



Historia de la Ley N° 21.522

Introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Mensaje	3
1.2. Informe de Comisión de Constitución	8
1.3. Discusión en Sala	43
1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	56
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	59
2.1. Informe de Comisión de Constitución	59
2.2. Discusión en Sala	73
2.3. Boletín de Indicaciones	77
2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución	79
2.5. Discusión en Sala	97
2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	117
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	119
3.1. Discusión en Sala	119
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	129
4. Trámite Veto Presidencial	130
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	130
4.2. Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen	134
4.3. Oficio a la Corte Suprema	141
4.4. Informe de Comisión de Constitución	142
4.5. Discusión en Sala	152
4.6. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	160
4.7. Oficio de la Corte Suprema	161
4.8. Informe de Comisión de Constitución	164
4.9. Discusión en Sala	172
4.10. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	178
5. Trámite Tribunal Constitucional	179
5.1. Oficio al Tribunal Constitucional	179
5.2. Oficio del Tribunal Constitucional	184
6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	187
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	187
7. Publicación de Ley en Diario Oficial	192
7.1. Ley Nº 21.522	192

Mensaje

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 23 de junio, 2021. Mensaje en Sesión 49. Legislatura 369.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO AL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO AL PROXENETISMO, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES.

Santiago, 23 de junio de 2021.

MENSAJE N° 104-36 9/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que tiene por objeto introducir un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes.

I. ANTECEDENTES

La legislación nacional en materia de delitos sexuales ha venido experimentando una serie de importantes reformas destinadas a la adecuada persecución penal de ciertas conductas, las cuales a su vez han permitido proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes. En este sentido cabe destacar las siguientes modificaciones:

(i) la ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, del año 2011; (ii) la ley N° 20.526, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil, del año 2011; (i) la ley N° 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades, del año 2012; y, (iv) la ley N° 20.685, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores, del año 2013.

En igual sentido, tratándose de una materia de la mayor relevancia para nuestro Gobierno, cabe destacar que con fecha 18 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la cual modificó el Código Penal para establecer que la acción penal respecto de ciertos crímenes y delitos no prescribirá cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad. La respectiva modificación, brinda la posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia sin la presión del tiempo y posibilita interponer acciones reparatorias contra quienes resulten responsables, incluyendo a terceros que no hayan impedido el delito. De esta manera, las víctimas cuentan con un derecho permanente a perseguir responsabilidades cuando se sientan preparadas, sin la amenaza del vencimiento de periodos preestablecidos. Cabe destacar además que la ley también establece requisitos para la renovación de la acción civil, con el objeto de facilitar el acceso a la indemnización de perjuicios ocasionados por la comisión de estos delitos.

Otra iniciativa que va en la línea de perfeccionar la protección a los niños, niñas y adolescentes, se relaciona con el registro de agresores sexuales y personas inhabilitadas para trabajar con niños y niñas. En este sentido, el 5 de noviembre de 2018 nuestro Gobierno presentó al H. Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reformular el actual registro de personas inhabilitadas para trabajar con personas menores de 18 años de edad, con el objeto de perfeccionar su funcionamiento. Dicho proyecto (Boletín 12.208 -07) se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, con urgencia calificada de simple. Junto a lo anterior, durante el año 2018, el Servicio de Registro Civil e Identificación trabajó con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en un Addendum para complementar el Convenio de Colaboración existente materia, periódica entre ambos organismos en esta incorporando la transmisión de la base de datos de sentencias condenatorias que contengan las penas de inhabilidades absolutas perpetuas o temporales

Mensaje

para trabajar con menores de edad. Este Addendum fue suscrito por ambas instituciones con fecha 27 de diciembre de 2018 y se encuentra plenamente vigente.

Así también, cabe destacar que con fecha 11 de noviembre del año 2019, este Gobierno envió a discusión parlamentaria un proyecto de ley cuyo objetivo es excluir del beneficio de rebaja de condena regulado en la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos que atentan contra la indemnidad sexual de menores de edad, y que corresponden al catálogo que el proyecto señala, esto inhumano o degradante es: trato cruel, con violación o abuso sexual agravado; violación; violación de persona menor de 14 años; estupro; abuso sexual agravado; abuso sexual de persona menor de 14 años; trata calificada de personas, en relación a la explotación sexual. Dicho proyecto (Boletín N° 13.046-07) se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado. El objetivo de la propuesta es dotar al ordenamiento jurídico nacional, a la mayor brevedad posible, de las mayores herramientas para una cada vez mejor y más eficaz protección a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, razón por la cual este proyecto de ley se mantiene con urgencia suma para su discusión.

Todas estas iniciativas, unidas a la agenda que reforma la institucionalidad de atención a la niñez y adolescencia, que ha sido prioritaria para este Gobierno, se constituyen como referentes para nuevos avances en materia legislativa y armonizan con el proyecto de ley que someto a vuestra consideración, reforzando de esta manera la protección penal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.

II.OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con la presentación de este proyecto de ley / se busca recoger las sugerencias que los diversos actores institucionales y de la sociedad civil, han venido desarrollando durante los últimos 20 años y que se han plasmado en distintas iniciativas, siendo una de las más relevantes, la generación de estrategias como Marco intersectoriales para la Acción conocidas contrala explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

A través de las referidas estrategias, se ha relevado que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es considerada una de las más graves vulneraciones a los Derechos Humanos, ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niñas, niños y adolescentes, y en las comunidades. Esta práctica, con carácter delictivo, implica que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social (etaria, emocional, de género, entre otras) de una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándole a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales. En este sentido, es un fenómeno social que se desarrolla bajo ciertas lógicas de poder, por parte de personas adultas.

A la fecha, la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y la forma en que se presenta este delito, son los denominados delitos de "Favorecimiento de la prostitución infantil" (artículo 367 del Código Penal); la "Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio" (artículo 367 ter del Código Penal), entre otros.

Los respectivos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, favorecen la percepción y entendimiento -erróneo, por cierto-, de que las niñas, niños o adolescentes presentan algún nivel de "voluntariedad" para "participar" en la comisión de este delito. Esta noción, niega o condiciona la "calidad de víctima", al no considerar la situación de asimetría de poder que subyace entre una víctima y el o los victimarios. Esta forma de referirse y entender la explotación sexual se encuentra fuertemente arraigada en nuestra cultura, lo que se expresa muchas veces en las propias víctimas, quienes no necesariamente interiorizan la condición de explotación en la que se encuentran, al mediar intercambios con los explotadores como estrategia de sobrevivencia.

El presente proyecto ha sido elaborado a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia -que asumirá la responsabilidad de generar las políticas públicas relacionadas a materias de protección de derechos de niñas, niños Ministerio de y adolescentes-y el Justicia y Derechos Humanos, quien estuvo encargado técnicamente de seguimiento de los la generación y referidos Marcos para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes de los años 1999, 2012 y 2017, a través de los cuales se ha mantenido un diálogo constante representantes y constructivo con de la sociedad civil organizada de nuestro país y se ha contado con el apoyo técnico de instituciones y profesionales expertos en estas materias.

Mensaje

III.CONTENIDO DEL PROYECTO

Teniendo presente lo expuesto de forma precedente, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración propone, a nivel sustantivo, las siguientes modificaciones al Código Penal:

1)Intercalar un nuevo párrafo 6° bis en el título VII del Libro Segundo, diferenciándolo de los delitos de estupro y abusos sexuales propios e impropios. De esta forma se reconoce la particular fisonomía de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes respecto de los demás delitos sexuales.

2)Se deroga el actual artículo 366 quinquies, que contiene tanto la figura de "producción de material pornográfico con menores de edad", así como una definición de qué debe entenderse por tal tipo de material, la que resulta aplicable también para el delito del artículo 374 bis.

La propuesta refunde las figuras contenidas en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis, en un nuevo artículo 367 quáter. Para salvar problemas de derecho intertemporal, se contiene asimismo una norma de tránsito que, en términos generales, permite la persecución y condena de los hechos cometidos bajo la vigencia de las normas que ahora son derogadas.

3)En el artículo 367 se hacen las siguientes modificaciones:

a)Se cambia la figura desde la "prostitución" sexual"de una a la"explotación persona menor de dieciocho años. Como, a diferencia del término "prostitución", el término "explotación sexual" no cuenta con un arraigo conceptual en materia penal, se establecen sus contornos precisos mediante una definición.

b)Se define "explotación sexual" como la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.

e) Se agrega en el tipo calificado una descripción del reproche que atiende a la vulnerabilidad de la víctima.

4)En el artículo367bis se introducen las siguientes modificaciones:

a)Se elimina la alusión al término "servicios sexuales", en razón de no ser un término descriptivamente operativo, así como porque puede dar a entender que la víctima es un "prestador".

b) Se elimina el piso de edad de 14 años para este delito y se excluye el carácter especial subsidiario en relación a los delitos de violación y estupro. Esto, además de tener sentido como declaración de principios, permite que exista un concurso ideal entre las figuras de abuso propio y esta figura de explotación sexual.

5)Se agrega un artículo 367 quáter, que refunde las figuras contenidas en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis:

a)Se agrega el verbo "producir" , con lo cual se absorbe sin más la figura contenida en el artículo 366 quinquies, dado que el artículo 374 bis (que también se refunde en esta norma) contiene todos los elementos típicos.

b) Se cambia por la fórmula de futuro imperfecto del modo subjuntivo de los respectivos verbos.

e) Se elimina la referencia al artículo 374 bis por estar refundidos las figuras de los actuales artículos 366 quinquies y 374 bis.

6)Se agrega el nuevo artículo 367 quinquies, que establece que las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

7)Se agrega una norma de concurso, el artículo 367 sexies, para los casos en que estos delitos concurrieren con los delitos propios de atentados sexuales contra niñas, niños y adolescentes, dando preferencia a la figura con mayor penalidad, pero considerando como agravante la concurrencia del ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía.

8) Se deroga el artículo 374 bis, que pasa a refundirse con el artículo 367 quáter.

Mensaje

9) Se incorpora una norma transitoria para resolver problemas de derecho intertemporal, entregando soluciones a problemas de *lex mitior* (aplicación retroactiva de norma favorable), *ultra actividad* (aplicación de "ley derogada" para los hechos perpetrados durante su vigencia) y estableciendo la prohibición de *lex tertia* (formación de una "tercera ley" usando elementos favorables de la ley antigua y la ley nueva).

Estamos ciertos que, mediante estas innovaciones, se avanzará de manera significativa en la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial, cuando afecten a niños, niñas y adolescentes, y comenzaremos a saldar una deuda por mucho tiempo ignorada, pero recogida en el trabajo interinstitucional desarrollado por instituciones públicas y privadas durante las últimas décadas.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo primero . - Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1) Intercálase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis, nuevo :

"§ VI bis. Proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes." .

2) Derógase el artículo 366 quinquies.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 367:

a) Reemplázase, en el inciso primero, las expresiones "prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro" por los vocablos "explotación sexual de una persona menor de dieciocho años".

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

"Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales." .

e) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.".

4) Reemplázase en el artículo 367 ter las expresiones "a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro" y la coma (,) que las anteceden por los vocablos "obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución" .

5) Intercálanse los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies y 367 sexies, nuevos:

"Artículo 367 quáter. El que produjere, comercializare, importar e, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Mensaje

Artículo 367quiquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en los artículos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía serán considerados como una sola circunstancia agravante."

6) Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo segundo.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible." .

Dios guarde a V .E.,

SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE

Presidente de la Republica

KARLA RUBILAR BARAHONA

Ministra de Desarrollo Social y Familia

HERNAN LARRAIN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Informe de Comisión de Constitución

1.2. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 07 de diciembre, 2021. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 109. Legislatura 369.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO AL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO AL PROXENETISMO, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES".

BOLETÍN N° 14.440-07-01

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificado con urgencia de discusión inmediata.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en avanzar en la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial, cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

2) Normas de quórum especial .

No hay.

4) Trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

5) Aprobación en general.

El proyecto fue aprobado en general por los votos favorables unánimes de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Matías Walker; Juan Antonio Coloma, y Luciano Cruz-Coke (4-0-0).

6) Se designó diputada Informante a la señora Camila Flores.

II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El mensaje de S.E. el Presidente de la República entrega los siguientes antecedentes:

“ANTECEDENTES

La legislación nacional en materia de delitos sexuales ha venido experimentando una serie de importantes reformas destinadas a la adecuada persecución penal de ciertas conductas, las cuales a su vez han permitido proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes. En este sentido cabe destacar las siguientes modificaciones: (i) la ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, del año 2011; (ii) la ley N° 20.526, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil, del año 2011; (iii) la ley N° 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades, del año 2012; y, (iv) la ley N° 20.685, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores, del año 2013.

Informe de Comisión de Constitución

En igual sentido, tratándose de una materia de la mayor relevancia para nuestro Gobierno, cabe destacar que con fecha 18 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la cual modificó el Código Penal para establecer que la acción penal respecto de ciertos crímenes y delitos no prescribirá cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad. La respectiva modificación, brinda la posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia sin la presión del tiempo y posibilita interponer acciones reparatorias contra quienes resulten responsables, incluyendo a terceros que no hayan impedido el delito. De esta manera, las víctimas cuentan con un derecho permanente a perseguir responsabilidades cuando se sientan preparadas, sin la amenaza del vencimiento de periodos preestablecidos. Cabe destacar además que la ley también establece requisitos para la renovación de la acción civil, con el objeto de facilitar el acceso a la indemnización de perjuicios ocasionados por la comisión de estos delitos.

Otra iniciativa que va en la línea de perfeccionar la protección a los niños, niñas y adolescentes, se relaciona con el registro de agresores sexuales y personas inhabilitadas para trabajar con niños y niñas. En este sentido, el 5 de noviembre de 2018 nuestro Gobierno presentó al H. Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reformular el actual registro de personas inhabilitadas para trabajar con personas menores de 18 años de edad, con el objeto de perfeccionar su funcionamiento. Dicho proyecto (Boletín 12.208-07) se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, con urgencia calificada de simple. Junto a lo anterior, durante el año 2018, el Servicio de Registro Civil e Identificación trabajó con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en un Addendum para complementar el Convenio de Colaboración existente entre ambos organismos en esta materia, incorporando la transmisión periódica de la base de datos de sentencias condenatorias que contengan las penas de inhabilitaciones absolutas perpetuas o temporales para trabajar con menores de edad. Este Addendum fue suscrito por ambas instituciones con fecha 27 de diciembre de 2018 y se encuentra plenamente vigente.

Así también, cabe destacar que con fecha 11 de noviembre del año 2019, este Gobierno envió a discusión parlamentaria un proyecto de ley cuyo objetivo es excluir del beneficio de rebaja de condena regulado en la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos que atentan contra la indemnidad sexual de menores de edad, y que corresponden al catálogo que el proyecto señala, esto es: trato cruel, inhumano o degradante con violación o abuso sexual agravado; violación; violación de persona menor de 14 años; estupro; abuso sexual agravado; abuso sexual de persona menor de 14 años; trata calificada de personas, en relación a la explotación sexual. Dicho proyecto (Boletín N° 13.046-07) se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado. El objetivo de la propuesta es dotar al ordenamiento jurídico nacional, a la mayor brevedad posible, de las mayores herramientas para una cada vez mejor y más eficaz protección a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, razón por la cual este proyecto de ley se mantiene con urgencia suma para su discusión.

Todas estas iniciativas, unidas a la agenda que reforma la institucionalidad de atención a la niñez y adolescencia, que ha sido prioritaria para este Gobierno, se constituyen como referentes para nuevos avances en materia legislativa y armonizan con el proyecto de ley que someto a vuestra consideración, reforzando de esta manera la protección penal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con la presentación de este proyecto de ley, se busca recoger las sugerencias que los diversos actores institucionales y de la sociedad civil, han venido desarrollando durante los últimos 20 años y que se han plasmado en distintas iniciativas, siendo una de las más relevantes, la generación de estrategias intersectoriales conocidas como Marco para la Acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

A través de las referidas estrategias, se ha relevado que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es considerada una de las más graves vulneraciones a los Derechos Humanos, ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niñas, niños y adolescentes, y en las comunidades. Esta práctica, con carácter delictivo, implica que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social (etaria, emocional, de género, entre otras) de una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándole a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales. En este sentido, es un fenómeno social que se desarrolla bajo ciertas lógicas de poder, por parte de personas adultas.

Informe de Comisión de Constitución

A la fecha, la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y la forma en que se presenta este delito, son los denominados delitos de “Favorecimiento de la prostitución infantil” (artículo 367 del Código Penal); la “Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio” (artículo 367 ter del Código Penal), entre otros.

Los respectivos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, favorecen la percepción y entendimiento -erróneo, por cierto-, de que las niñas, niños o adolescentes presentan algún nivel de “voluntariedad” para “participar” en la comisión de este delito. Esta noción, niega o condiciona la “calidad de víctima”, al no considerar la situación de asimetría de poder que subyace entre una víctima y el o los victimarios. Esta forma de referirse y entender la explotación sexual se encuentra fuertemente arraigada en nuestra cultura, lo que se expresa muchas veces en las propias víctimas, quienes no necesariamente interiorizan la condición de explotación en la que se encuentran, al mediar intercambios con los explotadores como estrategia de sobrevivencia.

El presente proyecto ha sido elaborado a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia -que asumirá la responsabilidad de generar las políticas públicas relacionadas a materias de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes- y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien estuvo encargado técnicamente de la generación y seguimiento de los referidos Marcos para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes de los años 1999, 2012 y 2017, a través de los cuales se ha mantenido un diálogo constante y constructivo con representantes de la sociedad civil organizada de nuestro país y se ha contado con el apoyo técnico de instituciones y profesionales expertos en estas materias.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Teniendo presente lo expuesto de forma precedente, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración propone, a nivel sustantivo, las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Intercalar un nuevo párrafo 6° bis en el título VII del Libro Segundo, diferenciándolo de los delitos de estupro y abusos sexuales propios e impropios. De esta forma se reconoce la particular fisonomía de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes respecto de los demás delitos sexuales.

2) Se deroga el actual artículo 366 quinquies, que contiene tanto la figura de “producción de material pornográfico con menores de edad”, así como una definición de qué debe entenderse por tal tipo de material, la que resulta aplicable también para el delito del artículo 374 bis.

La propuesta refunde las figuras contenidas en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis, en un nuevo artículo 367 quáter. Para salvar problemas de derecho intertemporal, se contiene asimismo una norma de tránsito que, en términos generales, permite la persecución y condena de los hechos cometidos bajo la vigencia de las normas que ahora son derogadas.

3) En el artículo 367 se hacen las siguientes modificaciones:

a) Se cambia la figura desde la “prostitución” a la “explotación sexual” de una persona menor de dieciocho años. Como, a diferencia del término “prostitución”, el término “explotación sexual” no cuenta con un arraigo conceptual en materia penal, se establecen sus contornos precisos mediante una definición.

b) Se define “explotación sexual” como la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.

c) Se agrega en el tipo calificado una descripción del reproche que atiende a la vulnerabilidad de la víctima.

4) En el artículo 367 bis se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se elimina la alusión al término “servicios sexuales”, en razón de no ser un término descriptivamente operativo, así como porque puede dar a entender que la víctima es un “prestador”.

b) Se elimina el piso de edad de 14 años para este delito y se excluye el carácter especial subsidiario en relación a los delitos de violación y estupro. Esto, además de tener sentido como declaración de principios, permite que exista un concurso ideal entre las figuras de abuso propio y esta figura de explotación sexual.

Informe de Comisión de Constitución

5) Se agrega un artículo 367 quáter, que refunde las figuras contenidas en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis:

a) Se agrega el verbo “producir”, con lo cual se absorbe sin más la figura contenida en el artículo 366 quinquies, dado que el artículo 374 bis (que también se refunde en esta norma) contiene todos los elementos típicos.

b) Se cambia por la fórmula de futuro imperfecto del modo subjuntivo de los respectivos verbos.

c) Se elimina la referencia al artículo 374 bis por estar refundidos las figuras de los actuales artículos 366 quinquies y 374 bis.

6) Se agrega el nuevo artículo 367 quinquies, que establece que las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

7) Se agrega una norma de concurso, el artículo 367 sexies, para los casos en que estos delitos concurrieren con los delitos propios de atentados sexuales contra niñas, niños y adolescentes, dando preferencia a la figura con mayor penalidad, pero considerando como agravante la concurrencia del ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía.

8) Se deroga el artículo 374 bis, que pasa a refundirse con el artículo 367 quáter.

9) Se incorpora una norma transitoria para resolver problemas de derecho intertemporal, entregando soluciones a problemas de *lex mitior* (aplicación retroactiva de norma favorable), *ultra actividad* (aplicación de “ley derogada” para los hechos perpetrados durante su vigencia) y estableciendo la prohibición de *lex tertia* (formación de una “tercera ley” usando elementos favorables de la ley antigua y la ley nueva).

Estamos ciertos que, mediante estas innovaciones, se avanzará de manera significativa en la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial, cuando afecten a niños, niñas y adolescentes, y comenzaremos a saldar una deuda por mucho tiempo ignorada, pero recogida en el trabajo interinstitucional desarrollado por instituciones públicas y privadas durante las últimas décadas.”.

III.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 402 de 26 de octubre de 2021.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, junto con agradecer la invitación, valoró especialmente el interés de la Comisión por tramitar esta iniciativa que apunta a un tema tan relevante y sensible, considerando la gravedad de la situación de explotación y comercialización sexual que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) de nuestro país, fenómeno que se ha tornado cada vez más complejo de perseguir y combatir.

En dicho contexto, el boletín bajo estudio contribuiría justamente a proteger la indemnidad sexual de NNA, como parte de otras modificaciones legales orientadas hacia el mismo fin (por ejemplo, la imprescriptibilidad de delitos sexuales que les afecten, la exclusión de rebajas en condenas a quienes atenten contra la indemnidad sexual de menores, entre otros).

A continuación, expuso mediante la siguiente presentación:

Antecedentes.

I. Agenda legislativa vinculadas a protección de la esfera de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes.

1) El 5 de noviembre 2018 se envió el proyecto de ley que busca reformular el actual Registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de 18 años (boletín N° 12.208-07). Se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

2) El 11 de julio de 2019 se promulga la ley N° 21.160 que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Informe de Comisión de Constitución

3) El 11 de noviembre de 2019 se envió el proyecto de ley para excluir del beneficio de rebaja de condena de la ley N° 19.856 a quienes hayan atentado contra la indemnidad sexual de menores de edad (boletín N° 13.046-07). Se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

II. Marco para la Acción contra la Explotación Sexual de Niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

1) La ESCNNA, es un fenómeno caracterizado por una multiplicidad de situaciones y sucesos entre los cuales se destaca la clandestinidad de su ocurrencia, la tolerancia de la sociedad y la compleja reparación del daño en las víctimas.

2) Desde el año 1999, el Estado de Chile ha desarrollado una estrategia interinstitucional tendiente a abordar dicho fenómeno denominada “Marco para la Acción contra la ESCNNA”, estableciéndose directrices que permitan focalizar el trabajo en líneas de acción, siendo una de ellas la sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas.

3) Como una conclusión del Tercer Marco para la Acción contra ESCNNA 2017 - 2019, se señala que se deben redoblar los esfuerzos en la persecución a los explotadores, para lo que se sugiere el revisar y modificar el Código Penal, eliminando la “prostitución infantil” y consignando el delito de ESCNNA, superando la utilización del concepto “prostitución infantil” el que genera nociones e imaginarios sociales de que existe plena voluntariedad por parte de las víctimas en la comisión de este delito.

4) En la actualidad se proyecta la generación de un Cuarto marco para la Acción, esta vez a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que debe estar en sintonía con los avances en materia de institucionalidad en niñez y adolescencia, a partir de la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

III. Convenio de colaboración referente a ESCNNA celebrado entre Ministerio Público - MINJUDH.

El 11 de junio de 2021 se firmó un convenio de colaboración con la finalidad de:

1) Favorecer instancias de trabajo colaborativo entre ambas instituciones que contribuyan a la detección oportuna de los delitos relacionados con ESCNNA y a la mejora de la persecución penal de los ofensores, mediante la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

2) Articular un trabajo interinstitucional, que permita un flujo de información sobre casos denunciados ante la autoridad competente, contribuyendo al desarrollo de la investigación de las causas relativas a ESCNNA, en que las víctimas sean representadas jurídicamente por el Programa Mi Abogado del MINJUDH, y donde éste cuente con la calidad de interviniente.

A la fecha se ha activado el protocolo en 7 oportunidades, poniéndose a disposición del Ministerio Público información con el objeto de aportar a la investigación.

Ideas y contenidos de la iniciativa.

I. Ideas Centrales del Proyecto

1) Visibilizar el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Las instituciones han relevado que la ESCNNA, es considerada una de las más graves vulneraciones a los DD.HH., ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niñas, niños y adolescentes, y en las comunidades.

Esta práctica implica que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social de una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándole a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales. Es un fenómeno social que se desarrolla bajo ciertas lógicas de poder, por parte de personas adultas.

2) Diferenciar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de los otros delitos sexuales cometidos en contra de ellos.

Informe de Comisión de Constitución

Actualmente nuestra legislación no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Existen los denominados delitos de “Favorecimiento de la prostitución infantil” (Artículo 367 del C. P.); la “Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio” (Artículo 367 ter del C.P.); la “Producción de material pornográfico en el que participen menores de edad” (artículo 366 quinquies del C.P.)

No obstante, estos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, favorecen la percepción y el errado entendimiento de que niños, niñas y adolescentes presentan algún nivel de “voluntariedad” para “participar” en la comisión de este delito.

3) Darle un tratamiento orgánico en el Código Penal a la Explotación Sexual.

Esto contribuirá a definir los contornos jurídicos del fenómeno, estableciendo bajo este título los diversos tipos penales relacionados con la explotación sexual que se encuentran dispersos en el código.

II. Contenido de la iniciativa

1) El artículo 1° introduce las siguientes modificaciones al Código Penal:

a) Intercala un nuevo párrafo 6° bis, en el título VII del Libro Segundo del Código Penal.

b) Deroga el artículo 366 quinquies.

c) Introduce modificaciones al artículo 367:

- Se cambia la figura desde la “prostitución” a la “explotación sexual” de una persona menor de dieciocho años.

- Se define “explotación sexual” como la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.

- Se agrega en el tipo calificado una descripción del reproche que atiende a la vulnerabilidad de la víctima.

d) Se modifica el artículo 367 ter, eliminando la alusión al término “servicios sexuales” y el piso de edad de 14 años para este delito.

e) Se Intercala los artículos 367 quáter, 367 quinquies y 367 sexies, nuevos, refundiendo el contenido de los artículos 366 quinquies y 374 bis y absorbiendo el contenido del artículo 374 ter.

f) Se derogan los artículos 374 bis y 374 ter.

2) El artículo 2°, establece una norma transitoria para resolver problemas de derecho Inter temporal, entregando soluciones a problemas de:

- Aplicación retroactiva de norma favorable,

- Aplicación de “ley derogada” para los hechos perpetrados durante su vigencia y,

- Estableciendo la prohibición de formación de una “tercera ley” usando elementos favorables de la ley antigua y la ley nueva.

Finalmente, reiteró la importancia de avanzar en esta materia, por su especial impacto en la defensa y protección de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, esperando una pronta y favorable tramitación del boletín en comento.

La representante de la Mesa sobre Incidencia contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCENNA), señora Mónica Contreras, junto con agradecer la invitación, destacó los esfuerzos por visibilizar este tipo de situaciones tan graves que afectan a NNA, siendo especialmente importante por formar parte de un contexto más amplio que busca enfrentar tales hechos de gravedad. Resaltó la necesidad de definir mejor la cantidad de víctimas afectadas por este tipo de delitos, pues las cifras que hoy se manejan están desactualizadas. Por ende, estimó relevante incluir la consideración de los nuevos espacios de riesgo como las redes sociales, que se suman a las ya existentes, siendo un fenómeno transversal al que se exponen los NNA a lo

Informe de Comisión de Constitución

largo del país, sugiriendo tener presente también este factor. Por último, consideró que la pandemia ha profundizado el conflicto, haciendo aún más urgente su confrontación.

La abogada de la Corporación Opción, señora Camila De La Maza, junto con agradecer la invitación, valoró especialmente este proyecto que permitirá visibilizar a quienes son víctimas de delitos de esta naturaleza, entendiendo las dificultades que existen hasta ahora para investigar y sancionar estas prácticas, tanto por la falta de una conceptualización apropiada, como por las dificultades en el modo investigativo aplicado por el Ministerio Público y las policías, derivando en que el éxito de las actuaciones pase a depender de la voluntad del ente persecutor. En este sentido, si bien el proyecto es bastante acotado, debería ampliarse a otras acciones que permitan hacerse cargo del fenómeno de manera más integral, incluyendo un cambio sustantivo en la política cultural de fiscales, policías y entidades judiciales, ya que sin esto no se podrá avanzar realmente en las investigaciones, quitando el peso que hoy se deja recaer en las víctimas, es decir, la carga de la prueba debería estar en los victimarios y no en las víctimas, evitando así un abordaje superficial de estas situaciones. En consecuencia, se debería establecer claramente la tipificación objetiva del delito, independientemente de la actitud subjetiva de las víctimas.

El diputado Ilabaca (Presidente), manifestó la disponibilidad para avanzar a la brevedad en la tramitación de este importante proyecto de ley, esperando que durante la próxima sesión ordinaria se despache en su totalidad.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos agradeció la favorable acogida al proyecto, señalando que se evaluarán las sugerencias enviadas por la Defensora de la Niñez, junto con manifestar plena disponibilidad para continuar participando en la tramitación del mismo durante la siguiente sesión ordinaria.

Sesión N° 405 de 10 de noviembre de 2021.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, refiere que su ministerio ya se ha pronunciado en extenso en sesiones pasadas, particularmente en la presentación del mensaje, por lo que espera que, si así lo tiene bien el presidente y la comisión, se proceda lo antes posible a votar en general y poder darle continuidad al análisis de las indicaciones que pudiera existir.

La Defensora de la Niñez, en primer lugar, hace hincapié en revelar la importancia de la materia que aborda el mensaje, la que a su juicio constituye una de las deudas pendientes del Estado de Chile para con los niños, niñas y adolescentes y que dice relación con la regulación legal del delito de explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

En el mismo sentido, realiza un reconocimiento al trabajo realizado en la materia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de las respectivas Subsecretarías de Justicia y de Desarrollo Social en relación a las modificaciones necesarias al tipo penal existente.

En efecto, el Código Penal habla de un concepto que se debe erradicar, referido a la “prostitución infantil” que asume una suerte de voluntariedad de las víctimas en una comisión que, evidentemente, es delictiva y que redundando en una agresión manifiesta desde el punto de vista de los derechos humanos de quienes son víctimas.

Desde ese punto de vista, comparte con el Ministro de Justicia la necesidad de avanzar rápidamente en la aprobación en general y en particular del proyecto.

Inicia su análisis más técnico con la definición de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y como a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 19 y 34, y también a través de la Observación General N° 13 del Comité de los Derechos del Niño, se abordan los conceptos de abuso y explotación sexual infantil, en todas sus formas, constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y de los derechos del niño a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar.

Una de las obligaciones que impone dicha convención es asegurar la protección de ellos y ellas contra todas las formas de violencia, y el Comité de los Derechos del Niño ha definido modos fundamentales de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes los siguientes: 1) abuso sexual infantil con o sin contacto físico; 2) imágenes de abuso sexual a través de las TIC; 3) Explotación sexual infantil y trata de personas. Estos últimos dos delitos son los que abarca el proyecto de ley.

Como indicó al inicio de su intervención, el proyecto de ley aborda una materia primordial -un delito gravísimo-,

Informe de Comisión de Constitución

que constituye un fenómeno delictivo multicausal con la participación de distintos actores, donde no solo está explotado, sino también el facilitador - que es quien tolera y promueve esta situación - y, por cierto, que también está presente el cliente - quien en dicho concepto es quien abusa de manera sexual de la víctima y genera el cumplimiento del circo delictivo.

También se debe considerar las relaciones de poder que median con los niños, niñas y adolescentes, y cómo también se involucran una serie de transacciones relacionadas a este tipo, como el dinero, especies, regalos, favores u otras formas de intercambio asimétricos que generan una dificultad muy importante desde el punto de vista del reconocimiento de las víctimas como tales. Desde éste último punto, se hace relevante que quienes operan en el sistema de persecución penal cuenten con una capacitación y habilidades especializadas que permitan realizar investigaciones lo suficientemente rigurosas para no discriminar y excluir a estas víctimas y así poder perseguir eficazmente a los abusadores, lo que a juicio de la Defensora no ha ocurrido hasta ahora.

La expositora enfatiza en que, dentro de este tipo penal, no existe posibilidad de defender que existe voluntad de la víctima porque, obviamente, el poder y explotación es la que se impone respecto de cualquier otra consideración en éste sentido. No debemos olvidar que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ha sido catalogada como una de las violaciones más severas a los derechos humanos.

Los aspectos positivos del proyecto son, a su juicio, los siguientes:

1.- Reconocimiento de una fenomenología específica.

Cuando hablamos de explotación comercial de NNA no se habla de cualquier tipo de delito, ni siquiera de un delito sexual común, y por ello es relevante que se trate en el nuevo párrafo de "Proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes".

2.- Incorporación de delitos relacionados con pornografía infantil.

En el contexto de ESCNNA (explotación sexual de niños, niñas y adolescentes) se reconocen distintas modalidades de comisión, lo que a su vez permite tener mayores probabilidades de recoger elementos probatorios que, desde el punto de vista de la investigación, permitan luego la imputación de estos hechos delictuales como así mismo la consecuente sanción

3.- El lenguaje utilizado da cuenta de una realidad.

El lenguaje da cuenta de la realidad, y pone el énfasis y la responsabilidad en la conducta del que promueve la explotación y no en una supuesta "voluntariedad" de la víctima. De esa forma, se descarta lo que hoy existe en esta línea a raíz de un concepto de prostitución infantil que de alguna manera descansa la responsabilidad en una supuesta voluntariedad de la víctima, favoreciendo la comisión del delito.

La Defensora, - acto seguido- manifiesta la voluntad del servicio que encabeza para trabajar junto con el Ejecutivo y las y los legisladores, con el objeto de realizar las siguientes mejoras al boletín:

1.- Aumentar la pena asignada a los delitos del nuevo párrafo propuesto, y así lograr que la ESCNNA sea considerada como un crimen y no un simple delito.

La propuesta del Ejecutivo aún le asigna una pena de simple delito, no resultando ser proporcional al impacto y daño que la comisión del mismo provoca en las víctimas. Tanto es así que el Estado de Chile ya ha sido cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño y distintas organizaciones internacionales en esta materia.

2.- Realización de una adecuación de la norma con el actual artículo 368 ter del Código Penal, que sanciona el cierre de locales, y que se refiere a los artículos 366 quinquies y 374 bis del mismo cuerpo legal, derogados por el proyecto de ley en comento por coherencia legislativa.

3.- Incorporar una agravante especial para funcionarios públicos, dada la especial gravedad de la participación de quienes aprovechan su función pública para favorecer, promover, tolerar o ejecutar este delito.

Lamentablemente (refiere la expositora) no es poco habitual conocer de denuncias donde, al interior de recintos públicos, - dicho sea de paso en contexto tan graves como al interior de residencias de protección -, se han

Informe de Comisión de Constitución

producido hechos delictivos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

4.- Establecer una norma especial de reincidencia que también reconozca sentencias dictadas en el extranjero, aunque no se haya cumplido.

5.- Aplicar las técnicas especiales de investigación de los artículos 411 del Código Penal o 222 del Código Procesal Penal, siempre y cuando se eleve la pena del artículo 367. De esta forma, se permitiría que por primera vez como país seamos capaces de prevenir la explotación sexual de los niños, y en aquellos casos en que no logremos evitarlos seamos lo suficientemente eficientes como sistema penal para investigar y sancionar a los responsables.

Finalmente, la Defensora hace presente que este proyecto evidentemente se relaciona con todo lo que se está abordando en un proyecto de ley que se está discutiendo y que aborda la criminalidad organizada [1], y en ese sentido les parece importante hacer una adecuación normativa, mirando y revisando esto con la perspectiva más global del sistema penal, debido a que se necesitan definiciones precisas y especiales y la generación de potentes técnicas de investigación reforzadas que permitan una detección y persecución oportuna y eficiente de los delitos considerando, además y como aspecto clave y central, el tratamiento protector de las personas que son víctimas de aquellos delitos, asegurándose debidamente el acceso a la justicia y la reparación.

No es lo mismo el estudio del crimen organizado relacionado a contrabando de drogas o de armas que investigar crimen organizado relacionado con delitos de abuso sexual, particularmente porque en el primero no existen víctimas directas, muy distinto a lo que sucede con la criminalidad organizada que abusa y utiliza a niños, niñas y adolescentes.

Por último, la Defensora recuerda a los miembros de la comisión que envió su apreciación y observaciones al proyecto en discusión a través del Oficio 606/2021 del 28 de julio del presente año, el que se encuentra en el siguiente link:

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=239448&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

El diputado Matías Walker pregunta a los invitados si el catálogo de los nuevos delitos de abuso sexual y pornografía infantil que incorpora el Mensaje quedan comprendidos dentro catálogo de delitos declarados como imprescriptibles por la ley N° 21.160, el que por cierto contiene un listado taxativo de los delitos relacionados con el abuso y explotación sexual infantil. De no estar incorporados, hace presente el diputado que deberían entonces ocuparse de aquellos.

El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín, indica que al tipificar de una forma distinta el delito de explotación sexual infantil puede hacer que, lo que hoy se quiere modificar, no esté debidamente incorporado en la ley que declaró la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, por lo que será una materia que abordará en detalle para que, de no estar incorporados, se agreguen en la forma debida y evitar vacíos legales.

Por último, la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato, solicita excusar a la Ministra de Desarrollo Social y Familia por ausentarse de la sesión de hoy, y agradece el espacio que otorga la comisión para la discusión de este proyecto, el que espera sea tramitado con celeridad. Manifiesta también su voluntad de trabajar en conjunto con todos aquellos que quieran mejorar la propuesta del Ejecutivo.

A continuación, el señor presidente solicita al señor secretario de la comisión tomar la votación general del proyecto en tabla.

VOTACIÓN GENERAL

En votación general el proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Matías Walker; Juan Antonio Coloma, y Luciano Cruz-Coke (4-0-0).

Sesión N° 407 de 24 de noviembre de 2021.

Informe de Comisión de Constitución

La señora Ymay Ortiz, Directora de la U. Especializada en DDHH, Delitos sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público da inicio a su exposición agradeciendo la invitación de la Comisión. Informa que en representación del Ministerio Público ha preparado una minuta para su exposición, la que pasa a leer en los siguientes términos:

	Minuta Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín N° 14.440-07)
---	--

1. Valoración del proyecto

La Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante ESCNNA), entendida también como violencia sexual con “intercambio”, tiene en el centro el involucramiento de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales, para la satisfacción de los intereses y deseos de otras personas, o de sí mismos, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalía. En consecuencia, la ESCNNA constituye una grave violación de los Derechos Humanos de NNA.

Su principal característica -a diferencia de otros tipos de violencia sexual, como los abusos sexuales- es el intercambio y la percepción de que el niño o niña recibe una retribución en el marco de una relación consentida y voluntaria.

La ESCNNA es un fenómeno complejo en el que intervienen distintos factores sociales, económicos, políticos y culturales. En la mayoría de los casos, las víctimas han sufrido deprivaciones culturales y afectaciones significativas, tales como negligencia permanente por parte de sus cuidadores; experiencias previas de violencia física, psíquica y/o sexual; institucionalización temprana; escasas o nulas redes de apoyo; entre otras. Lo anterior hace que las víctimas no se sientan como tales, sean estigmatizadas y tengan una percepción de responsabilidad, por lo que las denuncias e investigaciones por delitos en contexto de ESCNNA son escasas, invisibilizando aún más el fenómeno. A lo anterior se suma la falta de una regulación integral y equipos investigativos especializados y suficientes en todo el territorio [2]. En suma se requiere abordar la dinámica victimológica vinculada a la ESCNNA, para desarrollar procesos de trabajo especiales e integrales, con personal capacitado que conozca del fenómeno y atienda especialmente a sus dificultades, con el objeto de hacer efectiva la persecución penal y brindar protección a las víctimas.

La terminología utilizada actualmente en nuestro Código Penal colabora con el mantenimiento de los prejuicios y estigmatización de las víctimas. Así, al hablar de “prostitución infantil”; “trabajador sexual infantil”, se les niega o minimiza en su calidad de víctimas a niñas, niños y adolescentes explotados. Es importante recalcar que la terminología recién señalada no es apropiada para referirse a quienes son víctimas de estos delitos, pues mantiene la lógica de que los niñas, niños y adolescentes (NNA) explotados se encuentran en dicha situación voluntariamente, lo que claramente es una concepción errónea del fenómeno.

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público valora el presente proyecto de ley, al buscar mejorar la regulación actual, que no se hace cargo de manera suficiente del fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

2. Observaciones particulares a la propuesta

Sin perjuicio de su valoración en general, el Ministerio Público tiene una serie de observaciones respecto al articulado propuesto en el presente proyecto de ley, especialmente en lo relativo a algunos ajustes legales que se hacen a propósito de delitos vinculados con la utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, y a los nuevos delitos de explotación sexual comercial de NNA.

2.1. Sobre la incorporación del párrafo VI bis.

Informe de Comisión de Constitución

1) Intercálase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis, nuevo:

“§ VI bis. Proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.”.

Al igual que como ha sido señalado en esta Comisión por otros intervinientes, la incorporación de un nuevo título permite visibilizar y diferenciar los delitos asociados al fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de otros abusos sexuales.

Sin perjuicio de lo anterior, se considera mejorar la nomenclatura empleada en el título del párrafo, a uno más acotado que permita englobar de mejor manera el contenido de los delitos cuyas conductas se describen a continuación, pues entendemos que el propósito de este proyecto de ley es precisamente visibilizar el fenómeno de la explotación sexual comercial de NNA.

En ese sentido, se propone como título “De la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, que comprende como modalidades tanto la ESCNNA caracterizada por la transacción en sus artículos 367 y 367 ter, así como el uso de niños, niñas y adolescentes en pornografía en el artículo 367 quáter.

2.2. Sobre las adecuaciones a los delitos de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía (derogación arts. 366 quinquies y 374 bis y ter y refundición en nuevos arts. 367 quáter y 367 quinquies)

Sobre este respecto, se valora el espíritu del proyecto de ley en el sentido de incorporar los tipos penales relacionados a la utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía en el mismo Título de la explotación sexual, por las razones antes señaladas.

Esto dota de mayor sistematicidad al Código Penal en la materia, entendiendo estas conductas como una modalidad de la explotación sexual contra NNA.

En ese sentido, se valora sin observaciones trasladar la regla contenida en el actual art. 374 ter al nuevo art. 367 quinquies.

Sin embargo, y si bien se valora la idea de refundir las conductas contenidas en los artículos 366 quinquies y 374 bis, en un único artículo 367 quáter, dejando todas ellas descritas en una misma disposición y subsumidas en el mismo título referido a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la propuesta de modificación puede generar resultados no deseados y perjudiciales para la persecución penal, por dos órdenes de cosas:

i) Al incorporar el verbo rector de la producción en el mismo listado de conductas asociadas a la distribución, desaparece la producción como tipo penal autónomo.

Que si bien actualmente las conductas de participación en la producción de material pornográfico y la de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión y exhibición del mismo material, tienen la misma pena de presidio menor en su grado máximo, constituyen conforme a nuestra tipificación actual, delitos distintos.

Por esa razón, ante situaciones donde el o los autores participen en la producción de material pornográfico y también difundan, la práctica judicial ha aplicado las reglas concursales, castigando en algunos casos como concurso ideal o concurso real ante la concurrencia de ambas conductas, dependiendo del caso. En la práctica, ello se traduce en la aplicación de una pena más alta que si solo se considerara la realización única de solo uno de los delitos.

En cambio, la modificación legal que se propone, derechamente refunde todos los verbos, creando un único delito de producción y/o difusión de material pornográfico donde se utilicen NNA, de modo similar a lo que ocurre en los delitos vinculados al tráfico de drogas en la Ley N° 20.000.

En definitiva, una modificación en este sentido iría derechamente en detrimento de la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual a través de su utilización en pornografía, que consideramos no está en el espíritu de lo querido por el Mensaje del Presidente de la República.

ii) Al modificar el verbo rector de la producción de material pornográfico, desaparece una de sus consecuencias en cuanto a igualar la pena aplicable a los autores y los partícipes.

Informe de Comisión de Constitución

En un segundo orden de ideas, al modificar el verbo rector de la producción de material pornográfico desaparece una de sus consecuencias en cuanto regulada la pena aplicable a los actores que participan. En ese sentido, el actual artículo 366 quinquies del Código Penal, castiga a “el que participare en la producción”, siendo sostenido por la doctrina mayoritaria nacional que con esto se ha querido castigar con la misma pena tanto a los autores de la producción del material, como a todas las otras personas que participen en su producción, ampliándolo por tanto a los cómplices.

Que como ha sido advertido por algunos autores, esta interpretación se ajusta plenamente a las obligaciones del Estado en cuanto a la sanción de estas conductas, en orden a procurar una efectiva tutela a los intereses de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.

En ese sentido, la modificación propuesta constituiría un retroceso en la legislación penal en esta materia, disminuyendo el ámbito de protección al bajar la pena aplicable al resto de los partícipes en la producción del material pornográfico en que han sido utilizados niños, niñas y adolescentes.

PROPUESTA DE ARTÍCULADO

En definitiva, y con el objeto de mejorar la redacción y no ir en detrimento de la posible persecución penal de estas conductas, se propone refundir ambos artículos, manteniendo la redacción del actual inciso primero del art. 366 quinquies, intercalando luego los incisos primero y segundo del art. 374 bis, terminando con un texto adecuado del inciso final del art. 366 quinquies, en el siguiente sentido:

“Art. 367 quáter. El que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados niños, niñas y adolescentes, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas y adolescentes, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas y adolescentes, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados niños, niñas y adolescentes, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines”.

Sin perjuicio de lo anterior, llamamos la atención, sobre la situación de los adolescentes que produzcan y compartan voluntariamente el material entre ellos (caso pololeo), siendo necesario la incorporación expresa de los exima de sanción [3].

Para avanzar hacia una sanción más completa y actualizada del fenómeno, debería incorporarse otras actividades de explotación a través de imágenes y/o video que no implican “material pornográfico” propiamente tal: uso de webcams, streaming, etc.

Modificaciones a los artículos 367 y 367 ter.

En relación al actual artículo 367 del Código Penal, el proyecto de ley propone modificar tanto la redacción del delito base como de su figura agravada, e incorporar además un inciso tercero que define lo que se va a entender por explotación sexual.

Que como ya se observó, la terminología utilizada actualmente en nuestro Código Penal colabora con el mantenimiento de los prejuicios y estigmatización de las víctimas. Así, al hablar de “prostitución”, se niega o minimiza en su calidad de víctimas a niñas, niños y adolescentes explotados y mantiene la lógica de que estas personas explotadas se encuentran en dicha situación voluntariamente.

Por lo anterior, se valora positivamente la modificación del delito base del art. 367, reemplazando la referencia de la prostitución para la satisfacción de los deseos de otro, por la explotación sexual de las víctimas.

Informe de Comisión de Constitución

En cuanto a la pena, y al igual que lo señalado por la Defensoría de la Niñez en su intervención previa, se comparte la necesidad de aumentar la penalidad del delito base, atendidas las recomendaciones internacionales en la materia, y también para mantener una debida coherencia con la pena del delito de trata de personas con fines de explotación sexual del art. 411 quáter del Código Penal. En ese sentido, parece adecuado aumentar el marco penal al de presidio mayor en su grado mínimo.

En cuanto al delito agravado actualmente establecido en el inciso segundo de la norma, entendemos que el sentido de la modificación propuesta por el Proyecto de Ley dice relación con atender a la especial vulnerabilidad en que se pueden encontrar las víctimas explotadas. Sin embargo, la redacción que se propone, elimina sin mayor fundamento circunstancias relativas al abuso de autoridad o de confianza, y las reemplaza por el haber actuado “en razón de su dependencia personal o económica”. Sobre este punto, se estima que la mejor manera de incorporar un plus de injusto a propósito de la vulnerabilidad de la víctima, no es haciendo referencia a que esta es la razón ni la motivación del autor para realizar el hecho, si no que el autor abusa o se aprovecha de determinadas circunstancias para explotar sexualmente a la víctima.

En ese sentido, parece dotar de mayor sistematicidad a las conductas de explotación sexual reguladas aquí, con la figura de trata de personas con los mismos fines, la incorporación como circunstancias que agravan la explotación sexual de NNA, aquellas contenidas en la primera parte del inciso primero del artículo 411 quáter, relativas a actuar mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, autoridad o confianza, o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, manteniendo en todo caso aquellas circunstancias actualmente reguladas en el art. 367 relativas a la habitualidad.

Finalmente, en relación a la definición que se propone de explotación sexual como un inciso tercero nuevo, se valora su incorporación, tratándose de un elemento central del nuevo tipo penal.

Sin embargo, y a pesar de comprender las razones por las cuáles se hace referencia tanto a actos sexuales (en los términos del actual artículo 366 y 366 bis del Código Penal) y a acciones de significación sexual (en los términos del actual artículo 366 quáter del Código Penal), no parece una redacción clara ni precisa, que aclare en definitiva cuáles conductas podrán ser comprendidas como constitutivas de explotación sexual.

Por lo anterior, y también para dotar de mayor sistematicidad a la regulación de esta materia, se propone emplear un término distinto a los referidos a propósito de los abusos sexuales, que diga relación a toda actividad sexual, concepto empleado también por el legislador al describir el material pornográfico en que son utilizados niños, niñas y adolescentes.

Consideramos que esta nomenclatura permite entender sin duda que la conducta de la víctima explotada considera a las constitutivas de abusos sexuales, pero deja abierta la posibilidad de comprender también otro tipo de conductas sexualizadas a través de las cuáles los niños, niñas y adolescentes pueden ser explotados, ya sea a través de bailes, desnudamientos, tocamientos, etc.

En el mismo sentido, se propone realizar la misma modificación en la propuesta del art. 367 ter, reemplazando el empleo del concepto de “acción sexual” por el de “actividad sexual”.

PROPUESTA DE ARTICULADO.

“Art. 367. El que promoviere o facilitare la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si concurriere habitualidad o se cometiere el hecho mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, autoridad o confianza, o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, se impondrán las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de un niño, niña o adolescente para la realización de una actividad sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución”.

“Art. 367 ter. El que obtuviere la realización de una actividad sexual de un niño, niña o adolescente a cambio de cualquier tipo de retribución, será castigado con presidio menor en su grado máximo”.

Informe de Comisión de Constitución

Al respecto, se podría pensar que dejamos al tipo base un poco sin contenido. Pareciere difícil imaginarse al tipo base sin alguna de estas circunstancias, pero es precisamente la idea, ya que de esta manera bastaría que se den los elementos del tipo para que se configure el delito, y por lo tanto las posibilidades de prueba son mucho mejores respecto de poder acreditar la comisión del delito.

En este sentido, muchas veces el probar la habitualidad, la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de poder, es un poco difícil. Por lo tanto, concurriendo la acreditación de los elementos de la primera parte del artículo 367 ya se podría tener también por acreditado el delito.

2.3. Incorporación de agravante especial

Finalmente, se incorpora como un artículo 367 sexies, que lo dispuesto en los artículos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Consideramos que esta agravante es contraria al objetivo declarado del presente proyecto de ley, en cuanto a relevar a la explotación sexual comercial como un tipo específico de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes; y en específico a algunas modificaciones del mismo proyecto, como la que se señala a propósito del artículo 367 ter, donde se eliminó el carácter especial subsidiario en relación a los delitos de violación y estupro, para permitir el concurso ideal.

En ese sentido, al señalar expresamente que no se considerarán las conductas típicas descritas en este proyecto de ley, y se limita su uso como una única agravante, se termina por invisibilizar el fenómeno de la ESCNNA y limitar su aplicación en subsidio de la acreditación de otro tipo de agresiones sexuales.

Por lo demás, ello impide al tribunal apreciar la existencia de concursos ideales o materiales entre por ejemplo, la producción de material pornográfico en que han sido utilizados NNA, y un delito de violación o abuso sexual, cuando la doctrina mayoritaria en nuestro país parece inclinarse por la posibilidad de castigar conjuntamente ambas conductas a través de un concurso real, interpretación respaldada también por la jurisprudencia mayoritaria.

A sí mismo esta propuesta pierde sentido o coherencia, con la propuesta de incorporar modalidades comisivas en la figura agravada. Por ejemplo, si se intimida a la víctima, dependiendo de la actividad desplegada será siempre violación o abusos.

En definitiva, se sugiere a esta Comisión eliminar la agravante del propuesto artículo 367 sexies, por ir en contra de la mejor persecución y visibilización de los delitos que se buscan realzar.

Por último, es importante una norma que adecue todas aquellas que hacen referencia a estos delitos, por ejemplo art. 368 ter (a clausura de establecimientos) y 369 ter (técnicas especiales de investigación); 374 ter (regla sobre extraterritorialidad), etc.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín, luego de saludar a todos los presentes, indica que recién se han enterado de las observaciones y propuestas del Ministerio Público a través de la exposición que acaba de realizar la señora Ymay Ortiz, y que de alguna manera rearticulan el proyecto.

En efecto, a pesar de que valoran la iniciativa, existe una cantidad apreciable de información que hace complejo asumirlas con solo haber oído a la expositora, por lo que es difícil tener una opinión sobre cada una de ellas, por lo que es preferible que al iniciar la votación en particular del articulado se puedan revisar en detalle las mismas.

El diputado Ilabaca refiere que, luego de otorgar la palabra a la Ministra Rubilar, procederá a comunicar a la comisión una propuesta de trabajo en el sentido de hacer de éste proyecto, una mejor iniciativa de la que se ha presentado.

En el mismo sentido, la Ministra de Desarrollo Social, señora Karla Rubilar, agradeciendo la instancia a la que fue

Informe de Comisión de Constitución

invitada, indica que este proyecto se encuentra enmarcado en el combate a la explotación sexual infantil que lideró con mucha fuerza el Ministerio de Justicia, el Subsecretario de justicia y la Defensoría de la niñez, pero también por el trabajo en conjunto con varias organizaciones civiles como el Hogar de Cristo, Tierra Esperanza, Corporación Adopción, Ciudad del Niño, ONG Raíces, y tantos otros que están detrás de este trabajo y de empujar este esfuerzo mancomunado de decir de una vez por todas que no estamos frente a prostitución infantil sino a una explotación sexual infantil.

Es en este contexto donde varias posturas se han manifestado, siendo recogidas varias de ellas, como los de la Defensoría de la Niñez y que han sido revisadas con detención y que son muy relevantes. Así, la labor del Ministerio Público es muy importante, ya que se necesita que dicha institución este comprometida con la lucha para desbaratar delitos tan graves que marcan a las víctimas para toda su vida.

Con todo, al igual que el Ministro de Justicia, opina que es difícil emitir su parecer respecto de las observaciones y propuestas que les hace hoy el Ministerio Público, siendo necesario primero contar con la minuta que fue leída por la representante, de tal forma que puedan ser revisadas en detalles y hacer los esfuerzos para que el proyecto pueda ser despachado el día lunes de la próxima semana, si así lo tiene a bien la comisión.

Por último, señora Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, inmediatamente después de agradecer a todos los miembros de la comisión por la invitación, recuerda a la misma que la Defensoría, en el ánimo de contribuir al debate en particular del presente proyecto, despachó hace unas semanas una minuta con observaciones, y así poder tenerlas a la vista para hoy.

Por lo mismo, considera que luego de la intervención del Ministerio Público se hace necesario analizar dichas observaciones en detalle, siendo necesario para ello contar con el documento escrito lo antes posible, y de esa forma -en el marco de sus atribuciones legales- poder realizar recomendaciones a la Comisión en orden a lo que se podría considerar o no.

Con todo, de la exposición del Ministerio Público, hay cuestiones que preocupan, como la eximente que se propone en razón al pololeo. Al respecto, la expositora refiere que el solo hecho de la existencia de una relación sentimental no parece ser una justificante necesaria para evitar la persecución penal, más allá de casos puntuales y prácticos donde aquello pueda ser una realidad. La Defensoría conoce de la existencia de violencia intrafamiliar en el ámbito del pololeo, por lo que debería estudiarse una propuesta más profunda y no tan abierta.

Finaliza su exposición indicando que es importante legislar en esta materia con celeridad, considerando el impacto significativo que esto puede tener en las víctimas de explotación sexual comercial, y particularmente considerando las brechas significativas que en términos de persecución penal tiene este delito. Al respecto, aclara que no solo existen deficiencias manifiestas en la detección oportuna que permita prevenir este delito, sino también en su persecución penal que deberían revertirse con la generación de una legislación mucho más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

El diputado, señor Ilabaca, solicita a la representante del Ministerio Público el próximo envío de la minuta de su exposición. En este sentido, propone la conformación de una mesa de trabajo entre los miembros de la comisión y sus asesores, en conjunto con las autoridades y asesores de los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social, con la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio Público, para que puedan proponer un texto de indicaciones que recoja las observaciones emitidas por esta última entidad. SE ACUERDA por unanimidad de los miembros presentes.

Sesión N° 409 de 1 de diciembre de 2021.

VOTACIÓN PARTICULAR

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, manifiesta que, de acuerdo con lo conversado en la última sesión, se constituyó un grupo de trabajo coordinado por el Subsecretario de Justicia y en el que participaron la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, asesores de parlamentarios -entre ellos, el señor Enrique Aldunate-, y el equipo del Ministerio, con la finalidad de facilitar el desarrollo y la aprobación en particular de esta iniciativa.

En esa línea, el Subsecretario de Justicia expresa que la reunión tenía como propósito alcanzar consensos respecto de mejoras al articulado. Sin perjuicio de observaciones posteriores, hubo acuerdo en modificar el título del párrafo

Informe de Comisión de Constitución

VI bis que se incorpora, al eliminar la alusión a “proxenetismo” porque está incluido per se en el fenómeno de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Si bien fue una solicitud del Ministerio Público eliminar en el título del párrafo lo relativo a pornografía, se dialogó que podría existir casos de pornografía que no dieran cuenta de explotación sexual, por lo que era conveniente hacer mención de ambos fenómenos.

Un aspecto central de las observaciones del Ministerio Público –abogado también por la Defensoría de la Niñez– se relaciona con el artículo 367, que establece la tipificación de quien promoviére o facilitare la explotación sexual, consistente en el aumento de la pena (pasando a tener el estatus de crimen). Se planteó un problema de sistematicidad con otros delitos sexuales, sin embargo, el aumento de pena propuesto (presidio mayor en su grado mínimo) permitiría mantener una sistematicidad con la pena de la figura de trata de personas menores de edad con fines de explotación de sexual.

Otra modificación relevante es la de la figura relacionada con la pornografía, contenida en el artículo 367 quáter. Inicialmente, la propuesta legislativa unifica en un solo inciso lo que actualmente está separado en dos figuras delictivas: la producción de material pornográfico, y la comercialización, distribución o difusión de pornografía. El Ministerio Público hizo presente que esto podía llevar a un efecto indeseado, que quien produjere y quien comercializare o distribuyere fuera sancionado por un solo delito y no entenderse aplicable un concurso real delitos con un efecto agravatorio. En consecuencia, se separa en dos incisos diferentes.

Sobre la producción de material pornográfico, el Ministerio Público hizo una observación respecto a la participación delictiva. Actualmente, el Código Penal sanciona a “el que participare en la producción”, parte de la doctrina (no mayoritaria) entiende que hay un concepto más amplio, sancionar como autor aún a quienes tienen una intervención delictiva menor, en calidad de cómplice. En otras palabras, bajo esta regla especial, el cómplice estaría recibiendo la misma pena que el autor.

Como en el proyecto se sancionaba a “el que produjere” material pornográfico infantil, podía perder sentido esa interpretación; por ello, se ha mantenido la redacción vigente sancionando a “el que participare en la producción”.

Seguidamente, el Ministerio Público hizo presente la necesidad de incorporar otras actividades de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de imágenes o videos que no implican necesariamente una elaboración de material pornográfico, por ejemplo, a través del uso de webcam, streaming o la transmisión a través de la plataforma zoom –donde no hay una grabación, no hay elaboración– pero sí se pudiera estar afectando a un niño, niña o adolescente en el ámbito de la sexualidad. Si la actividad implica la difusión o transmisión a un número considerable o indeterminado de personas, aumenta la pena. Así se recoge en el nuevo artículo 367 septies.

Finalmente, se proponen cambios formales.

Al cerrar su intervención, plantea que se han recibido observaciones con posterioridad, por lo que se podrían analizar en cada caso particular.

El señor Walker agradece el trabajo mancomunado y valora que se haya incorporado el artículo 367 quater al catálogo que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

La señora Ymay Ortiz, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público, valora positivamente que se hayan incorporado varias de las sugerencias que hicieron presente, sin embargo, anuncia que persisten algunas diferencias de forma, las que pueden tener incidencia en el fondo, y que indicará durante la discusión del articulado.

La señora Jiles sugiere tener en cuenta cada una de las observaciones adicionales que sugiera el Ministerio Público, y cuestiona que el resultado de la mesa de trabajo no tenga el formato de indicaciones que se utiliza en esta instancia.

El señor Ilabaca (Presidente) aclara que las propuestas de la mesa de trabajo tendrán el formato de indicaciones al ser suscritas por los parlamentarios que así lo deseen. Se analizará artículo por artículo.

PROYECTO DE LEY:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo primero.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

Numeral nuevo

- Indicación del Ejecutivo. AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para agregar un numeral 1), nuevo, pasando el actual 1) a ser 2) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“1) Reemplázase en el artículo 94 bis, la expresión “366 quinquies” por “367 quater”.

La Directora de la Unidad Especializada del Ministerio Público observa que en el artículo 94 bis se debe intercalar también el artículo 367 septies nuevo, en caso de ser aprobado.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín, concuerda con lo señalado.

Sometido a votación el numeral 1) nuevo, contenido en la indicación N° 1 del Ejecutivo es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del señor Marcos Ilabaca y la señora Pamela Jiles, al artículo 94 bis, para intercalar la expresión “, artículo 367 septies,” a continuación del artículo 367 ter y antes del punto y coma que le sigue (;).

La indicación del señor Marcos Ilabaca y la señora Pamela Jiles queda pendiente, sujeta a la aprobación del artículo 367 septies nuevo en el numeral 5) del proyecto de ley.

Numeral 1)

1) Intercálase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis, nuevo:

“§ VI bis. Proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.”.

- Recogiendo la propuesta de la mesa de trabajo, el diputado Marcos Ilabaca presenta indicación para eliminar en el título del párrafo VI bis, nuevo, el vocablo “Proxenetismo” y la coma que le sigue.

En esa línea, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín, expresa que en la mesa de trabajo hubo consenso en eliminar la alusión a “proxenetismo” porque se encuentra comprendido en el fenómeno de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.

La señora Jiles estima innecesaria la eliminación, en el sentido de que “lo que abunda no daña”.

Puesto en votación el numeral 1, con la indicación, es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Leonardo Soto, y Matías Walker. Vota en contra la diputada señora Pamela Jiles (3-1-0).

Numeral 2)

2) Derógase el artículo 366 quinquies.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos aclara que el artículo 367 quater se hace cargo de los artículos 366 quinquies y 374 bis, en la reordenación que se propone.

La señora Jiles expresa que no está por derogar el artículo mientras no se apruebe la norma que lo reemplaza.

Informe de Comisión de Constitución

En votación el numeral 2 es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. Vota en contra la diputada señora Pamela Jiles (4-1-0).

Numeral 3)

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 367:

a) Reemplázase, en el inciso primero, las expresiones “prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro” por los vocablos “explotación sexual de una persona menor de dieciocho años”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.”.

- Recogiendo la propuesta de la mesa de trabajo, el diputado Marcos Ilabaca presenta indicación para sustituir el numeral 3) del proyecto de ley, por el siguiente:

“3) Sustitúyese el artículo 367, por el siguiente:

“ART. 367. El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.”.

Respondiendo la consulta de la señora Jiles, el señor Ilabaca (Presidente) aclara que efectivamente existe un cambio en la pena respecto del que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años, pasando de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín, expresa que este es un artículo clave porque el tipo penal que se concentraba en la prostitución de menores se sustituye por un concepto más amplio, que visibiliza un problema real, la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años. El tipo penal se modifica, y en la mesa de trabajo se consensuó aumentar la pena a solicitud de la Defensoría de la Niñez y del Ministerio Público.

El inciso segundo es una agravante que repite -adecuando el tipo penal en su redacción- la norma vigente.

El inciso final contempla una definición de explotación sexual, clave para la tipificación del delito, y para visibilizar este fenómeno y su amplitud. El concepto vigente es más restringido.

La señora Jiles comparte la importancia de que el artículo cuente con la definición de explotación sexual.

Informe de Comisión de Constitución

A continuación, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar, refuerza la idea respecto de la relevancia de la definición de la explotación sexual y el aumento de penalidad que se propone en la indicación, buscando homologar la pena con la trata de personas.

Sometida a votación el numeral 3) del proyecto de ley, con la indicación (que lo sustituye), es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Matías Walker. (5-0-0).

Numeral 4)

4) Reemplázase en el artículo 367 ter las expresiones “a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” y la coma (,) que las anteceden por los vocablos “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución”.

Puesto en votación el numeral 4) es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Matías Walker. (5-0-0).

Numeral 5)

5) Intercálanse los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies y 367 sexies, nuevos:

“Artículo 367 quáter. El que produjere, comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Artículo 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en los artículos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

Se acuerda discutir y votar cada artículo por separado.

Sobre el artículo 367 quáter:

- Recogiendo la propuesta de la mesa de trabajo, el diputado Marcos Ilabaca presenta indicación, al artículo 367 quáter, para eliminar en el inciso primero el vocablo “produjere”, y para incorporar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico.”.

El Subsecretario de Justicia expresa que el Ministerio Público puso de relieve la necesidad de mantener las figuras

Informe de Comisión de Constitución

de “producción de material pornográfico de menores de edad”, y “la comercialización, distribución o difusión de pornografía” en tipos penales diferentes, tal como ocurre actualmente en el Código Penal.

El proyecto de ley proponía tratarlos en un mismo artículo –en el inciso primero del artículo 367 quáter- (artículo que refunde los actuales artículos 366 quinquies y 374 bis). Sin embargo, el Ministerio Público advirtió que esto podía llevar a un efecto indeseado en la práctica, que quien produjere y quien comercializare o distribuyere fuera sancionado por un solo delito y no se entendiera aplicable un concurso real de delitos con un efecto agravatorio. El Ministerio Público aportó casos reales que habían tenido este tratamiento penal.

El riesgo que se producía por los términos en que está planteado el proyecto de ley es que al establecer todas estas conductas en un solo tipo penal, como verbos rectores alternativos, naturalmente, el efecto sería que a una persona no se le pudiera sancionar por ambas conductas, no habría concurso penal, lo que se traduce en una pena menor. A la luz de estos antecedentes se vio la conveniencia de mantener ambos tipos penales separadamente. Por eso, se incorpora un inciso segundo (las penas son las mismas).

Además, esta separación permite generar estadísticas (codificación por delito) útil para evidencia en materia de políticas públicas.

Sobre la producción de material pornográfico, precisa que el proyecto de ley sancionaba a “el que produjere” material pornográfico infantil, sin embargo, el Ministerio Público sugirió que se mantuviera la redacción actual “el que participare en la producción”, pues, con esa redacción, parte de la doctrina, entiende que se permitiría sancionar como autor aún a quienes tienen una intervención delictiva menor, en calidad de cómplice, es decir, el cómplice recibiría la misma pena que el autor.

El señor Enrique Aldunate observa que se podría producir un problema interpretativo con consecuencia político criminal complejo. En los orígenes de esta figura (reforma del año 2004), el verbo rector que se utilizaba era “emplear al menor”, el artículo vigente habla de “participar”. Al efecto, el académico don Mario Garrido Montt señala que el verbo participar no hay que atribuirlo a una equivalencia de participación en sentido estricto; cita: “cuando el tipo penal emplea la voz participar se refiere al proceso de producción del material pornográfico, importa que el menor intervenga de cualquier forma en el proceso sea interviniendo en actos de relevancia sexual que involucren su incorporación al contexto de ejecución de actos sexuales con posibilidad de una participación activa o meramente pasiva o de alguna otra manera. La noción participar ha de entenderse con amplitud.” En el análisis del artículo 366 quinquies, al momento de tratar el sujeto activo –cita nuevamente- “...comete el delito quien participa con un menor, noción que comprende a todos y cada uno de quienes intervienen en el proceso de producción siempre que tengan conocimiento de su intervención. La naturaleza de la participación puede ser a título de autor o cómplice y puede variar según el caso.”.

Al comprender que el inciso segundo se pretende hacer cargo de una posición en doctrina (que busca hacer equivalente la posición del cómplice con la del autor) se está en un problema porque la estructura del Código Penal distingue nítidamente, a partir del artículo 14, quienes son responsables del delito; distingue en el artículo 15 entre autores materiales o directos, instigadores o autores intelectuales, y autores contemplados en N° 3, concepto extensivo de autor pero que exige concierto previo.

La posibilidad político criminal de establecer un autor único existe, pero los precedentes históricos son nefastos, por ejemplo, el Código italiano de 1930 (Mussolini) no hizo distinción alguna.

Si se miran las conductas que sanciona el inciso primero y el inciso segundo no se entiende la distinción ni el tratamiento desigual, incluso la producción podría ser más relevante, en términos político criminal, para castigar a título de autor único, es decir, incorporar al cómplice. Especialmente, porque interpretativamente la doctrina está dividida en este punto, no cree que el legislador deba tomar posición en estas disputas y alejarse de la estructura y fisonomía del Código Penal chileno.

El problema radica en la voz “participar” (error en la reforma del año 2011). Si se quieren separar ambas conductas -para satisfacer la pretensión de separar las hipótesis concursales- habría que referirse al que “empleare” un menor en la producción de material pornográfico.

La Defensora de la Niñez expresa que es relevante destacar que el motivo de esta legislación son los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, y fortalecer aspectos de punibilidad que respondan proporcionalmente a la

Informe de Comisión de Constitución

gravedad manifiesta que representa la explotación sexual para ellos. A su juicio, la propuesta que se plantea producto del trabajo mancomunado no resulta en ningún caso perjudicial y atiende precisamente el espíritu de esta ley.

Por su parte, el abogado Sovino, del Ministerio Público, enfatiza que la propuesta del grupo de trabajo persigue mantener la redacción actual del tipo penal y la separación que existe en el Código Penal entre las figuras de producción, y las de comercialización, difusión, exhibición, etc.

Hace hincapié que existe jurisprudencia y doctrina que opina distinto. La idea es que la interpretación se vaya dando, en la práctica, como se ha ido desarrollando desde la creación del tipo penal de “participación en la producción de material pornográfico”. Solicita se mantenga la separación de los tipos penales, lo que aporta a los aspectos de política criminal mencionados por el Subsecretario.

El señor Illabaca (Presidente) concuerda que el objetivo es sancionar en forma contundente todo aquel que participe en la producción de material pornográfico, cuyo sustrato es la protección de niños, niñas y adolescentes; por ello, coincide con mantener la separación de los tipos penales, que permita la aplicación de concurso real de delitos.

En votación el artículo 367 quáter (contenido en el numeral 5), con la indicación, es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Marcos Illabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. Vota en contra la diputada señora Pamela Jiles (4-1-0).

Fundamento del voto:

La señora Jiles indica que lo que se intenta es contrario a lo que el texto señala; se está dejando fuera una actividad en vez de incluirla.

El señor Illabaca (Presidente) fundamenta que lo que se busca es separar la figura la producción de material pornográfico completa; queda comprendida en el inciso segundo, con la misma pena. La discusión doctrinaria tiene relación con el concepto de la participación, pero el objetivo es proteger a niños, niñas y adolescentes.

Sobre el artículo 367 quinquies:

Sometido a votación el artículo 367 quinquies (contenido en el numeral 5), es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Marcos Illabaca (Presidente de la Comisión); Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

Sobre el artículo 367 sexies:

La Defensora de la Niñez propone reemplazar la expresión “los artículos precedentes” por los vocablos “este párrafo”, con la finalidad que no quede duda que abarca todos los artículos del nuevo párrafo VI bis.

Por su parte, el abogado del Ministerio Público sugiere suprimir la frase “o la producción de pornografía”, porque estiman que no debería incorporarse como una agravante la producción de pornografía puesto que es un delito distinto. Ejemplifica, en caso de que una persona cometer violación contra un niño o niña y además produce pornografía, serían dos delitos distintos, que serían sancionados como concurso real. Hay jurisprudencia al respecto, la Corte Suprema al sancionar abuso sexual y producción de material pornográfico.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos manifiesta su conformidad con ambas observaciones.

- Se presenta indicación del diputado Marcos Illabaca, al artículo 367 sexies, para reemplazar la expresión “los artículos precedentes” por los vocablos “este párrafo”, y para suprimir la frase “o la producción de pornografía”.

Informe de Comisión de Constitución

Puesto en votación el artículo 367 sexies (contenido en el numeral 5), con la indicación, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

Artículo 367 septies, nuevo:

La mesa de trabajo liderada por el Subsecretario de Justicia propone incorporar el siguiente artículo 367 septies, nuevo:

“Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una persona menor de dieciocho años, de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado con presidio menor en su grado medio.

Cuando dicha transmisión fuere a un número considerable o indeterminado de personas, la pena será de presidio menor en su grado máximo.”

El abogado del Ministerio Público valora positivamente la incorporación de este nuevo tipo penal, sin perjuicio, observa algunos aspectos que pudieran traer problemas de interpretación.

Primero, la pena de esta figura debería ser la misma que la de la producción de material pornográfico puesto que utilizar un niño, niña o adolescente para que transmita imágenes a través de internet se asimila al tipo de producción de material pornográfico aunque no quede el registro grabado en un computador.

Segundo, los vocablos “dispositivos técnicos”, “situación o interacción” podrían complejizar el tipo; sería más fácil sancionar a el que transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una persona menor de dieciocho años llevando a cabo una acción sexual o de una acción de significación sexual.

Por último, en caso de aprobarse, se deberá modificar todas aquellas normas para incluirlo como otro delito sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La Defensora de la Niñez valora la inclusión de la norma, pero hace presente dificultades en la utilización de algunas expresiones, tales como “número considerable o indeterminado de personas”; la necesidad de centrarse en la conducta específica, la transmisión, y evaluar la posibilidad de incorporar la norma en el artículo 367 quáter.

La Ministra de Desarrollo Social y Familia expresa su conformidad con la incorporación de esta norma, como una manera de actualizar la legislación frente a las nuevas herramientas (tecnológicas) y nuevas modalidades de comisión de delitos. Concuera con las dificultades de determinar la magnitud de las personas según al inciso segundo.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos apunta a que, más allá de si es una producción o la mera transmisión de una situación, el daño para el niño, niña o adolescentes es igualmente grave; es un tipo penal distinto pero la pena debe ser la misma, por eso, en el inciso primero, la pena debiera ser presidio menor en su grado máximo. Asimismo, acogiendo las inquietudes, propone eliminar el inciso segundo.

Recogiendo el debate, la señora Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social hace llegar a la Secretaría una nueva propuesta de redacción:

“Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización, por parte de una persona menor de dieciocho años, de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.”

La redacción definitiva del artículo 367 septies queda pendiente.

Artículo 367 octies, nuevo:

- Indicación del Ejecutivo:

Informe de Comisión de Constitución

2) Para agregar, en el actual numeral 5), que pasó a ser 6), un artículo 367 septies, nuevo, a continuación del artículo 367 sexies, del siguiente tenor:

“Artículo 367 septies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

Sometida a votación la indicación N° 2 del Ejecutivo que incorpora un artículo 367 septies –que pasó a ser artículo 367 octies, nuevo- es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

Numerales nuevos

- Indicación del Ejecutivo:

3) Para intercalar un numeral 7), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 8), del siguiente tenor:

“7) Reemplázase en el encabezado del Párrafo VII, Título VII del Libro II, la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

El señor Ilabaca (Presidente) apunta que esta y una norma de orden.

Puesto en votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 3) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

4) Para intercalar un numeral 8), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 9), del siguiente tenor:

“8) Reemplázase en el artículo 368 inciso primero, la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

En votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 4) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

5) Para intercalar un numeral 9), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 10), del siguiente tenor:

“9) Reemplázase en el artículo 368 bis, la expresión “los párrafos 5 y 6” por “en los tres párrafos anteriores”.

- Indicación del diputado Marcos Ilabaca, al artículo 368 bis, para eliminar la expresión “de este Título”.

Puesto en votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 5) del Ejecutivo, con la indicación, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

6) Para intercalar un número 10), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 11), del siguiente tenor:

“10) Elimínase en el artículo 368 ter inciso primero, el número “366 quinquies” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

El señor Ilabaca (Presidente) informa que es una mera adecuación formal.

Sometido a votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 6) del Ejecutivo, es aprobado por la

Informe de Comisión de Constitución

unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

7) Para intercalar un numeral 11), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 12), del siguiente tenor:

“11) Reemplázase en el artículo 369, inciso cuarto, la expresión “en los párrafos 5 y 6”, por “en los tres párrafos anteriores”.

- Indicación del diputado Marcos Ilabaca, al artículo 369, inciso cuarto, para eliminar la expresión “de este Título”.

Puesto en votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 7) del Ejecutivo, con la indicación, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

8) Para intercalar un numeral 12), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 13), del siguiente tenor:

“12) Elimínase en el artículo 369 ter inciso primero, la expresión “366 quinquies” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.”.

Sometido a votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 8) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

9) Para intercalar un numeral 13), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 14), del siguiente tenor:

“13) Sustitúyese en el artículo 369 quinquies, el guarismo “366 quinquies” por “367 quater”.

Puesto en votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 9) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

10) Para intercalar un numeral 14), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 15), del siguiente tenor:

“14) Reemplázase en el artículo 371 inciso primero, la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

En votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 10) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

- Indicación del Ejecutivo:

11) Para intercalar un numeral 15), nuevo, pasando el actual numeral 6) a ser 16), del siguiente tenor:

“15) Reemplázase en el artículo 372 incisos segundo y tercero, el guarismo “366 quinquies” por “367 quater”.

Sometido a votación el numeral nuevo, contenido en la indicación N° 11) del Ejecutivo, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

Numeral 6)

Informe de Comisión de Constitución

6) Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos explica que los artículos 374 bis y 374 ter fueron subsumidos por los artículos 367 quáter y 367 quinquies, ya aprobados.

Puesto en votación el numeral 6) del proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados señores Marcos Illabaca (Presidente de la Comisión); Juan Antonio Coloma; Leonardo Soto, y Matías Walker. (4-0-0).

Artículos nuevos

- Indicación del Ejecutivo, ARTÍCULO SEGUNDO, NUEVO

12) Para intercalar un artículo segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:

“Artículo segundo.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos expresa que, conforme lo destacara el diputado Walker en la sesión anterior, esta modificación y las siguientes tienen como objetivo adecuar y dar coherencia a esta ley con las leyes N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, y N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

El abogado del Ministerio Público hace presente que en la ley N° 21.057 no bastaría con añadir el artículo 367 quáter, sino el párrafo VI bis nuevo, y habría que modificar también la ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas, particularmente, el artículo 15 bis, letra b), de libertad vigilada intensiva.

La Defensoría de la Niñez hace presente que el artículo 367 septies está pendiente de aprobación; en caso de aprobarse debe hacerse la adecuación también, aunque se subsana si se incorpora el párrafo completo.

La discusión y votación del artículo segundo nuevo (indicación N° 12 del Ejecutivo) queda pendiente.

Sesión N° 411 de 7 de diciembre de 2021.

El señor Secretario hace presente que, si bien corresponde iniciar la votación desde el Numeral 12) del proyecto, ha quedado pendiente la discusión y votación del artículo 367 septies propuesta por la mesa de trabajo que fuera liderada por el Subsecretario de Justicia, la de aprobarse traería como consecuencia la necesaria modificación del artículo primero N°1 del proyecto, respecto del artículo 94 bis del proyecto, por lo que propone iniciar con las materias pendientes, recibiendo el acuerdo del Presidente.

Artículo 367 septies, nuevo:

El Secretario de la Comisión informa que, la propuesta original de la mesa de trabajo, liderada por el Subsecretario de Justicia, proponía incorporar el siguiente artículo 367 septies, nuevo:

“Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una persona menor de dieciocho años, de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado con presidio menor en su grado medio.

Cuando dicha transmisión fuere a un número considerable o indeterminado de personas, la pena será de presidio menor en su grado máximo.”

Luego de las observaciones del Ministerio Público en la sesión N° 409 [4], existe una nueva propuesta de la mesa de trabajo, en orden a eliminar el inciso segundo y aumentar la penalidad a presidio menor en su grado máximo, en el siguiente sentido:

“Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización, por parte de una persona

Informe de Comisión de Constitución

menor de dieciocho años ,de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado con presidio menor en su grado máximo”.

El señor Maurizio Sovino, abogado de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público, observa que la redacción propuesta por la mesa de trabajo es compleja y puede causar problemas interpretativos. Lo anterior debido a que si lo que se busca es sancionar la transmisión de conductas sexualizadas por parte de una persona en la que se involucren a niños, niñas y adolescentes, la redacción propuesta por el Ministerio de Justicia no sería la más adecuada, porque se enfoca en la necesidad de que la transmisión se realice “a otra persona” que esté en una situación de observador, en circunstancias en que lo que importa es simplemente el acto de transmitir.

El Ministerio Público propone, como articulado simplificado, lo siguiente:

“Sanciónese a quien transmitiera a distancia, a través de cualquier medio electrónico, actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, de menores de dieciocho años”.

El señor Sovino expresa que la propuesta de redacción es la utilizada para conceptualizar el delito de almacenamiento o producción de material pornográfico, permitiendo ahorrar elementos de configuración del tipo que, en la práctica, son complejos.

El diputado Saffirio califica como atingente la observación y propuesta que hace el Ministerio Público, ya que el acto de subir a redes sociales acciones que tengan significación sexual de niños, niñas y adolescentes es el acto que se busca sancionar.

Agrega que, en el uso de redes sociales, lo que se “sube” es imposible de controlar y “bajar” para un ciudadano común, y no tiene un destinatario específico, causando daño por el sólo hecho de realizar la publicación. En otros términos, es apretar el gatillo, sin el control del curso de la bala.

El Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, inicia su exposición explicando el contexto del articulado. Al respecto, indica que fue a propósito de una solicitud realizada por el Ministerio Público, respecto de hacer notar que hay un vacío actual en la legislación y que dice relación con los casos en los que pueda haber una transmisión en vivo respecto de una conducta de significación sexual de menores de edad, lo que efectivamente no existe, llevándolos a ensayar una tipificación en un artículo nuevo, dando luego espacio a una discusión sobre la relevancia o no del número de destinatarios de ese material.

Siendo así, lo que se pretende subsanar con la propuesta del Ejecutivo es ese vacío normativo, y que como se dijo, tiene relación con una transmisión en directo.

Aclara que la figura de “subir” algo a redes sociales no calza con el artículo en discusión, sino con el artículo 367 quáter que ya fue aprobado y que habla sobre la difusión, distribución o exhibición de dicho material pornográfico, cualquiera sea su soporte. Ésta palabra final (soporte) es fundamental para el tipo, porque exige que dicho material se encuentre en un respaldo, lo que no pasa con las transmisiones en vivo, donde dicho material no queda registrado.

Por lo anterior, y a modo de ejemplo, lo que se busca sancionar con esta propuesta es la transmisión en vivo, vía zoom, de acciones de significación sexual de menores de edad. Es por lo mismo que en este artículo no se habla de “soporte”.

A la propuesta del Ministerio Público, el Subsecretario Valenzuela indica, en primer lugar, que al cambiar la redacción en los términos que han propuesto, pone a ésta nueva figura dentro del mismo tipo penal que el artículo 367 quáter. Por eso, a su parecer la propuesta del Ejecutivo es la más apropiada al fin perseguido, tipificándolo como un delito separado.

Informe de Comisión de Constitución

En un segundo lugar, a la observación del Ministerio Público en rechazo a la necesidad de incorporar en el tipo penal a un tercero receptor del material transmitido, y entendiendo que la propuesta que los fiscales realizaron directamente en conversaciones previas con el Ministerio de Justicia era modificarla por una transmisión a distancia, don Sebastián Valenzuela refiere que la esencia del tipo es que este material está llegando a un tercero destinatario y es un error concentrarse en el mecanismo o tecnología con la que se transmite. Es más, si la transmisión no llegase a nadie, y nadie eventualmente la vería, no se entendería cuál entonces sería el reproche de la conducta del tipo penal.

Por último, en materia de penalidad, entiende habría consenso en aumentarla a presidio menor en su grado máximo, considerando que la propuesta original era de presidio menor en su grado medio.

La diputada Jiles indica que el Ministerio Público ha manifestado su inconformidad con la propuesta del Ejecutivo, y considerando que son ellos los que persiguen el delito, deben tener más claro las modificaciones para configurar este tipo penal. En ese orden, ofrece a los representantes de dicha institución hacerle llegar el texto propuesto para suscribirla como indicación.

Don Maurizio Sovino (Ministerio Público), siendo emplazado por el diputado Saffirio a dar su opinión respecto de la exposición del Subsecretario de Justicia, indica que existe coincidencia en que el objetivo del artículo 367 septies es perseguir la transmisión en vivo de actos de significación sexual de menores de edad, pero reitera que la preocupación sigue latente al momento de exigir, para su configuración, que dicha transmisión sea para otra persona. Lo anterior, porque si se hace una comparación con el delito de distribución de material pornográfico, éste no señala a otra persona, siendo entonces un punto importante a la hora de la persecución del mismo el comprobar que dicha transmisión quede vinculada con el destinatario, ya que se puede prestar para la discusión de que la finalidad que tuvo la otra persona al llevar a cabo la conducta punible, no era que otra persona lo viera.

Siendo así, comparten con el Ministerio de Justicia dejar en la redacción el uso de los dispositivos técnicos y en lo que dice relación con las transmisiones a distancias, pero mantienen su observación respecto al destinatario.

Diputado Ilabaca (Presidente) establece como una propuesta, para llegar a un acuerdo en la indicación, mantener la redacción propuesta por el Ejecutivo, pero eliminado la frase “de otra persona”, en orden a evitar en la práctica una dificultad probatoria [5].

Consultado el Subsecretario de Justicia sobre la propuesta del diputado Ilabaca, refiere que puede ser factible dejar el tipo penal de ese modo, pero que, con todo, la jurisprudencia y doctrina exigirá, para el cumplimiento de la tipicidad, que esa transmisión llegue a un destinatario. Resultaría, a juicio de la autoridad de Gobierno, similar al delito de distribución de material pornográfico que, aunque si bien no se exige probar que llegó a otra persona, si se requiere que este destinado a ser conocido por un tercero, de lo contrario lo que habrá en la práctica será la configuración del artículo 161 A, relacionado con la intimidad y con la captación o interceptación de grabaciones personales, y que no exige la figura de un destinatario.

En este sentido, el diputado Ilabaca hace ingreso de la siguiente indicación:

- Indicación del diputado Ilabaca, al artículo 367 septies.

“Para eliminar del artículo 367 septies la frase “a otra persona y el vocablo “le”””.

- Indicación del diputado Soto, don Leonardo, al Artículo 367 septies.

Para trasladar la expresión “por parte de una persona menor de dieciocho años,” a continuación de los vocablos “significación sexual,”, eliminando la primera coma (,) de la expresión trasladada.

El diputado Soto, don Leonardo, fundamenta su indicación en el sentido de considerarlo una mejora, ya que su redacción original antepone a la víctima (los menores de edad) al acto de significación sexual, lo que considera

Informe de Comisión de Constitución

gramaticalmente incorrecto. Es así como, su propuesta, antepone la frase “una acción sexual o de una acción de significación sexual” a la frase “de un menor de dieciocho años”, quedando así de una forma continua la redacción de la conducta de la acción reprochada.

El diputado Alessandri comparte la indicación realizada, pero solicita poner el foco en el cuidado que se debe tener por parte del legislador en el buen uso de las palabras nuevas que dicen relación con redes sociales, como compartir, subir, transmitir. En este sentido, le llamo la atención las palabras del Subsecretario de Justicia al indicar que este tipo se aplicaba a una transición en vivo por Zoom, refiriéndose entonces a una plataforma de las decenas que existen hoy en día, lo que a su juicio es un error al encasillar el tipo penal al uso de una plataforma en particular, instando a mejorar la técnica legislativa.

Añade que el uso de conceptos como retwittear, aplicado a Twitter, o compartir como en Facebook e Instagram, pueden ser mal interpretados por la judicatura, la que para su interpretación recurrirá al uso corriente que se encuentra en los diccionarios y no comprenderá el sentido que el legislador le quiso otorgar.

Por lo anterior, deja abierta la pregunta al cómo usar de buena forma el lenguaje nuevo en relación a las redes sociales y no dejar abierta la posibilidad a interpretaciones erróneas.

El diputado Ilabaca (Presidente), refiere que el proyecto no se encasilla en una plataforma en particular, como tampoco utiliza conceptos como los enumerados por el diputado Alessandri, sino que se limita a indicar “el que usando dispositivos técnicos”. Siendo así, podrán crearse en el futuro diez formas o dispositivos de transmisión nuevas que igualmente quedarán comprendidas en el tipo penal.

En el mismo sentido, el concepto compartiere no corresponde a este articulado, sino al artículo 367 quáter, el que pena a quien comercializaré, importare, distribuyere, difundiere... siendo el compartir un acto de difusión.

La diputada Jiles solicita, en primer lugar, respeto por los turnos para intervenciones, ya que ha solicitado la palabra 4 veces antes que los demás intervinientes. En segundo lugar, expresa su queja respecto de la forma de trabajo, donde no se tiene a la vista la forma en la que queda el articulado que luego es puesto en votación, por lo que no tiene claro lo que se vota, pidiendo que se de lectura nuevamente a las indicaciones realizadas al artículo 367 septies.

El Secretario da lectura al texto del artículo 367 septies con las indicaciones presentadas, recordando que el objeto de la propuesta de la mesa de trabajo era aumentar la pena del tipo penal y suprimir el inciso segundo:

“Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.”.

El Ministerio Público, respecto de la propuesta final, observa que la expresión “le permitiere presenciar...” tenía sentido en la primera propuesta del Ejecutivo, en relación a la otra persona o tercero destinatario que ya fue eliminado, por tanto debería eliminarse la palabra “le”.

El Subsecretario de Justicia considera atingente la observación realizada, bastando entonces con la eliminación del pronombre “le”.

Sometido a votación, la propuesta de texto definitivo del artículo 367 septies, que considera las indicaciones de los diputados Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, junto con la eliminación del pronombre “le”, es aprobada por

Informe de Comisión de Constitución

unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Nuñez, doña Paulina), René Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y el Presidente don Marcos Ilabaca. (8-0-0) [6].

N° 1, Artículo 1°.

Considerando la aprobación del artículo 367 septies nuevo, se pone en votación la indicación de los diputados Ilabaca y Soto, don Leonardo, realizará al artículo 94 bis del N° 1 del artículo primero, con el objeto de incorporarlo dentro de las referencias, en el siguiente sentido:

- Indicación de los diputados Ilabaca y Soto (Leonardo), al numeral 1) del artículo primero, en el siguiente sentido: "Para incorporar en el artículo 94 bis, a continuación de la frase "367 quáter" y antes del punto y coma (;), lo siguiente "367 septies".

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Nuñez, doña Paulina), René Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y el Presidente don Marcos Ilabaca. (8-0-0) [7].

Nota: La secretaría deja constancia que se corregirá la redacción del N°1 del artículo primero, suprimiendo el artículo 366 quinquies (que el proyecto deroga) y agregando luego de "367 ter" las expresiones ",367 quáter, 367 septies", por ser la adecuada técnica legislativa.

Indicación N° 12, incorporación de un nuevo artículo segundo.

- Indicación del Ejecutivo, para intercalar un artículo segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:

"Artículo segundo.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, el guarismo "374 bis" por "367 quáter".

- Indicación, de los diputado(a)s Marco Ilabaca (presidente), Karol Cariola y Pamela Jiles, para sustituir el artículo segundo propuesto por el siguiente:

"12) Para intercalar un artículo segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:

"Artículo segundo.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

A) Sustituir la expresión: "en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo" por "en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo".

B) Eliminar el guarismo "374 bis".

Sometido a votación, la indicación N° 12 del Ejecutivo en conjunto con la indicación de los diputados Ilabaca, Cariola y Jiles, es aprobada por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0). [8]

N° 13, Artículo Tercero nuevo.

- Indicación del Ejecutivo, para intercalar un artículo tercero, nuevo, pasando el actual artículo segundo a ser cuarto, del siguiente tenor:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo tercero. - Reemplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Sometido a votación, la indicación 13° del Ejecutivo, es aprobada por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0). 98]

N° 14, Artículo Cuarto nuevo.

- Indicación 14° del Ejecutivo, para intercalar un artículo cuarto, nuevo, pasando el actual artículo segundo a ser quinto, del siguiente tenor:

“Artículo cuarto. - Sustitúyese en el artículo 4° de la ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por “367 quater”.

- Indicación del diputado Ilabaca (Presidente), al artículo cuarto, nuevo, en el siguiente sentido:

“Al Artículo Cuarto, nuevo, que sustituye el artículo 4° de la Ley N° 20.084, para agregar inmediatamente después de la frase “367 quater”, la siguiente: “, inciso segundo”.

Sometido a votación, indicación N° 14 en conjunto con la indicación del diputado Ilabaca, es aprobada por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0)[10]

Indicación, nuevo Artículo Quinto.

- Indicación del diputado Ilabaca (Presidente), para agregar un artículo quinto, nuevo, pasando el actual artículo segundo a ser sexto, del siguiente tenor:

“Artículo quinto. - Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216 que “Establece penas que indica como substitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, la referencia al artículo “366 quinquies”, y Agrégase a continuación del guarismo “367 ter”, el guarismo: “, 367 quater, inciso segundo,”.

El Ministro de Justicia, señor Larraín, indica que se trata de una indicación adecuatoria en el mismo sentido de las anteriores, con la diferencia de que cambia la ley a la que se realiza la adecuación, siendo el caso de la Ley N° 18.216 que establece las penas substitutivas, por lo que sugiere su aprobación.

Sometido a votación, la indicación del diputado Ilabaca, es aprobada por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0) [11].

Indicación nueva, del diputado Leonardo Soto.

- Indicación nueva del diputado Leonardo Soto, para agregar un nuevo artículo sexto, nuevo, pasando el actual artículo segundo a ser séptimo, en el siguiente sentido:

“Artículo sexto. - En el inciso tercero, del artículo 3° del decreto ley N° 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, reemplazase la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

El diputado Soto, don Leonardo, estima necesaria hacer la misma adecuación referencial al decreto ley N° 321 que establece los requisitos para la libertad condicional, y que se encuentra en el artículo tercero, inciso tercero de dicho cuerpo normativo. De esa forma, siendo todos delitos de connotación sexual, y estando en presencia de los denominados depredadores sexuales, a los cuales la ley dispone mayores exigencias para acceder a la libertad condicional, resulta necesario realizar allí las mismas adecuaciones referenciales.

Informe de Comisión de Constitución

El Subsecretario de Justicia manifiesta estar de acuerdo con la adecuación.

El diputado Saffirio comparte la propuesta, aunque aclara que no es adecuatoria en su esencia, ya que se está cambiando un requisito para acceder a la libertad condicional en estos casos, sin perjuicio de lo cual votará a favor.

Sometida a votación, la indicación del diputado Leonardo Soto, en orden a incorporar un nuevo artículo sexto que modifica el artículo 3°, inciso tercero, del Decreto Ley N° 321, es aprobada por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0) [12].

Artículo Segundo (original), que paso a ser artículo séptimo.

“Artículo segundo.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

El diputado Ilabaca (presidente), indica que este articulado fue revisado por la mesa de trabajo y existe acuerdo al respecto, sin observaciones.

Sometido a votación, el artículo segundo original, que paso a ser artículo séptimo, es aprobado por unanimidad de los presentes, diputado(a)s Jorge Alessandri, Karol Cariola, Pamela Jiles, Ximena Ossandón (en remplazo de la diputada Paulina Nuñez), Rene Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y Marlos Ilabaca (Presidente). (8-0-0) [13].

Fundamento del voto:

El diputado Saffirio refiere que la referencia que realiza el artículo a los principios de tipicidad e irretroactividad se encuentran demás, ya que son de aplicación general aunque no los mencionen. Sin perjuicio de ello vota a favor.

SE DESPACHA EL PROYECTO. Diputada informante, señora Camila Flores.

El Presidente Ilabaca agradece la colaboración del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez durante la tramitación del proyecto, el que refiere ser de gran relevancia para la protección real de los niños, niñas y adolescentes.

El diputado Walker solicita al Presidente Ilabaca tener a bien solicitar la unanimidad de los miembros de la comisión para incorporar su votación favorable a todas las votaciones realizadas durante la sesión. Así se acuerda por unanimidad

IV.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Concurrieron, en calidad de invitados, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández; la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar; el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela Agüero; la Jefa de División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés; la Subsecretaria de la Niñez,

Informe de Comisión de Constitución

señora Blanquita Honorato; la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz; la Directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz; la representante de la Mesa sobre Incidencia contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNA), señora Mónica Contreras; acompañada de la abogada de la Corporación Opción, señora Camila De La Maza.

V.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el (la) señor (a) diputado (a) informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo primero. - Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1) En el artículo 94 bis, suprímese la expresión "366 quinquies," e intercaláanse entre el guarismo "367 ter" y el punto y coma (;) que le sigue, las expresiones ",367 quáter, 367 septies"

2) Intercálase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis, nuevo:

"§ VI bis. Explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes."

3) Derógase el artículo 366 quinquies.

4) Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

"ART. 367.

El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución."."

5) Reemplázase en el artículo 367 ter las expresiones "a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro" y la coma (,) que las anteceden por los vocablos "obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución".

6) Intercálase los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies nuevos:

"ART. 367 quáter.

El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado

Informe de Comisión de Constitución

con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

ART. 367 quinquies.

Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

ART. 367 sexies.

Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

ART. 367 septies.

El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

ART. 367 octies.

Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

7) Reemplázase en el encabezado del Párrafo VII, del Título VII del Libro II, la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

8) Reemplázase en el artículo 368 inciso primero, la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

9) Reemplázase en el artículo 368 bis, la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

10) Elimínase en el artículo 368 ter inciso primero, el número “366 quinquies” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

11) Reemplázase en el artículo 369, inciso cuarto, la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título”, por “en los tres párrafos anteriores”.

12) Elimínase en el artículo 369 ter inciso primero, la expresión “366 quinquies” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

13) Sustitúyese en el artículo 369 quinquies, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

14) Reemplázase en el artículo 371 inciso primero, la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres

Informe de Comisión de Constitución

párrafos anteriores”.

15) Reemplázase en el artículo 372 incisos segundo y tercero, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”. En lo que respecta al inciso segundo eliminase también la coma (,) que sigue al mencionado guarismo “366 quinquies”.

16) Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo segundo.- Introdúcense en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, las siguientes modificaciones:

A) Sustitúyese la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

B) Suprímese el guarismo “374 bis;”.

Artículo tercero.- Remplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Artículo cuarto.- Sustitúyese en el artículo 4° de la ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter, inciso segundo,”.

Artículo quinto.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,” y agrégase a continuación del guarismo “367 ter”, el guarismo: “, 367 quáter inciso segundo,”.

Artículo sexto.- En el inciso tercero, del artículo 3° del decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, reemplázase la expresión “ 366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo séptimo.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 1 y 7 de diciembre, todas de 2021, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Marcos Illabaca (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. Asimismo asistió la señora Ximena Ossandón (por la señora Urrutia) y el señor Marcelo Díaz (por el señor Ibáñez).

Sala de la Comisión, a 7 de diciembre de 2021.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

Informe de Comisión de Constitución

[1] Boletines Refundidos N°s 13.588-07 11.915-07 12.668-07 y 12.776-07 que modifica diversos tipos penales con el objeto de mejorar la persecución penal del narcotráfico y crimen organizado en segundo trámite constitucional radicado en el Senado. En:

<https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14126&prmBOLETIN=13588-07>

[2] Al respecto la expositora ejemplificó que en la región metropolitana solo la comisaría N° 35 de Carabineros investiga los delitos de explotación sexual de niños niñas y adolescentes encontrándose sobrepasada por el volumen de causas y el escaso personal. Esta situación se replica en la PDI y en la brigada especial de cibercrimen.

[3] Al respecto la expositora manifiesta que en el caso del pololeo hay que tener en cuenta que las fotografías y envío de videos y otros medios ha pasado a ser parte de la actividad sexual y por tanto de no haber norma que los exima en este sentido los podría hacer caer en autores de este delito.

[4] Las observaciones del Ministerio Público al artículo 367 septies se encuentran en detalle en la página 13 del acta de la sesión N° 409 del 01 de diciembre del 2021 disponible en:

<https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1724>

[5] A modo ilustrativo con la propuesta del señor Presidente diputado Ilabaca quedaría de la siguiente manera: “Art. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar observar o escuchar la realización de una persona menor de dieciocho años de una acción sexual o de una acción de significación sexual será sancionado con presidio menor en su grado máximo”.

[6] Se hace presente que por acuerdo unánime tomado al término de la votación del boletín N° 14.440-07 se incorpora el voto favorable del diputado Matías Walker a todas las votaciones resultando la unanimidad por 8-0-0.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

Discusión en Sala

1.3. Discusión en Sala

Fecha 13 de diciembre, 2021. Diario de Sesión en Sesión 109. Legislatura 369. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

INTRODUCCIÓN DE NUEVO PÁRRAFO A CÓDIGO PENAL RELATIVO A PROXENETISMO, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 14440-07)

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, correspondiente al boletín N° 14440-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Camila Flores .

-Antecedentes:

-Mensaje, sesión 49ª de la presente legislatura, en jueves 24 de junio de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Camila Flores, rinde el informe el diputado Jorge Alessandri .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor ALESSANDRI (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados:

En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar el proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en avanzar en la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando afecte a niños, niñas o adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

En la fundamentación de motivos, el mensaje señala que con la presentación de este proyecto de ley se busca recoger las sugerencias que los diversos actores institucionales y de la sociedad civil han venido desarrollando durante los últimos 20 años y que se han plasmado en distintas iniciativas, siendo una de las más relevantes la generación de estrategias intersectoriales conocidas como Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescente.

A través de las referidas estrategias, se ha relevado que la explotación sexual comercial de niñas, niños y

Discusión en Sala

adolescentes es considerada una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos, ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niñas, niños y adolescentes, y en las comunidades. Esta práctica, con carácter delictivo, implica que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social de una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándoles a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales.

A la fecha, la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La forma en que se presenta este delito son los denominados delitos de favorecimiento de la prostitución infantil, la obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio.

Los respectivos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, favorecen la percepción y entendimiento erróneo de que las niñas, niños o adolescentes presentan algún nivel de voluntariedad para participar en la comisión de este delito. Esta noción niega o condiciona la calidad de víctima, al no considerar la situación de asimetría de poder que subyace entre una víctima y el o los victimarios.

El presente proyecto ha sido elaborado a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que asumirá la responsabilidad de generar las políticas públicas relacionadas con materias de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estuvo encargado técnicamente de la generación y seguimiento de los referidos marcos para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de los años 1999, 2012 y 2017, a través de los cuales se ha mantenido un diálogo constante y constructivo con representantes de la sociedad civil organizada de nuestro país y se ha contado con el apoyo técnico de instituciones y profesionales expertos en estas materias.

En cuanto al contenido del proyecto, se intercala un nuevo párrafo VI bis en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, diferenciándolo de los delitos de estupro y abusos sexuales propios e impropios. De esta forma se reconoce la particular fisonomía de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes respecto de los demás delitos sexuales.

La propuesta deroga los artículos 366 quinquies y 374 bis, refundiendo las figuras penales que contenían en un nuevo artículo 367 quáter. De esta manera esta nueva norma regula en forma adecuada los delitos de comercialización, difusión o exhibición de material pornográfico de esta naturaleza, como también aparte la producción de la misma.

En el artículo 367 se cambia la figura de proxenetismo desde la “prostitución” a la “explotación sexual” de una persona menor de dieciocho años. Como, a diferencia del término “prostitución”, el término “explotación sexual” no cuenta con un arraigo conceptual en materia penal, se establecen sus contornos precisos mediante una definición. Se define “explotación sexual” como la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución. Se agrega en el tipo calificado una descripción del reproche que atiende a la vulnerabilidad de la víctima. Asimismo, se eleva la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

En el artículo 367 ter se elimina la exigencia que el acceso sexual a un menor sea a cambio de dinero o prestaciones de cualquier naturaleza, estableciendo que puede ser a cambio de cualquier tipo de retribución.

Se agregan nuevos artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies. El 367 quáter ya fue comentado.

El artículo 367 quinquies dispone que las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

El artículo 367 sexies establece que estas normas especiales no serán aplicables si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por concepto de violación, estupro principalmente, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

El artículo tercero agrega a la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el 367 quáter, nuevo, que castiga al que comercializare, importare, exportare, distribuyere,

Discusión en Sala

difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho, como también al que participe en la producción del mismo.

Por su parte, el artículo quinto actualiza el artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, incorporando el ya mencionado artículo 367 quáter, inciso segundo (producción de este tipo de material pornográfico), de manera que para que el autor de este tipo de delitos tenga acceso a la libertad vigilada intensiva se requiere que la pena privativa o restrictiva de libertad que se impusiere fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de cinco años.

Finalmente el artículo séptimo incorpora una norma para resolver problemas de derecho intertemporal, entregando soluciones a problemas de *lex mitior* (aplicación retroactiva de norma favorable) y *ultraactividad* (aplicación de “ley derogada” para los hechos perpetrados durante su vigencia), y estableciendo la prohibición de *lex tertia* (formación de una “tercera ley” usando elementos favorables de la ley antigua y la ley nueva).

Habiendo aprobado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento este proyecto, es que este informante solicita su aprobación a esta honorable Sala.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Hernán Larraín .

La protección de los niños, niñas y adolescentes ha sido una preocupación creciente en los últimos años. A partir de los lamentables hechos ocurridos al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename), se han podido identificar miles de otras situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que van desde la violencia doméstica o intrafamiliar hasta casos en que los niños, niñas y adolescentes han perdido la vida con ocasión de delitos violentos, desapariciones y delitos sexuales de distinta índole.

Esto nos demuestra la necesidad de reforzar nuestra actual legislación en relación con mejorar la protección a favor de niños, niñas y adolescentes, y, a la vez, aumentar las sanciones contra quienes les causen daño, especialmente cuando este se produce a propósito de delitos de distinta índole.

En ese sentido, hace un tiempo propusimos restringir la aplicación de la libertad condicional a favor de los victimarios de menores, lo cual, con el pasar del trámite legislativo, fue lamentablemente rechazado.

Hemos intentado dar la debida protección a quienes son más vulnerables. Afortunadamente, el proyecto que ahora discutimos va en esa dirección.

No podemos ser ciegos ante la realidad de la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en el mundo y en Chile. Es una realidad poco visible, pero no por ello ausente.

Se estima que entre los años 2017 y 2019 los programas de protección especializada en explotación sexual comercial del Servicio Nacional de Menores atendieron un total de 4.286 casos, de los cuales el 90 por ciento eran mujeres y el 10 por ciento hombres, siendo la mayor parte de las afectadas adolescentes de catorce años o más.

Con este proyecto avanzamos a la tipificación de estos delitos, introduciendo un nuevo párrafo al Código Penal relativo al proxenetismo, a la explotación sexual comercial y a la pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Son delitos que afectan lo más delicado que tiene cada persona, especialmente quienes tienen menos edad, quienes comienzan a descubrir el mundo y a desarrollarse interpersonalmente. Son delitos que expresan la más grande crueldad que existe respecto de los niños, niñas y adolescentes, negando absolutamente su dignidad y derechos, tratándolos no como personas, sino como objetos dentro una actividad económica ilícita que solo traerá daños, tanto físicos como psicológicos, irreparables.

Discusión en Sala

Espero que la preocupación que tenemos por los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la explotación sexual no quede solo en la tipificación de nuevos delitos, sino que, como Estado, dispongamos de los recursos indispensables para perseguir estos delitos y, sobre todo, para reparar a quienes han sido víctimas de esos abusos.

No basta con que la justicia se reduzca a la imposición de una sanción cuando las víctimas aún no son reparadas en todo el daño que han sufrido, especialmente cuando se trata de víctimas de delitos sexuales. En esto tenemos mucho para avanzar y mejorar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aprobamos este proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , que se encuentra presente, y a todo su equipo, pues jugaron un rol muy importante en la elaboración de este proyecto de ley, así como también la defensora de los Derechos de la Niñez y la subsecretaria de la Niñez.

Este proyecto recoge las sugerencias de diversos actores institucionales y de la sociedad civil en pos de la generación de estrategias intersectoriales conocidas como Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, delito que se ha relevado por ser considerado como una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos, ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niños, niñas y adolescentes, y en las comunidades.

Esta práctica con carácter delictivo implica que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social de los niños, niñas y adolescentes, para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándoles a cambio un pago, a través de dinero, regalos, protección u otros elementos materiales o inmateriales.

En tal sentido, es un fenómeno social que se desarrolla bajo ciertas lógicas de poder por parte de personas adultas.

A la fecha, la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la forma en que se presenta este delito. Son los denominados delitos de “favorecimiento de la prostitución infantil”, o la “obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio”, entre otros. Los respectivos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, favorecen la errada percepción y entendimiento de que niños, niñas y adolescentes presentan algún nivel de “voluntariedad” para “participar” en la comisión de este delito. Esto queda subsanado con este proyecto.

Quiero valorar el esfuerzo que hizo la comisión en conjunto con el ministerio, la Defensoría de la Niñez, el gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, para entender que los tipos penales tienen que ser más altos. Y lo más importante -se acogió una sugerencia que hicimos en ese sentido es que se incorpora este delito dentro del catálogo de delitos imprescriptibles, de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, como se establece en una reciente legislación.

Por eso, invito a aprobar este proyecto ojalá por unanimidad.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

Discusión en Sala

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro de Justicia, señor Hernán Larraín, quiero agradecerle por promover y tramitar con prontitud esta iniciativa, que viene a complementar otros proyectos muy importantes del Congreso Nacional que van en la línea de la protección de la niñez, como son el fin del Sename y el establecimiento del sistema de garantías de los derechos de la niñez, que espero que prontamente deje el Congreso Nacional y sea promulgado como ley. Lamentablemente, producto de una verdadera leguleyada, la que fue corregida por el Tribunal Constitucional, el proyecto aún no se convierte en ley de la república.

Lo que se está haciendo a través de estas modificaciones legales es precisamente actualizar el Código Penal, que necesita ser renovado en su integridad. Tenemos un Código Penal del siglo XIX. En efecto, todavía ocupa conceptos tan errados como el de llamar “prostitución infantil” a la explotación infantil, a la explotación sexual de niños y niñas. Claramente, eso contraría todo tratado internacional y atenta y vulnera los derechos humanos de los menores, porque da la sensación de que hay una cierta voluntariedad en esa conducta, en circunstancias de que lo que hay detrás es el sometimiento de un menor de edad para realizar conductas contrarias a su voluntad y que vulneran su dignidad. Eso claramente tenía que ser corregido, incorporando el concepto de “explotación sexual” y eliminando el de “prostitución infantil”.

Además, se establecen mayores penas en el caso de que el ilícito se realice por dependencia personal o económica del niño, niña y adolescente, que es lo que muchas veces ocurre.

Precisamente por esas razones es que muchas veces hay casos en los cuales la denuncia ocurre muchos años después. Por eso fue tan importante que el Congreso Nacional aprobara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad.

Este es un paso muy importante, porque va a permitir al Ministerio Público investigar de mejor manera y tener mejores herramientas para que estos delitos, que vulneran los derechos más básicos de los menores de edad, tengan una efectiva condena y de esa manera podamos tener verdadera justicia para muchas familias que siguen esperando.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en esta Sala se suelen poner en debate proyectos que tienen distintas miradas y matices, que producen la división de todas las bancadas y que generan ácidos debates, en los que unos se enrostran a otros distintos tipos de actitudes. Hoy vamos a ver un proyecto que no produce ninguna división y que espero que logre la unanimidad de esta Sala.

Esta iniciativa tiene que ver con proteger la infancia vulnerada, con proteger a niños, niñas y adolescentes que están absolutamente desamparados, abandonados, muchas veces en el desamparo familiar, social y también sexual. Porque hoy vamos a tratar un proyecto de ley que reformula los delitos penales que combaten el proxenetismo, la explotación sexual comercial y la pornografía de niños, niñas y adolescentes.

La actual legislación penal trata la prostitución infantil como si fuera algo inevitable, un fenómeno social en el que las niñas o los niños, menores de catorce años o mayores de catorce años, pero menores de dieciocho años, se dedican prácticamente de manera voluntaria a la prostitución y participan de toda la industria comercial sexual que los explota, sin darse cuenta de que, de esa manera, se les niega una condición de víctima a niños, niñas y adolescentes.

Por eso este proyecto de ley, que tiene el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Justicia y de la Defensoría de la Niñez, actualiza la protección poniendo las cosas en su lugar, porque avanza en la protección penal de las víctimas -porque son víctimas de explotación sexual cuando se trata de menores de edad. Esta

Discusión en Sala

iniciativa surge con el apoyo de una mesa que durante mucho tiempo estableció el marco para la acción contra la explotación sexual infantil.

Nosotros creemos que este tipo de conductas, donde el adulto se aprovecha y abusa de una condición de poder, de dinero, pagando favores, es una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos y ocasiona las más devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niños, niñas y adolescentes. Por eso, hay que proscribirlos. Para ello establecemos tipos penales específicos. Establecemos un aumento de las sanciones y un mayor detalle en la persecución de todo tipo de conductas vinculadas a la explotación infantil. Y esta no es la única normativa al respecto, porque hace pocos meses aprobamos también algo que es fundamental: la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, para que no prescriban nunca, porque tenemos que dar una guerra frontal contra la explotación infantil, de todo tipo, de niños, niñas y adolescentes.

Invito a aprobar el proyecto, porque va en esa línea.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, existen pocas conductas tan bajas como esta sobre la cual estamos hablando hoy, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Entre las cosas más crueles que pueden darse está aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de un niño o adolescente, porque cuando un niño o un adolescente están en proceso de desarrollo, independientemente de su condición económica, son vulnerables frente a la vida y frente a todos estos hechos. Pero lo más grave de todo esto es hacer negocio con la dignidad, porque lo que está en juego, finalmente, es la dignidad de esos niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales ni siquiera saben lo que están haciendo.

Acabamos de salir de una comisión investigadora, que está en curso todavía, respecto de este tema, en la cual hemos escuchado a muchas instituciones que nos han ido iluminando sobre cómo esta problemática ha ido cambiando en el último tiempo. De acuerdo con sus relatos, hemos descubierto que el grave problema que existía hace poco tiempo era combatir, por ejemplo, la droga dentro de las instituciones; pero ellos mismos nos han señalado cómo esta problemática ha ido cambiando y hoy el tema de la explotación sexual es lo que más les preocupa. Por tanto, la mayor necesidad que hoy tienen es saber enfrentar esa problemática. Porque muchas veces los niños, niñas y adolescentes toman ese camino como una forma de sobrevivir, como una forma de ser aceptados y como una forma de conseguir plata fácil. Conocimos instituciones que no saben bien cómo reaccionar frente a esa situación.

También nos demostraron que, dependiendo de la comuna, existen redes que cuesta mucho que funcionen y existe muchísima improvisación. Estas instituciones claman por capacitaciones para saber cómo poder detectar esta situación.

En mi opinión, la explotación sexual es una grave vulneración que, sin lugar a dudas, marca la vida de quienes la sufren.

Este proyecto introduce en el Código Penal las figuras penales del proxenetismo, de la explotación sexual comercial y la pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Reconozco que en nuestro gobierno, el de Sebastián Piñera , se ha tomado el tema muy seriamente.

Es importante agradecer al ministro Hernán Larraín , a la Defensora de la Niñez y a todas las instituciones que han iluminado este y los otros cambios que se han realizado en pro de los niños, niñas y adolescentes en el último tiempo.

Discusión en Sala

La imprescriptibilidad, la división del Sename en dos servicios y este avance en materia penal son los temas que nos unen, transversales y que nos preocupan a todos los que estamos aquí.

Por las razones señaladas, esperamos que este proyecto se sea aprobado en forma transversal, porque el problema del que busca hacerse cargo no debe seguir existiendo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín .

El señor LARRAÍN (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, quiero saludar y agradecer el interés de los integrantes de esta Corporación, diputados y diputadas, por esta iniciativa, que efectivamente configura una de las líneas de trabajo que ha impulsado nuestro gobierno en conjunto con parlamentarios de los más variados sectores y con organizaciones de la sociedad civil que ven la necesidad de proteger la libertad y indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes como prioridad radical.

El eje de este proyecto, tal como se ha señalado, es visibilizar el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, haciéndose cargo de un problema que, lamentablemente, ha venido creciendo en el último tiempo y que se constituye como una de las más graves vulneraciones que pueden tener personas menores de 18 años de edad. Dicha vulneración es algo que violenta, de manera que la reacción que hay que tener debe ser equivalente a esa irritación que produce que se cometan estos actos.

Como lo señaló la diputada Ximena Ossandón al referirse a la comisión que está investigando la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, hemos tenido la percepción de que se trata de un fenómeno que ha crecido en los últimos años, con casos aislados y en distintos lugares, pero con características muy similares de personas que por razones de drogas u otras fueron presas de redes autónomas, distintas unas de otras, pero con el mismo propósito: la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Es por lo anterior que se están desarrollando numerosas acciones complementarias: hemos conversado con el Ministerio Público, con el fiscal regional de Valparaíso, con el de Santiago y de otros lugares con el propósito de atacar los puntos centrales donde esto se producía.

Como vimos que esto era una cuestión mucho más generalizada, en un trabajo efectuado en conjunto con el Ministerio Público, llevado a cabo por una comisión durante algunos meses, firmamos un convenio para fortalecer las investigaciones que en este campo se dan con el programa Mi Abogado, que tiene hoy la representación jurídica en todo Chile de niños, niñas y adolescentes que están bajo cuidado residencial, organismos que recibieron los programas de representación jurídica del Sename que se terminaron, y que están apoyando estas actuaciones. Vemos que los casos no avanzaban, situación de impunidad que queremos revertir.

Ustedes también conocen el Marco para la Acción contra la Explotación Sexual, que es una iniciativa que viene desde hace unos veinte años. Este marco, que reúne iniciativas de distintos ámbitos, ahora fue traspasado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto con el Servicio Mejor Niñez, y ha estado proponiendo una serie de iniciativas y actuaciones, siendo esta una de ellas, para lograr que esto tenga una mirada distinta.

Se han señalado algunos hechos, pero parte de la agenda legislativa que el gobierno ha tenido en este campo ha sido fortalecer este tipo de conductas. En esa línea, presentamos el proyecto que establece el fortalecimiento del registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de 18 años de edad. Esa iniciativa, que fue despachada la semana pasada por el Senado -la Cámara lo había hecho mucho antes-, se encuentra en estos momentos en el Tribunal Constitucional, pero esperamos que muy pronto sea ley de la república.

Está también el proyecto que excluye del beneficio de rebaja de condena a quienes hayan atentado contra la indemnidad sexual de menores de 18 años de edad. Esa iniciativa fue aprobada por esta Corporación y mañana se ve en particular en la Comisión de Constitución del Senado, que ya la aprobó en general, y esperamos que también

Discusión en Sala

sea pronto ley de la república. Adicionalmente, se recordaba esa ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales que nosotros reactivamos, a la que le pusimos urgencia e hicimos indicación sustitutiva y que es ley de la república, marcando un eje de trabajo muy significativo.

Respecto de este proyecto en particular, voy rápidamente a describir los aspectos principales de esta iniciativa.

Se trata de incorporar un párrafo nuevo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes.

La idea es separar dentro de los abusos sexuales este capítulo especial, porque tiene una significación relevante para poder visibilizar, en lo más sustantivo, esta figura, que hoy día, bajo la denominación o tipificación de prostitución infantil, esconde una realidad.

La idea de la prostitución pareciera suponer o sugerir alguna suerte de voluntariedad. Lo cierto es que no hay voluntariedad en una situación de significación sexual con niños, niñas y adolescentes. No existe y se borra esa diferencia incluso para los mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, porque creemos que ahí radica la clave del asunto.

La protección de nuestros y nuestras adolescentes pasa precisamente por extender este rango, este margen, y no solo visibilizarlo en el delito por lo que es -una explotación sexual que adultos cometen para beneficio propio, con algún tipo de retribución, que va en su provecho o en el de terceros y terminar con esa explotación que realmente produce daño físico, psíquico y social muchas veces difíciles de reparar en niños, niñas y adolescentes que son objeto de esta vulneración.

Ese tipo penal, por indicación y sugerencia de la comisión, ha incorporado un incremento en su penalidad. La base de la figura, que es actualmente presidio menor en su grado máximo, pasa a presidio mayor en su grado mínimo, como piso, lo cual supone que quien sea condenado por esto está expuesto a presidio efectivo.

Esta es una línea central: la de la explotación sexual comercial; la otra línea que reordena, reestructura y fortalece este proyecto es la que dice relación con la pornografía en sus distintas modalidades cuando se pretende producir, distribuir, comercializar, por cualquier tipo de medio, pornografía que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes.

Por lo tanto, sobre esa base se produce un avance en la tipificación, en el ordenamiento y en la modernización de este tipo penal que obviamente es, por el desarrollo de la tecnología y por el acceso que hay a las redes sociales, un camino, una vía muy potente para producir la incitación a actos de temprana edad en el ámbito sexual, con grave perjuicio para niños, niñas y adolescentes.

Creo que el trabajo que se hizo en la comisión con sus integrantes, con personas de la sociedad civil que cooperaron, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha sido muy importante.

En particular, dentro de ese proyecto, también se han incorporado normas adecuatorias que fueron sugeridas por miembros de la comisión, entre ellos el diputado Matías Walker y el diputado Leonardo Soto, quienes sugirieron la conveniencia, a pesar de que se podía pensar subentendida, de adecuar nuestros proyectos, nuestras normas, con otras que ya estaban dictadas.

Así, el proyecto, aparte de esos dos cambios -por un lado, tipificar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, dejando de lado la prostitución infantil, y, por el otro, reordenar, clarificar y sancionar con dureza la pornografía infantil en cualquiera de sus formas-, establece normas adecuatorias para asegurar la incorporación de estos tipos penales en la ley N° 20.084, que establece la responsabilidad penal de los adolescentes; la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en videos y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales; la ley N° 21.160, que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad; la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, régimen modificado recientemente y que también necesitaba incorporarse a la legislación vigente para tener una debida coherencia entre todo este conjunto de normas que se refieren a estas materias, y este nuevo proyecto.

Esta iniciativa produce un impacto muy profundo en el ámbito de la libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y

Discusión en Sala

adolescentes. Se trata de una norma simple, sencilla, pero de efectos muy profundos, y junto con las demás medidas que se están adoptando y con este marco que se ha desarrollado, que genera una red de actividades en los ámbitos público y privado para combatir la explotación sexual, y el esfuerzo del Ministerio Público -esperamos que dicho esfuerzo sea más efectivo y los trabajos que hoy se realizan en distintos ámbitos de la sociedad civil, creo que deberíamos empezar a tener mejores resultados en el combate contra este flagelo, porque en verdad constituye una vergüenza y un escándalo social que el abuso, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes haya proliferado a nuestra vista y paciencia como sociedad.

Por tanto, es tiempo de hacer un cambio radical en la materia, y este proyecto es un paso más en esa dirección.

Por eso, agradezco el apoyo que ha tenido la iniciativa en el Congreso, y esperamos que así siga, para que se convierta en ley lo más pronto posible.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son uno de los tipos penales más deleznable, no tan solo por los efectos que generan en las víctimas, sino además porque nos ponen a todos los ciudadanos y las ciudadanas en una alerta permanente.

En Chile, la situación es gravísima, y durante el último tiempo ha ido en alza. Solo en el primer semestre de este año se habla de 691 víctimas de delitos sexuales, que en su mayoría oscilan entre los 0 y los 13 años de edad. Además, el 85 por ciento de ellas son mujeres. O sea, esta es una realidad que afecta principalmente a niñas de entre 0 y 13 años, niñas que debieran ser la máxima preocupación de un Estado, niñas a las que no se les debiera robar su inocencia, transgrediendo uno de los derechos más importantes, cual es el de la indemnidad sexual.

Este proyecto dignifica mucho la labor del Congreso, por la forma en que se tramitó: de manera transversal y escuchando a los expertos. Iniciativas de este tipo dignifican nuestra función.

Actualizar los tipos penales es una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo. De hecho, cada vez que discutimos sobre un delito, yo digo que lo que necesitamos es hacer una reforma estructural a nuestro Código Penal completo. Pero, bueno, eso se ha demorado más de la cuenta, y, al menos en el ámbito de los delitos sexuales, en esta legislatura hemos avanzado bastante en modificar varias normas, además del trabajo que se ha venido haciendo en los períodos anteriores respecto de las entrevistas videograbadas. También logramos avanzar en la imprescriptibilidad. Y ahora este proyecto, sin duda, es un avance significativo, puesto que para el delito de explotación sexual con fines de comercialización establece penas que superan los cinco años y un día, lo que implica además que lo más probable es que se trate de penas que se deban cumplir de manera efectiva.

Por lo expuesto, anuncio que vamos a apoyar la iniciativa en discusión. Pero no quiero dejar de decir que una de las maneras de evitar precisamente la proliferación de este tipo de delitos es enseñando a niños, niñas y adolescentes, desde muy pequeños, cuáles son los límites corporales, el respeto y el amor por su propio cuerpo, lo que se logra estableciendo políticas públicas acordes con una educación sexual integral y efectiva.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

Discusión en Sala

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, valoro significativamente este proyecto, iniciado en mensaje, que permitirá visibilizar y proteger de mejor forma a niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, ya que hasta la fecha nuestro sistema penal presenta grandes dificultades para investigar y sancionar esas prácticas debido a la falta de una apropiada conceptualización en el ámbito penal, así como también por las dificultades en el modo investigativo que hasta ahora han venido aplicando el Ministerio Público y las policías, lo que ha derivado en que el éxito de las actuaciones pase a depender de la voluntad del ente persecutor.

Si bien así lo señalé valoro significativamente esta iniciativa, creo que también deberíamos estudiar su ampliación a otras acciones que permitan hacerse cargo del fenómeno de manera más integral, incluyendo un cambio sustantivo en las policías, en la política cultural de los fiscales y en las demás entidades judiciales, ya que sin esto no se podrá avanzar realmente en las investigaciones del caso, quitando el peso que hoy recae en las víctimas. Es decir, la carga de la prueba debería estar en los victimarios y no en las víctimas. En consecuencia, es preciso establecer claramente la tipificación objetiva del delito, independiente de la actitud subjetiva de las víctimas.

Es efectivo que nuestro Código Penal se refiere a un concepto que se debe erradicar, ya que habla de prostitución infantil, lo que denota una suerte de voluntariedad de las víctimas en la comisión de una acción que, evidentemente, es delictiva y que redundaría en una agresión manifiesta desde el punto de vista de los derechos humanos de quienes son víctimas y menores de edad, quienes difícilmente pueden defenderse, ya que, además, este tipo de delitos generalmente se comete en un contexto de subordinación de las víctimas frente a sus agresores, que para aquellas es difícil de superar.

Atendido lo anterior, manifiesto mi apoyo a este proyecto. Espero que podamos avanzar lo más rápido posible en su aprobación, pues viene a modificar nuestro Código Penal en pro de la protección y la defensa a nuestros niños.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal relativo al proxenetismo, a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, de cuyo tema llama la atención en su génesis, por cuanto en nuestro país es muy curioso que el actual código sea ambiguo respecto de lo que significa la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Este proyecto, que busca la generación de estrategias intersectoriales conocidas como el marco para la acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, debe ser relevado por considerarse este tipo de ilícitos una de las más graves vulneraciones a los derechos fundamentales de personas que están iniciándose en su vida y que, al ser víctimas de esta clase de delitos, queda en ellas una huella demasiado profunda y permanente en su integridad física, psíquica y social; incluso, no solo de la persona abusada o agredida, sino en su propia comunidad.

Esta práctica delictiva implica que una persona adulta abuse de la condición de vulnerabilidad de un niño o de una niña, sea esta social, etaria, emocional o de género, entre otras. Esa persona adulta lo que hace es ejercer su poder para abusar de un menor de edad que, en muchos casos, no tiene discernimiento para entender lo que está pasando. El daño que se le produce deja una huella imborrable en su persona.

A la fecha, como ya sabemos, la legislación chilena no contempla una tipificación para la explotación sexual de menores. La forma en que se presenta es muy curiosa, porque aparece como la obtención de servicios sexuales de menores de edad o el favorecimiento impropio.

¡Qué sutileza del idioma! Con esa frase se esconde la brutalidad del delito cometido por una bestia que se aprovecha de la vulnerabilidad de un menor de edad.

Discusión en Sala

Me alegro de que estemos avanzando en nuestra legislación para establecer penas ejemplarizadoras, con el fin de que nunca más un adulto abuse de un menor de edad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, a la fecha, la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La forma en que se presenta este delito son los denominados delitos de “favorecimiento de la prostitución infantil”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 367 del Código Penal, o la “obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio”, que señala el artículo 367 ter del mismo Código.

El proyecto que estamos debatiendo crea un título especial sobre la materia en el Código Penal, diferenciando estos delitos de aquellos como los de abuso sexual, estupro y otros.

Desde el año 2017 han aumentado considerablemente las cifras de explotación sexual infantil en Chile. Según datos del Ministerio Público, las denuncias por explotación sexual infantil en Chile se incrementaron en los últimos dos años, ya que en 2017 se reportaron 171 delitos de este tipo, mientras que al año siguiente, 2018, el número llegó a 203 casos, tanto por promover o facilitar la prostitución infantil como por la obtención de servicios sexuales de menores. En tanto, solo en enero de 2019 por este tipo de delitos se suman 95 denuncias.

Este aumento tiene diversas causas, entre ellas, la falta de normativas efectivas y eficaces que protejan a los menores en el país. Así lo ha señalado la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (AChNU), organización que resguarda los derechos de los niños y jóvenes, indicando que las razones pueden ser el aumento de la pobreza, la falta de oportunidades y, llanamente, el incremento de los explotadores sexuales infantiles, que primero seducen y luego explotan.

Además, esto responde a un tema estructural, pues los niños y niñas no cuentan en Chile con una ley de protección integral de derechos o de garantías que les aseguren protección y prevenga vulneraciones. Es en ese contexto que se ha vuelto una prioridad proteger los derechos de los niños frente a esta cruda realidad, más aún considerando que la explotación sexual de los niños es una forma de esclavitud y, por esta razón, no se puede hablar de prostitución infantil, ya que la prostitución, por definición, es un acto voluntario, situación absolutamente distinta a la de los niños que se ven forzados u obligados por distintos medios coercitivos al comercio sexual.

En ese sentido, es imperioso comprender qué es exactamente la explotación sexual comercial de niños. Por eso, votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Valoro este proyecto, iniciado por un mensaje presidencial, que contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su objetivo es modificar, una vez más, el Código Penal, para incluir un nuevo párrafo en el Título VII del Libro Segundo, relativo al proxenetismo, la explotación sexual comercial y la pornografía de menores de edad. De acuerdo al mensaje, en el texto se recogen

Discusión en Sala

las sugerencias hechas en los últimos años por diversos actores de la sociedad civil.

Además de reordenar y revisar la redacción de las normas existentes, el proyecto incorpora una definición más precisa de lo que debe entenderse por pornografía infantil y separa en un párrafo nuevo los delitos relativos a la explotación sexual y pornografía infantil, una realidad tremendamente dolorosa, con el fin de diferenciarlos de otros con mayor claridad, aunque manteniendo sanciones similares.

Dentro de las novedades del proyecto, se reemplaza el concepto de “prostitución infantil” por el de “explotación sexual”, que es más amplio, y se agrega la situación derivada de la vulnerabilidad de la víctima por dependencia emocional o económica. También es importante, a la luz de la experiencia, la eliminación del piso de catorce años para este tipo de delitos, manteniéndose como criterio solo que la víctima sea menor de dieciocho años de edad.

La verdad es que, a la luz de las cifras respecto de este grave flagelo en nuestra sociedad, que se ha visto impulsado por las nuevas tecnologías que sirven para divulgar este tipo de delitos, uno hubiera esperado al menos un endurecimiento de las condenas, porque junto con la incitación al consumo de drogas en los menores, la explotación sexual, en sus distintas formas, es uno de los delitos que más daño provoca en nuestra infancia y juventud. De manera tal que valoramos este proyecto de ley.

No obstante lo anterior, y aprovechando la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, creo necesario señalar que no debemos seguir remendando o enmendando el Código Penal, sino definitivamente tener uno nuevo, como fue la idea del Presidente Frei Ruiz-Tagle, en cuyo gobierno se inició un proceso de conversaciones entre especialistas para redactar un nuevo Código Penal.

Eso es lo que hoy necesitamos, pues han aparecido nuevos delitos, como los denominados ciberdelitos, que hacen necesario contar con un nuevo Código Penal.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

Cabe hacer presente que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 114 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita Flores García, Iván Mellado Suazo, Miguel Rosas Barrientos, Patricio Alessandri Vergara, Jorge Fuenzalida Cobo, Juan Meza Moncada, Fernando Rubio Escobar, Patricia Alinco Bustos, René Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Mirosevic Verdugo, Vlado Saavedra Chandía, Gastón Álvarez Ramírez, Sebastián Gahona Salazar, Sergio Moraga Mamani, Rubén Sabag Villalobos, Jorge Álvarez Vera, Jenny Galleguillos Castillo, Ramón

Discusión en Sala

Morales Muñoz , Celso Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra González Gatica , Félix Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Hernández Hernández , Javier Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías , Iván Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irrarrázabal , Ximena Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Tohá González , Jaime Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González , Juan Luis Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos , Juan Antonio Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Urrutia Soto , Osvaldo Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rathgeb Schifferli , Jorge Vallejo Dowling , Camila Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación.

Se despacha el proyecto al Senado.

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 13 de diciembre, 2021. Oficio en Sesión 104. Legislatura 369.

VALPARAÍSO, 13 de diciembre de 2021

Oficio N° 17.108

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, correspondiente al boletín N° 14.440-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,” e intercálase, entre el guarismo “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “;367 quáter, 367 septies”

2. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis:

“§ VI bis. Explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.”.

3. Derógase el artículo 366 quinquies.

4 Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

“ART. 367.

El que promoviére o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.”.

5. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuviere la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución”.

6. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“ART. 367 quáter.

El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

ART. 367 quinquies.

Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

ART. 367 sexies.

Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

ART. 367 septies.

El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

ART. 367 octies.

Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

7. Reemplázase en el encabezado del Párrafo VII del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

8. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

9. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

10. Elimínase en el inciso primero del artículo 368 ter la expresión “366 quinquies,”, y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

11. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

12. Elimínase en el inciso primero del artículo 369 ter la expresión “366 quinquies,”, y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

13. Sustitúyese en el artículo 369 quinquies el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

14. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

15. Reemplázase en el artículo 372 incisos segundo y tercero el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

16. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Artículo 2.- Introdúcense en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

2. Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Reemplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por la expresión “367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,” y agrégase, a continuación del guarismo “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Dios guarde a V.E.

RODRIGO GONZÁLEZ TORRES

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 22 de abril, 2022. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 14. Legislatura 370.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

BOLETÍN N° 14.440-07.

Objetivo / Constancias / Asistencia / Antecedentes / Aspectos centrales del Debate / Discusión en General / Votación idea de legislar / Texto del proyecto de ley / Acordado / Resumen Ejecutivo / Índice

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar, en general, acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, y para cuyo despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de “simple”.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 14 de diciembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes (4x0).

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando sean niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

ASISTENCIA

Concurrieron en forma presencial y telemática a la sesión que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, los siguientes personeros:

- La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, acompañada por la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres, y la Jefa de Comunicaciones, señora Alejandra Lazo.
- La Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, en compañía de la profesional de la Unidad de Estudios, señora Emilia Rivas.
- El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Guillermo Briceño.

Informe de Comisión de Constitución

- Los asesores parlamentarios señoras Alejandra Fischer y Ximena Gutiérrez y señores Roberto Godoy, Felipe Hübner, Pedro Lezaeta y Héctor Mery.

- - -

ANTECEDENTES

I) Normativos.

a.- Código Penal.

b.- Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

c.- Ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

d.- Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

e.- Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

f.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

II) De hecho.

1.- Mensaje.

Al fundar esta iniciativa de ley, el Mensaje hace presente que la legislación nacional en materia de delitos sexuales ha experimentado importantes reformas destinadas a la adecuada persecución penal de estas conductas, las que han permitido proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes. Destaca, enseguida, que mediante la ley N° 21.160 se declararon imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, modificándose el Código Penal para establecer que la acción penal respecto de ciertos crímenes y delitos no prescribirá cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad. Según el Ejecutivo, esta modificación permite, por una parte, que las víctimas acudan a la justicia sin la amenaza del vencimiento de periodos preestablecidos y, por otra, interponer acciones reparatorias contra quienes resulten responsables, incluidos terceros que no hayan impedido el delito.

Explica el Ejecutivo que las distintas iniciativas en la materia, unidas a la agenda de reforma de la institucionalidad de atención a la niñez y adolescencia, son referentes para nuevos avances en materia legislativa y armonizan con el proyecto de ley en estudio, con miras a reforzar la protección penal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Así, se busca recoger las sugerencias que actores institucionales y de la sociedad civil han expresado en los últimos años y que se han plasmado en distintas iniciativas, tales como las estrategias intersectoriales conocidas como “Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”, que dan cuenta que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos, pues daña su integridad física, psíquica y social. Con esta práctica delictiva, arguye el Mensaje, una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social (etaria, emocional, de género, entre otras) de una niña, niño o adolescente, para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándole a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales.

El Mensaje advierte que actualmente la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La forma en que se presenta este delito es a través de figuras como el “favorecimiento de la prostitución infantil” (artículo 367 del Código Penal), o la “obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio” (artículo 367 ter del Código Penal), entre otras. Sin embargo, añade, los respectivos tipos penales, y particularmente las referencias a la prostitución, inducen a la percepción de que las niñas, niños y adolescentes manifiestan algún nivel de “voluntariedad” para “participar” en la comisión de este delito. Lo anterior, puntualiza, niega o condiciona la calidad de víctima, toda vez que no atiende a la situación de asimetría de poder que subyace entre una víctima y el o los victimarios. Esta forma de referirse a la explotación

Informe de Comisión de Constitución

sexual se encuentra arraigada en nuestra cultura, lo que se expresaría en las propias víctimas, quienes no necesariamente interiorizan la condición de explotación en la que se hallan al mediar intercambios con los explotadores como estrategia de sobrevivencia.

Al finalizar, el Mensaje comenta que el proyecto de ley fue elaborado a partir de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Justicia y Derechos Humanos. El primero, asumió la responsabilidad de generar las políticas públicas relacionadas con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; el segundo, se encargó técnicamente de la generación y seguimiento de los Marcos para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de los años 1999, 2012 y 2017, por medio de los cuales se ha mantenido un diálogo constante y constructivo con representantes de la sociedad civil.

2.- Estructura y contenido del proyecto.

La iniciativa que ha ocupado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que fuera acordada en primer trámite constitucional por la Honorable Cámara de Diputados, consta de siete artículos.

Su artículo 1, compuesto de dieciséis numerales, incorpora modificaciones en el Código Penal, como se reseña:

1. Suprime, en el artículo 94 bis, la expresión “366 quinquies,” e intercala, entre el guarismo “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “, 367 quáter, 367 septies”

2. Incorpora, a continuación del artículo 366 quáter, un párrafo VI bis, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

3. Deroga el artículo 366 quinquies.

4. Sustituye el artículo 367, para sancionar con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años. Añade que, si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales. La norma, además, entiende por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.

5. Reemplaza, en el artículo 367 ter, el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la frase “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución”.

6. Incorpora nuevos artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies.

- El artículo 367 quáter, sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo al que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años. Con la misma pena sanciona al que participare en la producción de dicho material pornográfico. Asimismo, castiga con presidio menor en su grado medio al que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

Para tales efectos, entiende por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

- El artículo 367 quinquies, considera cometidas en Chile las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

- El artículo 367 sexies, declara no aplicable este nuevo párrafo si el hecho fuere constitutivo de un delito

Informe de Comisión de Constitución

sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

- El artículo 367 septies, sanciona con presidio menor en su grado máximo al que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años.

- El artículo 367 octies, precisa que para determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12 en esta clase de delitos, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.

7. Reemplaza en el encabezado del Párrafo VII del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

8. Reemplaza en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

9. Reemplaza en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

10. Elimina en el inciso primero del artículo 368 ter la expresión “366 quinquies,” y sustituye el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

11. Reemplaza en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

12. Elimina en el inciso primero del artículo 369 ter la expresión “366 quinquies,” y sustituye el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

13. Sustituye en el artículo 369 quinquies el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

14. Reemplaza en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

15. Reemplaza en el artículo 372 incisos segundo y tercero el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

16. Deroga los artículos 374 bis y 374 ter.

El artículo 2, mediante dos numerales, introduce modificaciones de referencia legislativa en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

El artículo 3, reemplaza en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

El artículo 4, sustituye en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter inciso segundo,”.

El artículo 5, elimina en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,” y agrega, a continuación del guarismo “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo,”.

El artículo 6, reemplaza en el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

El artículo 7, regula diversos efectos de la ley en el tiempo. Así, los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer

Informe de Comisión de Constitución

por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Precisa, también, que si la ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realice íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Si la aplicación de esta ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella. Para determinar si la aplicación resulta más favorable se deberán considerar todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Concluye la norma indicando que, para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 7, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

- Tipificación apropiada de la explotación sexual de NNA.
- Tratamiento en un párrafo dedicado sólo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de NNA.
- Inclusión de técnicas especiales de investigación.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL [1]

Al comenzar el estudio de este proyecto de ley, hizo uso de la palabra la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Con ocasión de su exposición, la señora Ministra resaltó la importancia de la iniciativa, en la medida que se hace cargo de un problema que no estaría regulado de forma adecuada en la normativa penal vigente, e hizo presente que es el resultado de un trabajo conjunto con la Defensoría de la Niñez y con el Ministerio Público. En ese marco, prosiguió, el proyecto combate un modo de violencia cometida contra niños niñas y adolescentes (NNA) que se expresa en la explotación sexual a que son sometidos, y que constituye una vulneración grave de sus derechos humanos y una coerción equiparable al trabajo forzoso (en este sentido, precisó, es una forma contemporánea de esclavitud).

Según la personera de gobierno, la legislación nacional no tipifica apropiadamente la explotación sexual de NNA, toda vez que sólo sanciona penalmente el favorecimiento de la prostitución infantil y la obtención de servicios sexuales de menores de edad. En esa línea, acotó, el proyecto intenta superar el concepto de prostitución infantil, que promueve la percepción errónea de que el niño manifiesta algún nivel de voluntad en la perpetración de estos graves hechos. Aquí se trata de un delito frecuente en nuestra sociedad y que afecta principalmente a las niñas. Así, desde el año 2014 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado (a través del Programa Mi Abogado) 114 querellas, de las cuales en 97 casos la víctima es una niña. Por lo anterior, se requiere urgentemente implementar medidas para prevenir y sancionar adecuadamente estas prácticas.

Al finalizar, la representante del Ejecutivo comentó que en la redacción del proyecto de ley, que generó un consistente asentimiento parlamentario en el primer trámite constitucional, hubo un proceso participativo amplio, que se hizo cargo de las recomendaciones que hiciera la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en esta materia.

A su turno, la señora Defensora de la Niñez, luego de reiterar la importancia de esta iniciativa, arguyó que su sustento normativo se encuentra en los artículos 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en las Observaciones Generales N°s. 13 y 25 del Comité de los Derechos del Niño. Siendo la explotación sexual infantil una de las violaciones más graves de derechos fundamentales de NNA, que afecta de forma categórica su desarrollo integral, resulta esencial legislar sobre la materia. Es deber del Estado de Chile brindar protección efectiva a este grupo de la población.

Enseguida, la señora Defensora de la Niñez valoró el cambio de visión que se ha verificado actualmente acerca de este problema, que ha implicado incluir elementos tecnológicos como medios para cometer estos delitos, y que hoy nuestra legislación no regula integralmente. En circunstancias que la ley vigente no aborda la explotación sexual infantil como un fenómeno delictivo específico y multicausal, que involucra una relación de poder entre el

Informe de Comisión de Constitución

agresor y sus víctimas, el proyecto de ley en estudio, en cambio, estructura este delito de manera distinta y aclara que en su ejecución no media la voluntad de la víctima, sino que un abuso y una explotación. Así, se erradica la idea equivocada de “prostitución infantil” que utiliza el Código Penal, vinculada a la disposición y voluntad de las víctimas. El punto medular, añadió, es que este tema se analice como un fenómeno específico: por ejemplo, mediante su tratamiento en un párrafo dedicado sólo al proxenetismo y a la explotación sexual comercial y pornografía de NNA, y la tipificación de nuevos delitos relacionados con la pornografía infantil que reconozcan sus diferentes modalidades. En este orden, estuvo conteste con que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya tomado en consideración las propuestas destinadas a aumentar las sanciones haciendo aplicables las correspondientes a un crimen y establecer una agravante especial cuando el delito sea cometido por funcionarios públicos, fundada en su deber de protección como agentes del Estado.

Concluyó su intervención abogando por el establecimiento de técnicas especiales de investigación en esta materia, que permitan recabar más y mejores pruebas para sostener la imputación penal ante los tribunales y lograr la aplicación de penas proporcionales a la gravedad del daño causado.

El Honorable Senador señor Moreira, consultó sobre las razones que explican que la retribución sea un requisito del tipo penal (no siendo suficiente la sola utilización de niños y niñas para su configuración); el motivo para distinguir las conductas descritas en el inciso primero del artículo 367 quáter, de la producción de material pornográfico establecido en el inciso segundo, y la utilización de la expresión “maliciosamente” como elemento del tipo (dado que el almacenamiento de material pornográfico podría producirse sin la voluntad del imputado; por ejemplo, si inadvertidamente se envía un archivo que quedó registrado en la memoria de un dispositivo).

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Defensa y Derechos Humanos explicó que la inclusión de la retribución en el tipo se relaciona con la naturaleza comercial de la explotación sexual: se trata de un concepto amplio, que busca precisar que se está ante una modalidad de carácter comercial. En lo tocante a la regulación separada de las figuras contenidas en los incisos primero y segundo del artículo 367 quáter propuesto, la personera señaló que, si bien originalmente se planteó la posibilidad de unir ambas hipótesis, el Ministerio Público recordó que existen casos en que se verifican ambos supuestos de forma independiente (por lo que resulta conveniente regularlos separadamente). En cuanto al almacenamiento de material y la exigencia de que la conducta sea cometida maliciosamente, adujo que responde a la necesidad de que concurra dolo directo en la ejecución del delito.

La señora Defensora de la Niñez precisó que se exige retribución en la explotación sexual infantil porque la simple utilización de NNA ya se encuentra cubierta por otros tipos penales, como el abuso sexual o la violación. En la especie, al aludirse a una retribución no sólo se incluye una asignación económica, sino que también a prestaciones de otra naturaleza. Ello, permite cubrir diversas hipótesis en que los niños pueden ser víctimas de estas conductas (hay casos en que los propios familiares exponen a niños a la explotación sin que estos reciban la retribución, sino el adulto).

En lo que atañe a las figuras del artículo 367 quáter, sostuvo que la distinción que se propone responde a consideraciones relacionadas con la investigación de estos delitos que se basan en la experiencia del Ministerio Público en la persecución penal y las dificultades que ha tenido para lograr una condena en casos de producción de material pornográfico. Se pretende posibilitar que se impute con mayor eficiencia la producción de material pornográfico infantil.

Sobre la voluntariedad del autor como elemento del tipo en el delito de almacenamiento de pornografía infantil, hizo presente la necesidad de que el fiscal acredite la concurrencia de este elemento volitivo. Como el ejemplo planteado por el Senador señor Moreira no podría sostenerse probatoriamente como una acción maliciosa, no sería susceptible de perseguirse penalmente.

El Honorable Senador señor Walker acotó que lo expuesto precedentemente se relaciona con los elementos del tipo penal. El punto, dijo, se discutió cuando se aprobó el catálogo de delitos relacionados con la pedofilia y la explotación sexual infantil, ocasión en que hubo penalistas que criticaron la inclusión de un elemento volitivo adicional.

Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Galilea manifestó su inquietud por los motivos para incorporar en el inciso segundo del nuevo artículo 367, la aplicación de una multa pecuniaria si la explotación se perpetrare en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad. En su opinión, la multa no debería quedar restringida a un monto específico, sino que debería otorgarse al juez libertad para determinar una indemnización, de conformidad con las circunstancias del caso.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos explicó que, en lo tocante a ese punto, aunque se mantuvo en el proyecto la regulación vigente, ello no obsta a que, adicionalmente, se pueda demandar indemnización de perjuicios.

El Honorable Senador señor Araya, favorable a esta iniciativa, refiriéndose al artículo 367 quinquies del proyecto de ley, señaló que establecería una presunción de principio de ejecución. Al respecto, cuestionó el significado de la frase relativa a que “se tenga acceso desde territorio nacional” que se emplea en la disposición, advirtiendo que los servidores pueden estar en Chile o en el extranjero (como ocurre en las conexiones vpn, utilizadas cuando no se desea dejar registro de actividades realizadas a través de servidores nacionales). Sobre el particular, estuvo por consultar a la SUBTEL sobre los alcances de esta norma.

Sobre el artículo 367 octies (al tenor del cual para determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12 en esta clase de delitos se considerarán las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida), adujo que este aspecto se relaciona con el efecto de sentencias penales dictadas en país extranjero. Es conocido, añadió, que las legislaciones extranjeras en materia penal poseen tipologías y penas propias y diferenciadas. En ese orden, mediante la norma propuesta podría incurrirse en una vulneración del principio de tipicidad, lo que la tornaría inconstitucional. Además, no todos los países poseen los mismos registros de condenas, y no existe una base de datos en la que se pueda obtener información de condenas, por lo que, de requerirse información sobre un caso particular, deberá solicitarse directamente al Estado respectivo. Por tal razón, consultó si se estaba considerando celebrar un algún convenio internacional en la materia, pues en principio los países no están obligados a informar antecedentes procesales de sus ciudadanos (el acceso a la información de Interpol no sólo es restringido, tampoco es completa).

El Honorable Senador señor Moreira, para dimensionar este ilícito y la situación real que pretende abarcar el proyecto, consideró oportuno conocer estadísticas relativas a la cantidad de condenas y absoluciones que se han producido en los últimos años, así como al número de investigaciones formalizadas o desformalizadas que se han iniciado.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a la consulta en torno a servidores ubicados fuera de Chile, se comprometió a solicitar antecedentes técnicos a la SUBTEL para respuesta técnica adecuada para presentarla ante la Comisión, y puntualizó que, por medio de transformaciones tecnológicas, se han generado carteles de pornografía infantil que vulneran la capacidad de control dentro de un espacio territorial.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agregó que la disposición acerca de la reincidencia con sentencia en país extranjero proviene de una norma que ya existe en el ámbito de la “trata de personas”. La solución allí contenida se trasladó al artículo que se propone, sin perjuicio de que puede ser objeto de una discusión más detallada.

El Honorable Senador señor Araya recordó que, si bien la norma referida a la trata de personas reproduce la solución contemplada en el convenio internacional suscrito por Chile en la materia, actualmente se estaría en una situación distinta, lo que haría conveniente un análisis pormenorizado al respecto para precaver vulneraciones al principio de tipicidad.

La Defensora de la Niñez, en alusión a la consulta acerca de la pertinencia de una multa y su cuantía, previno que la eliminación de esta sanción accesoria dejaría exclusivamente la pena privativa de libertad como castigo, lo cual sería un retroceso desde el punto de vista de la punibilidad asociada a la comisión del delito. Se debe entender, añadió, que esta multa no dice relación con un objetivo indemnizatorio para la víctima, sino con una imposición a favor del Estado. Con todo, la personera coincidió en la baja cuantía de esta sanción pecuniaria, sobre todo si se atiende a que se trata de una hipótesis de habitualidad y de relación de dependencia de la víctima respecto de su agresor. La habitualidad se enmarca en la ejecución de los actos de explotación al alero de un lugar o

Informe de Comisión de Constitución

establecimiento comercial en el cual se ejecutan estas conductas, por lo que se incrementa la sanción restrictiva de la libertad mediante una multa en base al lucro que el agresor obtiene con ocasión de la explotación sexual. De allí que podría estudiarse el aumento de su cuantía, así como la posibilidad de cierre de los establecimientos comerciales en los cuales se haya ejecutado la explotación sexual.

Sobre el artículo 367 quíntes, precisó que la regulación se vincula con la posibilidad de acreditar que el acceso generado a un servidor (que puede estar ubicado en otro país) se produjo desde Chile por el imputado. Con ello se puede asumir la comisión del delito desde el lugar en el cual el imputado en Chile se conectó a ese servidor y, por ende, hacer punible la actuación delictiva.

En cuanto al artículo 367 octies, sostuvo que es un traslado de la norma y fue una recomendación que se hizo de parte de la Defensoría de la Niñez sobre la posibilidad de considerar sentencias dictadas en el extranjero para efectos de reincidencia, ya que se entendió relevante enfatizar agravantes específicas relacionadas con la comisión de estos graves delitos.

El lo que atañe a la inexistencia de bases de datos, hizo presente que el Ministerio Público, por medio de la Unidad de Cooperación Internacional, a propósito de alguna investigación que se esté llevando a cabo, obtiene información directa de los ministerios públicos o poderes judiciales de los países involucrados y a los que corresponda la sanción en cuestión, para obtener la copia de la sentencia y cualquier otro antecedente que permita sostener la comisión del delito. En consecuencia, la inexistencia de una base de datos no representa una dificultad, sino que se realiza caso a caso en cada una de las investigaciones y a propósito de requerimientos internacionales que efectúa esta unidad especializada del Ministerio Público.

Refiriéndose a estadísticas en la materia, informó que se solicitaron antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre la cantidad de niños víctimas de delitos sexuales por sexo, advirtiéndose que en el año 2020 hubo 3.806 víctimas, con un porcentaje mayor de víctimas mujeres.

Tabla 1 Cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales y otros delitos sexuales por sexo 2005-2020

Sexo	Años	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mujer	0 a 13	1.583	1.796	1.891	2.380	2.399	2.387	2.956	3.228	2.805	2.328	2.040	2.175	2.264	2.582	2.826	1.986
	14 - 17	987	1.074	1.225	1.445	1.496	1.433	1.716	1.677	1.511	1.298	1.280	1.227	1.343	1.538	1.694	1.316
	Total	2.570	2.870	3.116	3.825	3.895	3.820	4.672	4.905	4.316	3.626	3.320	3.402	3.607	4.120	4.520	3.302
Hombre	0 a 13	457	591	598	690	721	731	932	1.181	958	544	524	540	546	588	667	378
	14 - 17	92	107	113	112	144	140	117	149	124	98	85	110	98	114	140	126
	Total	549	698	711	802	865	871	1.049	1.330	1.082	642	609	650	644	702	807	504
Total	0 a 13	2.040	2.387	2.489	3.070	3.120	3.118	3.888	4.409	3.763	2.872	2.564	2.715	2.810	3.170	3.493	2.364
	14 - 17	1.079	1.181	1.338	1.557	1.640	1.573	1.833	1.826	1.635	1.396	1.365	1.337	1.441	1.652	1.834	1.442
	Total	3.119	3.568	3.827	4.627	4.760	4.691	5.721	6.235	5.398	4.268	3.929	4.052	4.251	4.822	5.327	3.806

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito

Luego, respecto a la edad de quienes han sido víctimas de estos hechos, entre 14 y 17 años se observa un tramo menor que aquel que se observa en los menores de 14 años.

Informe de Comisión de Constitución



En la trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, que son delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, se observa una proyección que exhibe cómo a las niñas y adolescentes mujeres las afecta en términos mayores que a los hombres.



Los gráficos anteriores, dijo, se refieren a delitos sexuales en general. Existe cierta dificultad para obtener datos específicos de explotación sexual comercial. Como experiencia de la Defensoría de la Niñez, se posee una intervención excepcional en el área judicial en aquellos casos en que la connotación y conmoción pública amerita la presentación de querellas. En este sentido, se han presentado a lo menos ocho querellas por explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes, incluso en contextos residenciales. De esas ocho investigaciones, sólo una se encuentra en vías de la imputación en juicio oral. De allí que la personera criticara la labor investigativa del Ministerio Público: la Defensoría de la Niñez ha representado formalmente al Fiscal Nacional y Fiscales Regionales la falta de debida diligencia en las investigaciones penales por explotación sexual comercial infantil, donde se observan debilidades severas en la investigación y falencias complejas desde el punto de vista proteccional de las

Informe de Comisión de Constitución

víctimas. Lo anterior acarrea consecuencias inadmisibles en un Estado que debe evitar la impunidad de delitos tan graves como los discutidos en este contexto. Son casos en que interviene la Defensoría de la Niñez, por lo que se trata de situaciones particularmente complejas, referidas a víctimas que pertenecen al sistema proteccional del Estado. No obstante, no se hacen las diligencias correspondientes ni se imputan cargos, por lo que es previsible que en el resto de los casos seas todavía peor (implicando una grave afectación de derechos para las víctimas).

La señora Ministra, a su turno, ilustró a la Comisión señalando que desde el Programa “Mi Abogado” se han presentado 114 querellas desde 2020 hasta la fecha por razón de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En 97 de aquellas se trata de niñas, por lo que es un asunto con una dimensión de género muy relevante. De entre las 114 querellas, se cuenta hoy con 9 formalizados.

El Honorable Senador señor Walker destacó que esta instancia parlamentaria ha fijado como prioridad los proyectos de ley sobre infancia vulnerable.

- - -

VOTACIÓN IDEA DE LEGISLAR

Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación la idea de legislar sobre este asunto.

- Sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Galilea, Moreira y Walker.

Cabe consignar que el Honorable Senador señor De Urresti manifestó su opinión favorable a la iniciativa.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito del acuerdo precedentemente reseñado, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, os propone aprobar en general el proyecto de ley acordado por la Honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,” e intercálase, entre el guarismo “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “ , 367 quáter, 367 septies”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente párrafo VI bis:

“§ VI bis. Explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.”.

3. Derógase el artículo 366 quinquies.

4 Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

“ART. 367.

El que promoviére o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a

Informe de Comisión de Constitución

cambio de cualquier tipo de retribución.”.

5. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución”.

6. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“ART. 367 quáter.

El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

ART. 367 quinquies.

Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

ART. 367 sexies.

Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

ART. 367 septies.

El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

ART. 367 octies.

Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

7. Reemplázase en el encabezado del Párrafo VII del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

8. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

Informe de Comisión de Constitución

9. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

10. Elimínase en el inciso primero del artículo 368 ter la expresión “366 quinquies,”, y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

11. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

12. Elimínase en el inciso primero del artículo 369 ter la expresión “366 quinquies,”, y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

13. Sustitúyese en el artículo 369 quinquies el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

14. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

15. Reemplázase en el artículo 372 incisos segundo y tercero el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

16. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

2. Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Reemplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por la expresión “367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,”, y agrégase, a continuación del guarismo “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Informe de Comisión de Constitución

- - -

ACORDADO

Acordado en sesión celebrada el día 20 de abril de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ignacio Walker Prieto (Presidente), Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton, Iván Moreira Barros (Luz Ebensperger Orrego) y Rodrigo Galilea Vial.

Sala de la Comisión, a 22 de abril de 2022.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín N° 14.440-07).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: En síntesis, propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial, cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

II. ACUERDO: Aprobado en general (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: Esta iniciativa contiene siete artículos, el primero de los cuales se compone de dieciséis numerales. Estas disposiciones modifican el Código Penal; la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales; la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

IV. URGENCIA: Simple.

V. ORIGEN E INICIATIVA: Se originó en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VI. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VII. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Fue aprobado en general y en particular por 114 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 14 de diciembre de 2021.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe. Pasa a la Sala.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) Código Penal.

b) Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

c) Ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

d) Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Informe de Comisión de Constitución

e) Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

f) Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

Valparaíso, 22 de abril de 2022.

[1] Sesión de la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de fecha 20 abril de 2022.

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 11 de mayo, 2022. Diario de Sesión en Sesión 17. Legislatura 370. Discusión General. Se aprueba en general.

INCORPORACIÓN DE NUEVO PÁRRAFO EN CÓDIGO PENAL RELATIVO A EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.440-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley tiene por objeto, en síntesis, propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace presente que discutió solo en general esta iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Araya, Galilea, Moreira y Walker. Consigna además que el Honorable Senador De Urresti manifestó su opinión favorable a ella.

El texto del proyecto de ley que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 16 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Secretario .

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, para que entregue el informe correspondiente.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta.

Tengo el honor de informar este proyecto, que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

Espero que, tal como ocurrió en la Comisión de Constitución, podamos aprobarlo en general en esta sesión.

Por eso voy a ser muy directo y bastante sucinto en la rendición de este informe.

¿Por qué hablamos de explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes?

El otro día, en un reportaje en televisión, se hablaba de una red de pornografía infantil, y por ello es muy importante señalar que acá estamos hablando de explotación sexual infantil y no de pornografía infantil, porque los niños, niñas y adolescentes son explotados.

Por tal razón, este proyecto tiene por objeto propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual

Discusión en Sala

comercial cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 14 de diciembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución. Asimismo, cabe consignar que este proyecto de ley se discutió solo en general, como ha dicho el señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento.

¿Cuáles son las modificaciones más importantes, Presidenta ?

La primera sustituye el artículo 367 del Código Penal, que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años. Con esta enmienda, si se perpetrare el hecho explotando a la víctima en razón de su dependencia personal o económica o si concurre habitabilidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco UTM. La norma, además, entiende por explotación sexual "la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución".

En el artículo 367 ter del Código Penal se incorpora como elemento del tipo obtener la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución.

Se incluye una serie de artículos en el referido Código; a saber:

-El artículo 367 quáter, que sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo al que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

Con la misma pena sanciona al que participare en la producción de dicho material pornográfico.

Asimismo, castiga con presidio menor en su grado medio al que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

Para tales efectos, se entiende "por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines".

-El artículo 367 quíntes, que considera cometidas en Chile las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

-El artículo 367 sexies, que declara no aplicable este nuevo párrafo si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro II, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

-El artículo 367 septies, que sanciona con presidio menor en su grado máximo al que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años.

-El artículo 367 octies, que precisa que para determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12 en esta clase de delitos se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.

En cuarto lugar, regula diversos efectos de la ley en el tiempo:

-Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa, así como las penas y las

Discusión en Sala

demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

-Si la ley entra en vigor durante la perpetración del hecho, se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

-Si la aplicación de esta ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella, conforme a las reglas generales.

-Para determinar si la aplicación resulta más favorable, se deberán considerar todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

-Para los efectos de lo dispuesto en esta normativa, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Presidenta, finalmente quiero agradecer a la Defensoría de la Niñez, particularmente a la Defensora de la Niñez, Patricia Núñez , por su disposición...

La señora ALLENDE .-

Patricia Muñoz .

El señor WALKER.-

Exactamente, Patricia Muñoz ; muchas gracias, Senadora Allende .

Decía que quiero agradecerle por su disposición a mejorar la tramitación de este proyecto, incorporando más tipos penales a todo el catálogo de explotación sexual infantil.

El proyecto también fue perfeccionado en el trámite de la Cámara de Diputados.

En tal sentido, quiero agradecer a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos , por su apoyo a este proyecto.

Estoy seguro de que todavía podemos afinarlo más en el trámite en particular; pero espero, Presidenta , que tengamos la oportunidad de aprobarlo ojalá hoy día en general.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

La señora ALLENDE.-

"Si le parece".

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Debido a la importancia de este proyecto, y tal como se solicita acá, recabo la unanimidad de la Sala para aprobarlo en general.

(Varios señores Senadores levantan la mano en señal de aprobación).

Senador Insulza, ¿quiere decir algo?

El señor INSULZA.-

No; después, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Bien.

--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Hay que fijar plazo para la presentación de indicaciones.

Le consulto al Presidente de la Comisión si tiene alguna propuesta.

El señor WALKER.-

Dos semanas.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Se propone el 2 de junio.

El señor GALILEA.-

No; es justo volviendo de la semana regional.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Una semana más.

Nos indican el 16 de junio, a las 12.

¿Les parece a Sus Señorías?

--Así se acuerda.

Boletín de Indicaciones

2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 16 de junio, 2022. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO AL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES BOLETÍN N° 14.440-07

INDICACIONES

16.06.2022

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYETO DE LEY

1.- Del Honorable Senador señor Walker, para reemplazarla por la siguiente: “Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

ARTÍCULO 1

o o o o o

Número nuevo

2.- Del Honorable Senador señor Walker, para intercalar, a continuación del número 1, el siguiente número 2, nuevo:

“2. Intercálase, en el inciso primero del artículo 366 quáter, entre las expresiones “material pornográfico” y “o presenciar espectáculos”, lo siguiente: “o de explotación sexual”.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

3.- De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, para incorporar el siguiente número 2, nuevo:

“2. Modifícase el artículo 366 quáter, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, suprímese la frase “, para procurar su excitación sexual o la excitación de sexual de otro”.

b) En el inciso segundo, reemplázase la frase “Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación de sexual de otro,” por lo siguiente: “El que”.”.

o o o o o

Número 2

4.- Del Honorable Senador señor Walker, para reemplazar, en la denominación del Párrafo VI bis propuesto, la palabra “pornografía”, por la expresión “material de explotación sexual”.

Número 4

Artículo 367 propuesto

Inciso tercero

5.- De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, para intercalar entre la expresión

Boletín de Indicaciones

“retribución” y el punto final, el siguiente texto: “hacia el menor o un tercero”.

Número 5

6.- De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, para agregar, en la frase que se propone, luego de la palabra “retribución”, el siguiente texto: “hacia el menor o un tercero”.

Número 6

Artículo 367 quáter propuesto

7.- Del Honorable Senador señor Walker, para reemplazar la palabra “pornográfico”, todas las veces que aparece, por la expresión “de explotación sexual”.

o o o o o

Inciso nuevo

8.- De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, para intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“Con todo, quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.”.

o o o o o

- - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 18 de agosto, 2022. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 49. Legislatura 370.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. BOLETÍN N° 14.440-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, iniciado en Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, y para cuyo despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de “suma”.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 14 de diciembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Participaron en las sesiones que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, en forma presencial o por vía telemática, los siguientes personeros:

- La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, acompañada por los asesores jurídicos señores Rafael Ferrada y Diego Moreno; el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton, y el encargado de asuntos digitales, señor Vicente Cornejo.
- La Subsecretaria de la Niñez, señora Rocío Faúndez.
- La Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz.
- El asesor legislativo de la SEGPRES, señor Guillermo Briceño.
- Los asesores parlamentarios señoras Paola Bobadilla y Daniela Farías y señores Roberto Godoy, Felipe Hübner, Benjamín Lagos, Pedro Lezaeta, Héctor Mery e Ignacio Ortega.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: Del artículo 1, los numerales 1, 3 (pasa a ser 4), 7 (pasa a ser 8), 8 (pasa a ser 9), 9 (pasa a ser 10), 10 (pasa a ser 11), 11 (pasa a ser 12), 12 (pasa a ser 13), 13 (pasa a ser 14), 14 (pasa a ser 15), 15 (pasa a ser 16) y 16 (pasa a ser 17), y los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Ninguna.

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s. 1, 2, 3 letra b), 4, 5, 6 y 7.

4.-Indicaciones rechazadas: Ninguna

5.-Indicaciones retiradas: N°s. 3 letra a), y 8.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

- - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando sean niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se contiene una descripción de las indicaciones y de los artículos en que inciden, señalándose en cada caso los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto.

Denominación administrativa del proyecto de ley

El título que se ha asignado a esta iniciativa legal es “Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes”.

Indicación N° 1.-

Del Honorable Senador señor Walker, propone reemplazar la referida denominación por la siguiente: “Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

Con motivo del análisis de esta indicación, el Honorable Senador señor Walker explicó que su propósito es superar el concepto “pornografía infantil”, y reemplazarlo por el de “material de explotación sexual”. Ello, en la medida que el primero denotaría cierto consentimiento de quienes participan en la elaboración del material de que se trata.

Para fundamentar la propuesta, el señor Senador citó el artículo “It's Not Child Pornography, It's Child Sexual Abuse Material” elaborado por la organización Child Rescue Coalition, que discurre sobre la idea de abuso sexual infantil. En su opinión, se hace necesario precisar el lenguaje, y no hablar de pornografía: los menores no consienten en participar en esta clase de situaciones, lo que ocurre en estos casos es explotación de niños, niñas y adolescentes por parte de personas adultas.

El Honorable Senador señor Araya previno acerca de las dudas que suscita la sustitución de un concepto ampliamente asentado en la jurisprudencia y la doctrina penal.

El Honorable Senador señor Galilea, luego de hacer presente que el concepto de material pornográfico se encuentra definido en el Código Penal, coincidió con la relevancia del tema.

A la luz de las observaciones formuladas por el Ministerio Público a las indicaciones, el Honorable Senador señor Walker fue partidario de reemplazar la alusión a “pornografía” por “material pornográfico”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger destacó la relevancia de la denominación que el legislador confiere a los párrafos y títulos de un cuerpo legal, toda vez que influye en el tratamiento que la jurisprudencia y la doctrina le dan a la materia. De allí, también, la importancia que adquiere el nombre que tendrá el proyecto.

El Honorable Senador señor Walker, en el entendido que el Ministerio Público valoró positivamente la indicación, tendiente a erradicar de la legislación penal las referencias a la pornografía (pues supondría la realización de actos sexuales voluntarios), arguyó que tal expresión contribuye a normalizar, legitimar y disminuir la gravedad de este delito. Con todo, acotó que el Ministerio Público considera pertinente utilizar en el ámbito legal la noción de “material pornográfico”.

El asesor legislativo del Ministerio del ramo, señor Ferrada, señaló la coincidencia del Ejecutivo con el planteamiento del Ministerio Público: la locución contenida en el Código Penal es “material pornográfico”. Por otra parte, previno que el texto propuesto para el artículo 367 quáter emplea este mismo término (que, incluso, en el inciso final, se define).

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor De Urresti abogó por la debida congruencia de la terminología utilizada en el articulado del proyecto.

El Honorable Senador señor Araya, junto con compartir la opinión del Ministerio Público, reiteró que los conceptos “pornografía” y “material pornográfico” se encuentran asentados en la doctrina y jurisprudencia penal, e insistió en las dudas que surgen ante una eventual eliminación de los elementos subjetivos del tipo penal.

En mérito del debate habido, la Comisión estuvo por modificar la redacción de la indicación, en sintonía con las ideas discutidas. En este sentido, la denominación adecuada del proyecto de ley explicitar que su finalidad es introducir un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

- Con dicha redacción y sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti y Walker.

ARTÍCULO 1.-

Introduce, mediante dieciséis numerales, diversas modificaciones en el Código Penal.

□ □ □

Indicación N° 2.-

Del Honorable Senador señor Walker, propone intercalar un numeral 2, nuevo, para incluir una alusión al “material de explotación sexual” en el artículo 366 quáter, que sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo a quien, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realiza acciones de significación sexual ante un menor de catorce años, o le hace ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter.

El asesor legislativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Moreno, planteó que, en la medida que el cambio de nomenclatura utilizada por la normativa da cuenta de la naturaleza del fenómeno de la explotación sexual infantil, adujo que la propuesta sería concordante con el espíritu del proyecto, a saber, cambiar el paradigma de este delito.

No obstante, prosiguió, cuando se revisa el parecer de la sociedad civil y de los organismos públicos en la materia y se analiza la literatura internacional, se evidencia que el concepto “pornografía de menores” tiene raíces normativas. En ese marco, el documento de la UNICEF titulado “Orientaciones terminológicas para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual”, recomienda no reemplazar “pornografía de menores” por “material de explotación”, basándose en que la noción de “pornografía” se encuentra arraigada en el derecho penal e internacional. Incluso, dijo, si bien en derecho de la infancia se ha postulado reemplazar el vocablo “prostitución infantil” por “explotación sexual”, no ha ocurrido lo mismo con pornografía infantil y material pornográfico.

El asesor señor Ferrada, luego de puntualizar que en derecho comparado se utiliza el término “material pornográfico”, señaló que el origen de este concepto en nuestro país data del año 2004, cuando se incorporó en el Código Penal el artículo 366 quinquies, inciso final, para responder a las dudas que originaba la noción de “material pornográfico”. Al respecto, recordó que, con arreglo a dicha disposición, se entiende por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

A la fecha, precisó, existe un nutrido desarrollo doctrinario y jurisprudencial en torno al concepto, por lo que cualquier modificación terminológica en esta materia requerirá de una nueva definición y del subsecuente proceso de elaboración interpretativa en sede penal. En razón de lo expuesto, arguyó, de aprobarse esta indicación habrá que definir el nuevo concepto en el artículo 366 quinquies, para asimilarlo a material pornográfico.

El Honorable Senador Walker hizo presente que esta indicación no ha sido objeto de controversias.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Enseguida, el asesor señor Ferrada sugirió explicitar cada vez que se aluda a material pornográfico el término “explotación sexual”, dado que, si bien es un concepto reconocido por las ciencias sociales, no lo es por la normativa.

El Honorable Senador señor Walker aclaró que tal sugerencia sería consistente con la indicación, cuando intercala, a continuación de “material pornográfico”, la frase “o de explotación sexual”.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas de técnica legislativa por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti y Walker.

□ □ □

Indicación N° 3.-

De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, persigue también incorporar un numeral 2, nuevo, para modificar el artículo 366 quáter, en dos sentidos:

- En su letra a), para suprimir, en el inciso primero, la frase relativa a “procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro”.

- En su letra b), para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro,”, por “El que”.

Con motivo de su análisis, el Honorable Senador señor Galilea sostuvo que la propuesta se funda, por una parte, en el carácter confuso de la redacción de la norma vigente y, por otra, en el hecho de que en las conductas punibles que se comentan la excitación sexual, como elemento subjetivo del tipo, sería indiferente a los efectos de la configuración del delito. Lo anterior, porque si se cometen actos de esta naturaleza serán considerados punibles cualquiera que sea su motivación. Exigir un elemento adicional del tipo, acotó, complejiza la prueba y menoscaba el objetivo de protección de niños, niñas y adolescentes.

El Honorable Senador señor Walker estuvo conteste en la idea de eliminar este elemento subjetivo del tipo.

El Honorable Senador señor Araya, discrepando de quienes lo antecedieron en el uso de la palabra, advirtió que la modificación que se consulta aproxima esta figura delictiva a un derecho penal objetivo, como quiera que elimina un elemento subjetivo del tipo y de la culpabilidad. A modo ilustrativo, el señor Senador citó el caso de la asistencia de un menor de edad a una exhibición de arte en que se representen actos de connotación sexual: si se suprime el elemento subjetivo, se verificaría el tipo penal.

El Honorable Senador señor Walker planteó que el elemento culpabilidad seguirá presente, porque se mantiene la expresión “determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual”. En ese marco, aunque la intencionalidad se debilita, no se afectan los elementos del tipo penal. Algo similar, añadió, ocurrió con las modificaciones introducidas a la Ley Antiterrorista, que complejizaron su aplicación: los gobiernos se han mostrado reacios a aplicarla, entre otros motivos por la dificultad de probar el elemento subjetivo, esto es, el “ánimo terrorista” (una querrela por el delito de incendio sería más efectiva).

El asesor ministerial señor Moreno explicó que mientras el inciso primero del artículo 366 quáter describe conductas que realizan otros frente al menor, el inciso segundo regula determinaciones para que el niño o niña realice ciertos actos. En este segundo grupo de ilícitos el elemento subjetivo tiene por objeto distinguir conductas reprochables de otras que no lo son (por la falta de contacto físico en estos delitos), mediante un ánimo especial en el tipo. Ejemplo de lo anterior, es el caso en que un niño irrumpe en la habitación de sus padres mientras mantienen coito (como quiera que es un acto de significación sexual ante un menor de 14 años). El inciso segundo contempla los casos en que un menor de 14 años es el que realiza ciertos actos de connotación sexual, distinguiendo tres hipótesis: que realice ciertas actividades con su cuerpo; que entregue imágenes o grabaciones de su cuerpo, o que entregue grabaciones corporales de otro menor de 14 años. En el primer caso, podría eliminarse el ánimo especial; en el segundo, sería discutible; en el tercero, el ánimo especial cobra relevancia para diferenciar conductas reprochables de las que no lo son.

El Honorable Senador señor Walker explicó que, de aprobarse la indicación, el elemento subjetivo del tipo se

Segundo Informe de Comisión de Constitución

mantiene, y consiste en determinar a una persona menor de 14 años a realizar actos de significación sexual (no basta con mirar una foto o presenciar una obra de un desnudo, por ejemplo).

El asesor parlamentario señor Mery señaló que hay ocasiones en que el legislador acude a elementos subjetivos anómalos del tipo (como en el caso de los delitos de injuria y calumnia), que exceden el dolo. El profesor Enrique Cury sitúa estos elementos en la estructura de la tipicidad y como requisitos subjetivos y objetivos del tipo. Otros autores los ubican en el plano de la culpabilidad. Como el dolo de un delito, añadió, no se identifica con la concurrencia del elemento anímico particular, la supresión de esta exigencia subjetiva podría implicar castigar con mucho rigor conductas que, si se mantuviera, no serían ilícitas.

Al concluir, consideró aceptable la redacción propuesta por los autores en la letra b) de la indicación, en cuanto no produciría el riesgo de un castigo excesivo.

El Honorable Senador señor De Urresti, valorando el debate doctrinario, fue partidario de atender al modo cómo ha razonado la jurisprudencia en la materia, para mantener un análisis práctico y no sólo normativo.

El Honorable Senador señor Galilea, tendiendo presente que la letra b) de la indicación no genera mayor discrepancia, adujo, respecto a la letra a), que, en circunstancias que el artículo 366 quáter tipifica delitos en que se verifica un contacto corporal, se trata de conductas de significación sexual en que puede haber confusión si se elimina el elemento subjetivo. En los otros supuestos normativos no puede haber equívocos: por ejemplo, si se obliga a ver o escuchar material pornográfico a un niño, debe sancionarse con prescindencia del ánimo del sujeto.

El Honorable Senador señor Araya recordó que las normas en análisis fueron incorporadas el año 2011, cuando la tecnología no se encontraba tan avanzada como en la actualidad, que ha generado que hoy muchos menores de edad establezcan relaciones sentimentales y sexuales utilizando medios tecnológicos. Si se elimina el elemento subjetivo puede suscitarse un problema para esos supuestos, al ser ambos menores de edad. Sobre este punto, sería útil conocer si existe jurisprudencia bajo el régimen de responsabilidad penal adolescente.

El Honorable Senador señor De Urresti, conteste en conocer la jurisprudencia sobre este tema, planteó que los avances tecnológicos de los últimos años pueden haber incrementado la ocurrencia de estos hechos, dada la facilidad para difundir imágenes y videos.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, aludiendo a los datos de ingreso de causas, comentó que el delito del artículo 366 quíntos efectivamente ha aumentado en los últimos años (de 66 casos el 2018, a 101 el 2021).

Al respecto, el Honorable Senador Araya estuvo por distinguir los casos que se han verificado bajo el régimen de responsabilidad penal adolescente, principalmente respecto al delito del artículo 366 quáter, que es el que genera mayores dudas.

El asesor señor Moreno, hizo presente que el artículo 4° de la ley N° 20.084 consagra la regla denominada “Romeo y Julieta”, en virtud de la cual, si no concurre alguna de las circunstancias de la violación o del estupro, no hay responsabilidad penal adolescente si entre la víctima y victimario no hay más de tres años de diferencia. Es probable que los casos del 366 quáter por responsabilidad penal adolescente sean bajos, y se refieran sólo a aquellos en los que exista una diferencia de edad superior a la mencionada.

La Subsecretaria de la Niñez, luego de advertir que la explotación sexual comercial tiene características particulares, señaló que dicha actividad involucra a un adulto y a un menor de edad, y requiere intercambio de dinero o especies. Esta condición la distingue de otros fenómenos, como la difusión sin consentimiento de imágenes de contenido sexual. La Defensoría de la Niñez, sostuvo, ha planteado la conveniencia de modificar la nomenclatura en la legislación para desarraigar conceptos como los de “pornografía” o “prostitución infantil”, que pueden naturalizar la explotación sexual comercial al dar a entender que existe cierto grado de consentimiento de la víctima.

A su turno, prosiguió, el Comité de los Derechos de la Niñez ha declarado que, atendida la existencia de un lenguaje legal constituido desde la noción de pornografía o material pornográfico, sería recomendable que el cambio se verifique en los espacios donde se elaboran políticas públicas y orientaciones técnicas. No obstante, en este momento no se considera imperativo un cambio de dicha índole, por los costos prácticos que podría acarrear y la posibilidad de generar más problemas que beneficios.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, sostuvo que este asunto está en la línea con el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados acerca de la necesidad de acelerar la tramitación y aprobación de proyectos de ley como el que se analiza, o el que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio.

En lo tocante a las acciones concretas que la Subsecretaría ha desarrollado, comentó la elaboración de un estudio de la Fundación Tierra Esperanza que busca reconstruir la ruta de la respuesta del Estado en la persecución y protección hacia niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Los nudos críticos de esta respuesta, persiguen visibilizar experiencias comparadas y, a partir de ello, formular respuestas sobre la intervención que se necesita.

Refiriéndose a las dinámicas cambiantes del fenómeno de explotación, explicó que el incremento de la vida digital y, particularmente, el confinamiento por la pandemia, han favorecido la explotación sexual comercial, porque los medios digitales han permitido un despliegue acelerado y el surgimiento de nuevas prácticas.

A fin de aclarar los alcances que tendría la propuesta, el Honorable Senador señor Walker fue partidario de considerar la opinión del Ministerio Público sobre la eliminación del elemento subjetivo del tipo.

El asesor señor Ferrada, luego de manifestar que el Ejecutivo es contrario a la indicación y valorar la idea de estudiar la jurisprudencia, aludió a la existencia de fallos en los cuales los sentenciadores analizan de qué forma se puede inferir, a partir de la conducta de un sujeto, que un delito se cometió para procurar conseguir excitación sexual. El artículo 366 quáter, prosiguió, alude a un abuso sexual en el que no hay contacto, aspecto que lo diferencia de otras modalidades de abuso: al no haber contacto corporal se torna necesario exigir que el dolo se manifieste para procurar la excitación sexual. Sobre los supuestos del inciso segundo, en que se determina a un menor de catorce años para que realice acciones de significación sexual o envíe imágenes, la jurisprudencia ha entendido que el ánimo existe pese a que no se evidencien signos explícitos de excitación sexual. Así, el dolo subjetivo que exige este tipo penal se entiende verificado según el contexto. Por esto, para no innovar ni alterar lo resuelto por la jurisprudencia, sugirió mantener el texto vigente.

El Honorable Senador señor Walker comentó que el Ministerio Público apoya la indicación sobre la base de dos argumentos: la eliminación de un obstáculo para la persecución de estos delitos; el tratarse de un elemento subjetivo adicional, por lo que, de suprimirse, seguirá siendo necesaria para su sanción la concurrencia de dolo. Por lo mismo, arguyó, no se configuraría una forma de responsabilidad penal objetiva.

El Honorable Senador señor Araya sostuvo que, en circunstancias que la opinión del Ministerio Público se explicaría por las dificultades que ha experimentado para acreditar esta clase de delitos, eliminar este elemento transformará esta figura delictiva en un tipo penal objetivo, con prescindencia de si hay o no dolo (que siempre será un elemento del tipo penal).

El asesor legislativo señor Mery, refiriéndose a los argumentos del Ministerio Público para apoyar la indicación, esto es, la eliminación de un obstáculo para la persecución del delito; la dificultad para acreditar los elementos anímicos, el hecho de que estos elementos subjetivos estarían comprendidos dentro de la noción de dolo, comentó lo siguiente:

- Se desconoce la existencia de figuras delictivas que exigen la concurrencia de elementos subjetivos distintos del dolo y que son ocasionales.
- De eliminarse, también se podría proponer modificar los delitos contra el honor y suprimir el elemento del tipo en los delitos de injurias y calumnias, porque representan un obstáculo para su persecución. Lo anterior, no obstante la dificultad para probar este elemento.
- Se trata de un elemento anómalo y atípico, diferente del dolo. Su supresión puede generar distorsiones y resultados injustos, que pueden ser más perjudiciales. Al ponderar ambos valores, hay que privilegiar aquello que permita castigar las conductas que efectivamente busquen un propósito delictivo (cuestionado por el legislador).

El Honorable Senador señor Galilea, estuvo por distinguir los supuestos descritos en los dos incisos del artículo 366 quáter, y aceptar la indicación sólo respecto del inciso segundo. Si bien en los supuestos del inciso primero es útil contar con un elemento subjetivo adicional, las hipótesis del inciso segundo son de carácter objetivo y no requieren ningún ánimo especial para su verificación. De aprobarse así la indicación, quedarían cubiertas las aprehensiones

Segundo Informe de Comisión de Constitución

planteadas.

El asesor parlamentario señor Godoy explicó que la norma no contiene elementos subjetivos adicionales al dolo, sino un dolo especial. Consecuencialmente, si se elimina este elemento la figura se convierte en un tipo de responsabilidad penal objetiva. El derecho penal ha avanzado a la eliminación de los delitos de esta naturaleza.

Por su parte, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Ferrada, luego de recordar que el artículo 366 quáter tipifica el abuso sexual impropio, esto es, aquel en que no existe contacto corporal con la víctima (lo que justificaría la exigencia de un ánimo especial en su comisión, a saber, procurar la excitación sexual), arguyó que esta norma contiene dos delitos distintos:

- En el primero, la víctima menor de edad tiene una actitud pasiva, porque se le obliga a observar algún acto de significación sexual. En este supuesto, la postura del Ejecutivo es mantener el dolo lascivo, por considerar necesario este reproche penal más intenso.

- En el segundo, se obliga al niño a realizar alguna acción de significación sexual, y, enseguida, se describe el denominado child grooming (la acción de enviar o remitir imágenes de sí mismo).

En ese marco conceptual, la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos sugirió una propuesta de redacción del artículo 366 quáter, que implica sustituir sus incisos primero y segundo, por lo siguiente:

“Art. 366 quáter. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

- a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

- b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años, si dicha determinación se hiciere para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro.”.

Al explicar el sentido de la propuesta, el asesor señor Moreno declaró que implica distinguir aquellos casos en que es posible prescindir del elemento subjetivo especial o ánimo lascivo, de aquellos en que es necesario mantenerlo para diferenciar conductas reprochables de otras que no lo son. Además, se mantiene el ánimo especial en las dos hipótesis del inciso primero, esto es, cuando se realizan actos de significación sexual ante la persona menor de edad, y cuando se le hace ver material pornográfico o de explotación sexual. El elemento subjetivo, dijo, resulta importante para distinguir conductas reprochables de otras que no lo son. En el inciso segundo se elimina el ánimo especial tratándose de aquellos supuestos en que se determina al menor a realizar acciones de significación sexual. En el nuevo inciso tercero se diferencia el caso en que se determinare a una persona menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir: (a) imágenes o grabaciones en que se representen acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de 14 años (en que no se exige el ánimo especial), de (b) imágenes o grabaciones de sus genitales o de otra persona menor de 14 años (en que sí se exige dicho ánimo).

Según el personero de Gobierno, cuando se analizó la disposición se pudo advertir un vacío normativo que genera impunidad, referido a las hipótesis cubiertas por la letra b) de la propuesta. En estos casos, la imagen no tiene un contenido de significación sexual “naturalmente” lo que se compensa con una mayor exigencia de reprochabilidad, que se traduce en el ánimo especial de la persona que determina al menor de 14 años a realizar tales conductas. Así, se restringe la exigencia del ánimo especial, manteniéndolo sólo en los casos en que es decisivo para cumplir el mandato de determinación de las conductas punibles.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, partidaria de la indicación N° 3, dijo no comprender las razones del Ejecutivo para proponer una nueva letra b) que mantiene el ánimo especial en la comisión de la conducta, porque,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

en su opinión, siempre será grave enviar imágenes de genitales a una persona menor de 14 años. Con independencia de los motivos, la sola realización de la conducta debería ser sancionada, atendida su gravedad.

El Honorable Senador señor Galilea propuso la siguiente redacción: “El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años,...”, manteniendo la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esta conducta, argumentó, es distinta a hacer ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, como señala a continuación el actual inciso primero. Esta última figura debería incorporarse al inciso segundo, respecto del cual existe consenso en orden a eliminar el elemento subjetivo.

En lo tocante a la propuesta del Ejecutivo de incorporar un inciso tercero, compartió la aprensión relativa a que el envío de imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de 14 años debiese ser un delito objetivo, sin consideraciones subjetivas del autor.

La Defensora de la Niñez valoró la propuesta desde el punto de vista proteccional, considerando que niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a diversas hipótesis delictivas, como la realización de acciones de significación sexual frente a ellos o la exposición de imágenes en distintos contextos. Colocando el foco en facilitar la actividad probatoria para acreditar la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, resulta interesante la idea de trasladar la segunda hipótesis del inciso primero al inciso segundo.

La redacción del Ministerio de Justicia, prosiguió, utiliza una fórmula interesante al separar los supuestos punibles, para distinguir, por una parte, la determinación a una persona menor de 14 años a la realización de acciones de significación sexual y, por otra, la ocurrencia de dos hipótesis distintas (inciso tercero). Sobre este último punto, puntualizó que la sola determinación a la persona menor de 14 años del envío, entrega o exhibición de imágenes o grabaciones de genitales debiera sancionarse prescindiendo del elemento subjetivo, por la gravedad de la conducta, incluso puede que la obtención de este tipo de imágenes tenga un fin comercial y no su satisfacción sexual, sino la de terceros.

La propuesta, entonces, sería coherente con las obligaciones del Estado orientadas a entregar protección efectiva a niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Moreno, aclaró que la letra b) propuesta por el Ejecutivo no describe conductas en que el adulto envíe imágenes, sino que determina a la persona menor de 14 años a enviarlas.

Sobre este punto, la Honorable Senadora señora Ebensperger enfatizó que, si bien es cierto que el menor es quien envía las imágenes, es un adulto quien lo determina a hacerlo.

El asesor señor Moreno agregó que si se elimina el ánimo especial, el supuesto punible podría cubrir aquellos casos en que los padres toman fotos de sus hijos durante el baño en un contexto familiar. Sin perjuicio de lo anterior, a su entender, se trata de un asunto de política criminal.

La Honorable Senadora señora Ebensperger acotó que el ejemplo anterior no se relaciona con el debate, que se centra en fotografías o imágenes con connotación sexual.

Enseguida, el asesor señor Moreno sostuvo que, si el acto tiene connotación sexual se trata de un supuesto cubierto por la letra a) propuesta, mientras que la letra b) se refiere a simples imágenes de genitales. Sobre la sugerencia de trasladar la segunda parte del inciso primero al inciso segundo, estimó que podría ocurrir que un padre que se encuentra viendo junto a su hijo una serie de televisión calificada para mayores de 18 años quede cubierto por dolo eventual. Ello plantea la dificultad de determinar si se encuentran o no en el supuesto normativo.

En lo tocante a la obtención de imágenes con un fin comercial, postuló que se trata de supuestos compatibles con la exigencia de un ánimo especial, porque éste puede verificarse para la excitación propia o la de otra persona. Si se recopilan imágenes de genitales con un fin comercial, el elemento subjetivo se cumple.

El Honorable Senador señor Walker apuntó que el verbo rector se mantiene en la propuesta del Ejecutivo, es decir, procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, en relación a acciones de significación sexual.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Defensora de la Niñez, refiriéndose a la letra b) del Ejecutivo, señaló que no sería coherente con los ejemplos dados (como la captura de fotos de índole familiar), porque la determinación del envío de una imagen de los genitales no puede sino tener un propósito relacionado con la búsqueda de la excitación sexual.

El Honorable Senador señor Galilea manifestó su preocupación por las hipótesis en que se dispone a un niño a ver material o espectáculos pornográficos, porque en la práctica las víctimas no son conscientes de lo que han vivido. En muchos casos, añadió, se descubre que los niños se encuentran hipersexualizados como consecuencia de estas experiencias. Por tal motivo, fue partidario de que esas hipótesis prescindan del elemento subjetivo adicional (un adulto jamás debe entregar imágenes de contenido sexual a un niño).

Consultado por el Honorable Senador señor De Urresti acerca del significado que debe dársele a la palabra “determinare”, el asesor señor Ferrada sostuvo que se utiliza como sinónimo de “inducir” o “influnciar”. El abuso sexual impropio, continuó, está organizado de manera tal que en el inciso primero el menor tiene una actitud de observador o espectador, mientras que en el inciso segundo se le determina a realizar un acto de significación sexual o a enviar imágenes. Por lo mismo, trasladar un supuesto del inciso primero al segundo genera dificultades, porque este último se refiere a acciones que realiza el menor. Con todo, dijo, eliminar el elemento subjetivo en ambas hipótesis no sería un problema.

En línea con el debate habido, el Honorable Senador señor Galilea planteó conferirle una nueva redacción a la disposición sugerida por el Ejecutivo, del siguiente tenor:

“Art. 366 quáter. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

La Comisión tuvo presente que en sesión celebrada el día 19 de julio se aprobó una indicación conforme a la cual, luego del término “material pornográfico” se agrega la expresión “o de explotación sexual”.

- La letra a) de la indicación N° 3, fue retirada por su autor.

- La letra b) de la indicación N° 3, fue aprobada con enmiendas y en los términos reseñados, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker.

□ □ □

Numeral 2)

Incorpora, a continuación del artículo 366 quáter, un párrafo VI bis, nuevo, cuyo epígrafe es “§ VI bis. Explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.”.

Indicación N° 4.-

Del Honorable Senador señor Walker, propone reemplazar, en el citado epígrafe, la palabra “pornografía”, por la frase “material de explotación sexual”.

Sobre la propuesta, el asesor señor Moreno advirtió que la terminología utilizada sólo afecta al articulado que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

contiene los delitos, por lo que no habría el mismo problema con el título. Incluso, adujo, podría contribuir a visibilizar este fenómeno, porque constituye una declaración de principios. Así las cosas, puede incorporarse la nomenclatura si se encuentra fundamento en el derecho a la infancia, sin afectar la normativa.

El Honorable Senador señor Walker hizo presente el acuerdo de consignar los términos “explotación sexual comercial” y “material pornográfico de niños niñas y adolescentes”.

En mérito del debate habido, la Comisión estuvo por reemplazar en el epígrafe del Párrafo VI bis propuesto, la palabra “pornografía”, por la expresión “material pornográfico”.

- Con dicha redacción y sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker.

Numeral 4)

Sustituye el artículo 367 por otro, para sancionar al que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años edad, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

La norma sustitutiva precisa, además, que la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de 31 a 35 UTM, si se perpetrare el hecho explotando a la víctima en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad.

Finalmente, entiende por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución.

Indicación N° 5.-

De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, propone acotar, en el inciso tercero del artículo sustitutivo propuesto, que la retribución sea “hacia el menor o un tercero”.

Los Honorables Senadores señores Walker y Galilea, fundados en el carácter obvio del propósito de la indicación, precisaron que el victimario puede pagar directamente a la víctima o a quien explota al menor.

El asesor del Ejecutivo señor Ferrada previno que el Código Penal no utiliza el concepto “niño, niña o adolescente”, razón por la que el Ejecutivo sugiere agregar, en la frase que se propone, el texto “hacia la víctima o un tercero”.

- Con dicha redacción y sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker.

Numeral 5)

Reemplaza en el artículo 367 ter el texto “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce años pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro”, por la frase “obtuviere la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución”.

Indicación N° 6.-

De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, propone agregar que la retribución sea “hacia el menor o un tercero”.

La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos planteó la conveniencia de incorporar la nueva terminología de manera de plasmar el cambio cultural sin afectar la aplicación práctica de la norma ni la labor del ente persecutor.

En concordancia con el criterio adoptado respecto de la indicación precedente, la Comisión decidió modificar la redacción de esta proposición para hacerla coincidente.

- Con dicha enmienda y sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Numeral 6)

Incorpora, a continuación del artículo 367 ter, nuevos artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies.

Artículo 367 quáter propuesto

En su inciso primero, sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo al que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

En su inciso segundo, castiga con la misma pena al que participare en la producción de dicho material pornográfico.

En su inciso tercero, sanciona con presidio menor en su grado medio al que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

En su inciso cuarto, entiende por “material pornográfico aquel en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años”, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Indicación N° 7.-

Del Honorable Senador señor Walker, propone reemplazar la palabra “pornográfico” por “de explotación sexual” en todo el artículo.

El Honorable Senador señor Walker estuvo por mantener en el texto la expresión “material pornográfico”, y, en sintonía con lo resuelto a propósito de la indicación N° 2, intercalar, enseguida, la frase “o de explotación sexual”, modificando además esta propuesta de manera de responder a una adecuada técnica legislativa.

- Sometida esta indicación a votación, fue aprobada con las enmiendas reseñadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker.

Indicación N° 8.-

De los Honorables Senadores señoras Aravena y Núñez, y señor Galilea, propone intercalar un inciso cuarto, nuevo, del tenor que sigue:

“Con todo, quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.”.

Con motivo del estudio de la indicación, el Honorable Senador señor Galilea subrayó que, en circunstancias que la legislación vigente no resuelve adecuadamente todas las hipótesis que pueden verificarse, la propuesta busca hacerse cargo del punto.

El asesor señor Ferrada adujo que la propuesta adolece de un problema de imputación de resultado, porque el mero hecho de ser dueño de una página web lo convierte autor y será responsable penalmente, cuando no necesariamente tendrá conocimiento del contenido de connotación sexual. Tal solución parece excesiva, arguyó, como forma de atribución de responsabilidad penal. Además, acotó, la propuesta plantea una suerte de responsabilidad objetiva, atendido que por el mero hecho de tener una página web el dueño será responsable, sin que sea necesario acreditar que hubo dolo al difundir material pornográfico. Así, en opinión del Ejecutivo, tal como está redactada la norma vigente se satisfacen los supuestos punibles, pues se sanciona al que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años de edad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Walker comentó que la indicación utiliza los mismos verbos rectores que el artículo 367 quáter vigente.

El Honorable Senador señor Galilea explicó que, pudiendo suceder que el dueño de una página web no tenga participación en el delito (por lo que debiese eliminarse de la propuesta), lo que pretende la indicación es que el administrador responsable de la página web, aunque no sea quien subió el material pornográfico, implemente políticas que impidan la ocurrencia de estos hechos (como se da en las plataformas de mayor envergadura, incluso en los sitios para adultos).

El asesor señor Moreno destacó que, siendo la indicación admisible si no existiera el actual inciso primero, las grandes plataformas digitales cuentan con políticas de prevención que impiden el almacenamiento de este tipo de contenido. En ese orden, continuó, cabe preguntarse qué ocurre entre el momento en que el material pornográfico es cargado y aquel en que el dueño o administrador toma conocimiento de ese hecho. Conforme a la indicación, sería responsable penalmente sin que exista una conexión subjetiva con el mismo. De allí que se genere un problema de imputación de responsabilidad, existiendo un vínculo contractual entre el responsable, la página web y un tercero que carga la información. En el lapso que tarda en advertirlo se verificaría responsabilidad objetiva.

El Honorable Senador señor Walker consideró pertinente eliminar la figura del dueño de la página, y destacó la importancia de que los administradores se hagan responsables del contenido e introduzcan modelos de compliance.

El Honorable Senador señor Araya opinó que el problema con los sitios web es que no se encuentran a cargo de una única persona: generalmente el administrador es un algoritmo, por lo que si alguien logra burlarlo no hay forma de enterarse hasta que otro lo denuncie. Incluso, plataformas como Facebook e Instagram con políticas muy estrictas, no son infalibles. En este marco, coincidió en que la indicación propone un tipo de responsabilidad penal objetiva, conforme a la cual el dueño o el administrador de un sitio puede desconocer que alguien subió pornografía infantil hasta que exista una denuncia, pero se convierte en responsable por un tercero que utilizó un servicio, lo que resulta cuestionable. Con todo, siendo proclive a la indicación, sugirió mantener la pena de multa, e incluso incrementarla. Para su redacción, estimó apropiado basarse en la asesoría de un experto en páginas web, para establecer a ciencia cierta la forma en que se organiza su estructura de propiedad y en que funcionan.

El Honorable Senador Galilea, coincidiendo en la conveniencia de eliminar la referencia al dueño de la página web y mantener únicamente la pena de multa, sugirió que el tipo sea complementado en términos tales que el sujeto activo sea quien “permita” que este contenido sea difundido o distribuido, pudiendo incluir un elemento subjetivo al tipo penal, para que, de este modo, este espacio intermedio quede resuelto.

El Honorable Senador señor Araya insistió en que, de sancionarse estos supuestos, la Comisión debería recibir la asesoría de expertos para determinar quién es el responsable de una página web, en concordancia con la ley sobre delitos informáticos y la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (si es el programador del hosting, el que autoriza subir contenidos o el que verifica que el hosting funcione). Por tales razones, una norma de esta índole no debería estar en este proyecto, toda vez que busca perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas (que sería su ámbito propio).

La Honorable Senadora señora Ebensperger puntualizó que si el administrador o responsable permite que esta clase de contenido se suba, quedaría cubierto por el artículo 367 quáter. Además, quien administra debería ser sancionado y responder por lo que pasa en esa página. En ese entendido, estuvo por mantener la propuesta, con una multa más alta. Si se agrega la voz “permitir”, adujo, se reiteraría el 367 quáter.

El Honorable Senador señor De Urresti señaló que se trata de una materia que debería regularse en la normativa relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y avanzar en la eventual aplicación de una multa. Para esto, acotó, sería necesario precisar la nomenclatura.

En concordancia con la idea de regular el tema en la normativa sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante una figura especial, el Honorable Senador señor Galilea anunció el retiro de la indicación.

El Honorable Senador señor Walker explicó que la conducta descrita en esta indicación, estaría incluida en el tipo penal del artículo 367 quáter.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, luego de abogar por mantener la indicación, señaló que una persona

Segundo Informe de Comisión de Constitución

natural también puede ser dueña de una página web y, a su vez, contratar un administrador, por tanto radicar esa responsabilidad sólo en las personas jurídicas dejará impune a las personas naturales que las administran.

El Honorable Senador señor Araya especificó que esas personas naturales serán sancionadas conforme a las reglas generales de participación, pudiendo ser encubridores o coautores del delito.

- Esta indicación fue retirada.

- - -

Cabe consignar que, en mérito de lo resuelto a propósito de la indicación N° 1, la Comisión, unánimemente, os propone reemplazar la denominación administrativa que se le ha dado a esta iniciativa, por la que sigue:

“Proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente consignados, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, os propone aprobar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, y aprobado en general por el Honorable Senado, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1.-

□ □ □

- Intercalar el siguiente número 2., nuevo:

“2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Art. 366 quáter. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

(Indicaciones N°s. 2 y 3 letra b). Aprobadas por unanimidad 4x0 y 5x0, respectivamente)

□ □ □

NUMERAL 2.

- Pasa a ser numeral 3., reemplazado por el siguiente:

“3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo VI bis, nuevo:

“§ VI bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de niños, niñas y adolescentes.”.”.

(Indicación N° 4. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

NUMERAL 3.

Pasa a ser numeral 4., sin otra modificación.

NUMERAL 4.

(Pasa a ser numeral 5.)

Artículo 367 sustitutivo propuesto

Inciso tercero

- Intercalar, luego de “retribución”, la frase “hacia la víctima o un tercero”.

(Indicación N° 5. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

NUMERAL 5.

(Pasa a ser numeral 6.)

- Intercalar, en la frase sustitutiva que se propone, a continuación de “retribución”, lo que sigue: “hacia la víctima o un tercero”.

(Indicación N° 6. Aprobada por unanimidad con enmiendas 5x0)

NUMERAL 6.

(Pasa a ser numeral 7.)

Artículo 367 quáter propuesto

- Intercalar, a continuación del vocablo “pornográfico”, todas las veces que aparece, la frase “o de explotación sexual”.

(Indicación N° 7. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

NUMERALES 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. y 16.

Pasan a ser numerales 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. y 17., respectivamente, sin otra modificación.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

A título ilustrativo, de acogerse las enmiendas reseñadas, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,”, e intercálase, entre el guarismo “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “ , 367 quáter, 367 septies”.

2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Art. 366 quáter. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo VI bis, nuevo:

“§ VI bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico

de niños, niñas y adolescentes.”.

4. Derógase el artículo 366 quinquies.

5. Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

“ART. 367. El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.”.

6. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero”.

7. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“ART. 367 quáter. El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

mismos fines.

ART. 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

ART. 367 sexies. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

ART. 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

ART. 367 octies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

8. Reemplázase en el encabezado del Párrafo VII del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

10. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

11. Elimínase en el inciso primero del artículo 368 ter la expresión “366 quinquies,” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

12. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

13. Elimínase en el inciso primero del artículo 369 ter la expresión “366 quinquies,” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

14. Sustitúyese en el artículo 369 quinquies el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

15. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

16. Reemplázase en el artículo 372 incisos segundo y tercero el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

17. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

2. Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Reemplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por la expresión “367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,”, y agrégase, a continuación del guarismo “367 ter”, lo siguiente: “ , 367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 13 de julio de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 19 de julio de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 16 de agosto de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial.

Sala de la Comisión, a 18 de agosto de 2022.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

* El presente informe se suscribe sólo por el Abogado Secretario de la Comisión, en virtud del acuerdo de Comités de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín N° 14.440-07).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: Propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial, cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

II. ACUERDO: Según se señala:

Indicación N° 1.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 2.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 3, letra a).- Retirada.

Indicación N° 3, letra b): Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 4.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 5.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 6.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 7.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 8.- Retirada.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: Esta iniciativa contiene siete artículos, el primero de los cuales se compone de dieciséis numerales y el segundo de dos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Suma.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 14 de diciembre de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. Discusión en particular.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) Código Penal.

b) Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

c) Ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

d) Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

e) Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

f) Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

Valparaíso, 18 de agosto de 2022.

Discusión en Sala

2.5. Discusión en Sala

Fecha 06 de septiembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 51. Legislatura 370. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.

INCORPORACIÓN DE NUEVO PÁRRAFO EN CÓDIGO PENAL RELATIVO A EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Señor Secretario , continuamos con el próximo proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, Presidenta .

La señora Presidenta pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.440-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto fue aprobado en general en la sesión del 10 de mayo del presente año y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Para los efectos reglamentarios, dicha Comisión deja constancia de que el artículo 1, numerales 1, 3 (pasa a ser 4), 7 (pasa a ser 8), 8 (pasa a ser 9), 9 (pasa a ser 10), 10 (pasa a ser 11), 11 (pasa a ser 12), 12 (pasa a ser 13), 13 (pasa a ser 14), 14 (pasa a ser 15), 15 (pasa a ser 16) y 16 (pasa a ser 17), así como también los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto, no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

La referida Comisión, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Finalmente, y en mérito de los acuerdos adoptados, la Comisión unánimemente propone reemplazar la denominación administrativa dada a esta iniciativa por la siguiente: "Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes".

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Secretario .

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Matías Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar el proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, y para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia en calidad de "suma".

La iniciativa en estudio tiene por objeto propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 14 de diciembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Entre las modificaciones más importantes que establece este proyecto de ley destacan las siguientes.

En relación con el nombre de la iniciativa, la Comisión acordó sustituirlo por el siguiente: "Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes".

Se reformula la tipificación contenida en el artículo 366 quáter, relativo al abuso sexual sin mediar contacto corporal, distinguiéndose entre las siguientes conductas:

-El que realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo (341 días a cinco años).

-El que determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante de él o de otro, o le hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual, o presenciar espectáculos del mismo carácter, será sancionado con presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años).

-Será castigado con presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) el que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representen acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad. b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.

Se incorpora un párrafo VI bis, nuevo, en el Título VII del Libro II del Código Penal, denominado "Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes".

Se deroga el artículo 366 quinquies, que sanciona a quien participare en la producción de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de dieciocho años, para regularse en forma más detallada posteriormente en los artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies, que se proponen en este proyecto de ley.

Se sustituye el artículo 367, que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años.

Con esta enmienda, si se perpetrare el hecho explotando a la víctima en razón de su dependencia personal o económica, o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y una multa de 31 a 35 unidades tributarias mensuales.

Esta norma, además, entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de

Discusión en Sala

retribución hacia la víctima o un tercero.

En el artículo 367 ter se incorpora como elemento del tipo el que obtuviere la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier clase de retribución hacia la víctima o un tercero.

Se incluye una serie de artículos en el referido Código, a saber:

-El artículo 367 quáter, que sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo al que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera que sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

Con la misma pena se sanciona al que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

Asimismo, castiga con presidio menor en su grado medio al que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera que sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

Para tales efectos, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

-El artículo 367 quinquies, que considera cometidas en Chile las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

-El artículo 367 sexies, que declara no aplicable este nuevo párrafo "si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante".

-El artículo 367 septies, que sanciona con presidio menor en su grado máximo al que "usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual por parte de una persona menor de dieciocho años".

-El artículo 367 octies, que precisa que para determinar la clase de reincidencia de la circunstancia N° 16ª del artículo 12 en esta clase de delitos, también se considerarán las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.

El artículo séptimo del proyecto regula diversos efectos de la ley y el tiempo, a saber: "Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración".

Si la ley entra en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de esta ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación resulta más favorable se deberán considerar todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en esta normativa, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Es todo cuanto puedo informar, estimada Presidenta .

Discusión en Sala

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidenta.

Una forma de medir a las sociedades es mirar cómo tratan a sus miembros más débiles, y claramente nuestros niños y nuestras niñas son quienes merecen mayor protección de parte de la comunidad. No hay nada más deleznable que la invasión o la intromisión en su esfera de intimidad y, especialmente, en su esfera sexual.

La pedofilia, como perversión, ha sido una constante a través de la historia, pero lo nuevo es que la tecnología se ha sumado como elemento que facilita la transmisión y acumulación de datos que dicen relación con la pornografía infantil.

Ya se sanciona el almacenamiento de material pornográfico infantil y su distribución, pero siempre quedan zonas grises que son aprovechadas por la peor casta de delincuentes, escoria humana: aquellos que matan la inocencia de nuestros niños y niñas, en especial de los más desposeídos, de los más pobres.

Un aspecto fundamental de este proyecto es que no solo pretende regular la explotación infantil, sino también modificar las normas para sancionar con mayor eficacia la exposición de menores de catorce años a material de contenido sexual, como lo que ocurrió en Valparaíso el último fin de semana, donde en medio de un acto de campaña política "familiar" -se decía- se llevó a cabo un acto de clara índole sexual, de pésimo gusto, claramente inclinado a insultar los símbolos y valores patrios. Con el artículo 366 quáter esos "artistas" serían objeto de una sanción penal más severa.

Cuesta entender qué impulsa a ciertos seres humanos a actuar de una manera tan artera y atentatoria. Cuesta leer el informe sin que produzca asco o repulsión el tema tratado, pero, asimismo, es esperanzador que se pongan en movimiento las ruedas del poder legislativo con el fin de sancionar de manera eficaz delitos tan graves.

A quienes tenemos la bendición de ser padres siempre nos asiste la preocupación por velar por nuestros hijos. Queremos verlos crecer, desarrollarse, ser libres y que una vez llegado el momento emprendan libres el vuelo hacia su propio destino. La ley está para proteger ese sueño, para cimentar ese vuelo, para sancionar a aquellos monstruos, porque eso son: monstruos que usan o abusan de la inocencia de nuestro tesoro máspreciado, o lo exponen a contenido indeseable para su edad e inocencia.

No podemos ser tolerantes con aquellos que profitan o que, solo pensando en su propio beneficio o placer, denigran o abusan de los más inocentes entre los inocentes.

Un Estado que no protege a los niños no sirve y esto debe incluir, por supuesto, al que está por nacer. Todos tienen el legítimo derecho a ser protegidos.

Me parece que este es un avance y entre tanta crítica en contra del Congreso es importante; creo que alimenta el alma poder apoyar un proyecto de esta naturaleza en forma transversal.

Voto a favor de esta iniciativa y de las modificaciones hechas en la discusión en particular. Y espero que sea un instrumento eficaz para impedir este abuso que cada día aumenta y que estas armas legislativas, jurídicas tratarán de controlar.

Voto a favor.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Solicito el acuerdo de la Sala para que la Senadora Rincón me reemplace unos minutos, por favor.

Discusión en Sala

(La señora Presidenta hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

(Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón).

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidenta .

Con la presentación de este proyecto de ley se busca recoger las sugerencias que los diferentes actores institucionales y la sociedad civil han venido desarrollando durante los últimos veinte años y que se han plasmado en distintas iniciativas, siendo una de las más relevantes la generación de estrategias intersectoriales conocidas como "Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes".

Nadie puede restarse de condenar todas las actividades ilícitas en las cuales, por medio de engaños o de la promesa de intercambio de bienes, nuestros niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos y comprometida su inocencia a tan temprana edad.

Rechazo cada situación en la que se utiliza a los menores en beneficio de un adulto, rechazo a quienes sabiendo el contexto que hay detrás se hacen partícipes de semejantes violaciones a los derechos humanos. Y espero para quienes componen bandas e incurrir en este tipo de delitos un procedimiento de investigación penal y sanciones que efectivamente ayuden a desincentivar su perpetración; y que sean castigados con condenas ejemplares según cada caso, porque se trata de personas que se aprovechan del estado de vulnerabilidad, pobreza y muchas veces de soledad por la que pasan nuestros niños.

Valoro profundamente que esta iniciativa, entre otras cosas, quite todo atisbo de voluntariedad de nuestros niños, niñas y adolescentes que sufren esta vulneración de derechos mediante las acciones descritas y que se castigan aquí.

Me entristece como Senador, como vecino, pero sobre todo como padre que este tipo de acciones, lamentablemente, sigan ocurriendo en nuestro país. Pero tengo la esperanza de que este nuevo título que se agrega al Código Penal contribuya a la disminución de estos actos contrarios a la ley y espero que en algún minuto sea una situación que no se repita en Chile.

La realidad nos llama a reforzar el Código y las sanciones contra quienes incurran en la perpetración de estos delitos.

Desde ya manifiesto mi voto a favor para avanzar en la legislación particular y así lograr desincentivar este delito y condenarlo debidamente en cualquier estado de perpetración.

Gracias, Presidenta .

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta .

Fue muy gratificante aprobar en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, que tengo el honor de presidir, la mayoría de los artículos de este proyecto, como antes lo hicimos en la Cámara de Diputados. Proyecto que, por cierto, establece un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Y es bueno explicar esto en la Sala del Senado a quienes se enfrentan por primera vez a esta iniciativa.

Discusión en Sala

No corresponde hablar de "pornografía infantil"; corresponde hablar de "explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes". Obviamente, ellos no se exponen voluntariamente a ser grabados, a ser víctimas de material pornográfico. Son explotados por adultos. De ahí la sanción que corresponde a este tipo penal.

Además, y por lo mismo, no corresponde hablar de "pornografía", sino que de "material pornográfico infantil". Así como tampoco corresponde hablar de "prostitución infantil" o de "prostitución de niños, niñas y adolescentes"; debemos hablar de "explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes".

Quiero valorar en este proyecto los aportes que recibimos de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz . La verdad es que el aporte de la Defensoría de la Niñez, tanto en la Cámara como en el Senado, en la Comisión de Constitución, fue muy relevante a los efectos de poder perfeccionar y abarcar todos los tipos penales.

Yo recuerdo, Presidenta , cuando se dictaron las primeras leyes que sancionaban la pedofilia en nuestro país, cómo los teóricos del derecho penal criticaban al Congreso Nacional y encontraban que era una exageración sancionar el almacenamiento, la producción de material pornográfico infantil. El tiempo ha demostrado la importancia de establecer esta sanción penal. Si alguien adquiere material pornográfico infantil, se transforma automáticamente en cómplice de esa explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Por eso es que este proyecto sanciona con penas muy severas a quienes, valiéndose de la dependencia económica que tienen niños, niñas y adolescentes de los adultos, los explotan sexualmente, sobre todo de manera permanente. Se consideran penas altísimas, como tiene que ser.

De ahí la importancia de extender el ámbito de la territorialidad y de la extraterritorialidad en la aplicación de esta ley. Porque acá hay verdaderas mafias y crimen organizado que se dedican a la producción de este material pornográfico infantil a través de la explotación de niños, niñas y adolescentes, que después distribuyen a través de internet. Por eso es tan importante el aspecto de la extraterritorialidad.

Yo, Presidenta , quiero sugerirle y pedirle a la Sala del Senado que aprobemos en particular este proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Constitución, y que signifiquemos la importancia de proteger de verdad a los niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidenta .

Desde el año 2014, según se nos informó en la Comisión, se han presentado 114 querellas por lo que se denominaba "prostitución infantil"; 97 de las cuales estaban relacionadas básicamente con mujeres, con niñas menores de dieciocho años.

Tal como se ha dicho antes, el tema de la prostitución en el Código Penal estaba tratado de una manera que resultaba un poco equívoca. Porque el solo concepto de la prostitución generaba -lo dijo el Senador Walker antes que yo- la percepción de que había una cierta voluntariedad en la persona que se prostituía, porque estaba de acuerdo en cobrar o en cualquier circunstancia que justificara ese camino de la prostitución.

Por lo tanto, buena parte de este proyecto de ley, iniciado en el Gobierno del Presidente Piñera, y que espero que aprobemos luego, tiene que ver con precisar estas figuras. Aquí no hay espacio para segundas miradas, para decir: "Bueno, pero si ella o él de alguna manera querían, aceptaban". ¡No! En los menores de dieciocho años aquí no hay dobles miradas. Esto se trata de una explotación sexual completamente indebida.

En consecuencia, el proyecto busca justamente eso: precisar penas, conductas, aclarar cuándo puede haber un dolo subjetivo y cuándo la conducta es absolutamente objetiva. En eso la Comisión se detuvo bastante rato.

Discusión en Sala

Revisamos tipo por tipo. Modificamos algunos tipos desde un área subjetiva, los llevamos a la objetividad, porque lo que queríamos evitar y además aclarar era cuáles son las conductas que no se pueden permitir y cuáles son las conductas sancionadas.

En mi vida me ha tocado, por diversas situaciones, conocer casos de abuso sexual. Y fíjese, Presidenta, que casi todos nacen de una hipersexualización de los menores, que se da a través de imágenes, de espectáculos, de obligarlos a presenciar cuestiones que no debieran ver ni escuchar jamás a una determinada edad. Y eso hace que finalmente todas esas niñas y esos niños terminen siendo sumamente vulnerables a la explotación sexual.

Por consiguiente, todos estos tipos los hemos querido precisar. Se hicieron algunas sugerencias, aceptadas finalmente también por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y creemos que es un gran aporte en el camino hacia la protección de nuestras niñas y niños.

Por eso, Presidenta, voto a favor de este proyecto en todas sus partes.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

En marzo del 2022, entró en vigencia la Ley sobre Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. En su artículo 37 el Estado de Chile reconoce, por primera vez, la protección contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Nuestro país ha adherido a todas las declaraciones oficiales y a los llamados a la acción de los tres congresos mundiales contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (Estocolmo, 1996; Yokohama, 2001, y Brasil, 2008). Sin embargo, solo catorce años después, en la Ley de Garantías de la Niñez, se la consideró como "violación de sus derechos humanos", y el Estado asume como su deber su protección.

La referida ley define la explotación sexual comercial infantil como "la utilización de los niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de remuneración en dinero o especies al niño, niña o adolescente, o a terceras personas. Constituye una forma de coacción y violencia contra los niños, niñas y adolescentes y una forma contemporánea de esclavitud".

Asimismo, el Estado se comprometió a adoptar medidas para combatir, en especial:

1. La tolerancia hacia la explotación sexual, tanto por parte de la población nacional como extranjera.
2. La compra de sexo de niños, niñas y adolescentes que realizan adultos en espacios públicos como parques, calles, playas o locales comerciales como clubes nocturnos, bares y hoteles.
3. Los intermediarios, negocios y redes organizadas de explotadores.
4. La producción de pornografía infantil.
5. El aumento del uso del Internet para la divulgación de pornografía infantil y la promoción del turismo sexual.
6. El tráfico de personas menores de edad con fines sexuales y comerciales.
7. La impunidad de explotadores sexuales nacionales y extranjeros.
8. Cualquier otra forma en la que se manifieste la explotación sexual comercial infantil.

Discusión en Sala

En este contexto legislativo, la aprobación del presente proyecto de ley resulta imprescindible y urgente.

La iniciativa incorpora en el Código Penal un párrafo nuevo relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, haciendo un reconocimiento expreso de este fenómeno delictual específico.

Con ello se elimina del Código Penal el concepto de que los niños, niñas o adolescentes pueden "prostituirse" como un acto voluntario y propio.

Celebramos que se aumente la pena para que la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes sea considerada un crimen.

En tal sentido, se eleva la sanción para tal delito de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo: cinco años y un día a diez años. Si se les explota en razón de su dependencia personal o económica o si concurre habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, de cinco hasta veinte años.

En esta hipótesis agravada, se elimina el acceso al beneficio de penas sustitutivas, y en todos los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se elimina el acceso al beneficio de libertad condicional; se incorpora un agravante especial para funcionarios públicos; se establecen, además, normas especiales de reincidencia; se aplican a estos delitos las técnicas especiales de investigación, y se otorga el carácter de imprescriptible a la acción penal.

Sin lugar a dudas, es una tremenda pero tremenda iniciativa.

Queda pendiente un esfuerzo presupuestario para hacer efectivo el deber del Estado de reparación del daño a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, dado que el artículo 51 de la Ley de Garantías les reconoce el derecho a su recuperación física y psicológica, y a la plena integración social y educativa.

No podemos sino que respaldar la iniciativa, pero poniendo un foco de atención en este pendiente.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidenta.

Quiero valorar el proyecto que estamos votando en este minuto, puesto que marca un hito en la resignificación del fenómeno a partir de la eliminación de la concepción jurídica de la "prostitución infantil" como un acto voluntario y no como una explotación sexual infantil.

Además, aumenta las penas para ciertas figuras jurídicas, equiparándolas a otras formas más graves de explotación.

Pero también quiero destacar que la iniciativa contempla la consideración de que niños, niñas y adolescentes son víctimas y no meros prestadores de servicios, lo que obviamente permite un enfoque particular de las situaciones de abuso, y esperamos que ayude en la persecución del delito por parte de las policías como del Ministerio Público.

Hay que recordar que el proyecto se basa precisamente en las recomendaciones del Tercer Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondiente al período 2017-2019, y obedece a una serie de compromisos intersectoriales que el Estado de Chile ha ido suscribiendo para avanzar progresivamente en el afianzamiento de las garantías de las personas menores de edad.

Y también cabe señalar que en su discusión participó con mucha fuerza la sociedad civil.

Discusión en Sala

Quisiera destacar, a modo de contextualización, que la explotación sexual comercial infantil y adolescente es considerada en el mundo como una moderna esclavitud y constituye una de las más graves expresiones de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y según calcula las Naciones Unidas, afecta a más de un millón de niños, niñas y adolescentes en el mundo.

De acuerdo al Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil del año 96, el fenómeno se puede definir como "una violación fundamental de los derechos de la niñez" y abarca el abuso sexual por parte de un adulto, con el fin de obtener una remuneración en dinero o en especie para el niño, la niña, o para un tercero.

Los niños, niñas y adolescentes son tratados como un objeto sexual y como una mercancía bajo condiciones de manipulación y coerción. Además, "equivale al trabajo forzado y es una forma contemporánea de esclavitud", según Camacho y Trujillo en una publicación del año 2009.

En Chile, de acuerdo a un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, se estima que 3 mil 719 niños, niñas y adolescentes al menos son víctimas de explotación sexual y comercial, cuyas edades oscilan entre los diez y los dieciocho años y donde el 80 por ciento son mujeres. Y hasta hoy, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no estaba tipificada en nuestro país como delito, ya que en nuestro Código Penal se la concibe como "prostitución infantil", un concepto totalmente inadecuado, como han dicho Senadores y Senadoras que me ha antecedido.

De ahí que consideramos que la posibilidad de proteger el bien jurídico de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes resulta fundamental en este proyecto.

Por lo mismo, no solo vamos a votar a favor, sino que nos parece que va en la línea absolutamente adecuada en materia de modernización de nuestras legislaciones y en el establecimiento de un enfoque con transformación cultural que permita considerar a niños, niñas y adolescentes como víctimas en las prácticas descritas.

Queremos destacar también la innovación en materia de la conocida hasta ahora como "pornografía infantil" y no como material de pornografía que se produce con la utilización de niños y niñas.

Quitarle cualquier acto de voluntariedad a lo descrito por parte de los y las menores de dieciocho años nos parece fundamental para poder proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes.

Esperamos que los cambios que se están realizando mediante la presente legislación y conforme a todas aquellas en las cuales hemos estado modernizando la concepción de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, contra mujeres, contra personas diversas y disidentes sexogenericamente, constituyan un avance que nos permita estar a la altura de los compromisos internacionales y de las mejores legislaciones a nivel mundial.

Voto a favor, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidenta.

Como aquí se ha dicho, este proyecto, que fue ingresado a tramitación en junio de 2021, nace de una evaluación de nuestra legislación, la cual no contemplaba una tipificación adecuada para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ya que la circunscribía dentro de los actualmente denominados "delitos de favorecimiento de la prostitución infantil" y obtención de servicios sexuales de menores de edad, o favorecimiento impropio.

Este proyecto, entonces, "re-significa" el fenómeno, ya que descarta el concepto de "prostitución", según el cual

Discusión en Sala

existiría la voluntad -la voluntad,¡- de los niños, niñas y adolescentes para la realización del acto sexual por una remuneración, y enfatiza, por el contrario -y es lo relevante y nos pone al día con la legislación internacional-, que es una forma de abuso, de explotación de las condiciones de los niños y niñas, quienes, por cierto, deben ser protegidos; es decir, a los niños, niñas y adolescentes se los califica como víctimas y no como prestadores de servicios.

Lamentablemente, tengo que decirlo aquí, es un tema contingente.

Hace algunos meses, la PDI desbarató en Viña del Mar una red de explotación sexual de la Región de Valparaíso, mediante la cual algunos sujetos captaban a menores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad para trasladarlos a domicilios para su abuso y explotación. Una de las personas involucradas tenía incluso un orden de detención internacional por los delitos de violación y tráfico de drogas en Perú y Argentina.

Por eso, el proyecto claramente está bien encaminado para poner fin a los mencionados abusos y brindar la debida protección que les debemos a los niños, niñas y adolescentes.

Y la operación denominada "Orión", desarrollada por la PDI y la Fiscalía y que incluyó cerca de setenta investigaciones a lo largo del país, permitió localizar y detener a casi cincuenta y cinco sujetos por pornografía infantil.

Los medios de comunicación daban cuenta de la captura de diecinueve personas en la Región Metropolitana, de trece en Valparaíso, de seis en Antofagasta y el resto en diversas regiones.

Es el camino que debemos seguir para evitar por todos los medios que estos niños, niñas y adolescentes sean explotados.

El proyecto también aumenta las penas para ciertos delitos, equiparándolas con otras formas graves de explotación.

Y, como ya decíamos, contempla a estos niños, niñas y adolescentes como víctimas y no como prestadores de servicios.

Valoro además que las modificaciones de la iniciativa hayan recogido planteamientos hechos por la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público.

Destaco especialmente el tratamiento diferenciado que se tendrá en el Código Penal respecto a los niños y niñas, en relación con el tratamiento general de algunos delitos sexuales. No es menor que con la creación del nuevo párrafo 6 bis vamos a tener un párrafo denominado "Explotación sexual comercial y material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes". Será un delito con tipología propia, lo cual está en concordancia, como decíamos, con las formulaciones de diversos organismos internacionales, entre los cuales, por cierto, se destaca la Unicef.

Además, se adecuaba la legislación respecto a nuevas formas de afectación de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, para aquellos casos en que no existen soportes, ya que con el avance de la modernidad pueden darse situaciones en que pueden producirse afectaciones mediante la utilización de plataformas de videollamadas, donde no necesariamente se "graban" videos o audios.

En cuanto a las reincidencias -esto es importante-, se establece que para configurar la agravante de reincidencia se puedan hacer valer las condenas en el extranjero, lo cual es sumamente relevante, considerando la dimensión transnacional de algunos delitos como la pornografía y la explotación de niños, niñas y adolescentes.

No puedo dejar de mencionar, lamentablemente, que hemos fallado a niños, niñas y adolescentes tanto en la Región de Valparaíso como a nivel nacional. Hay 11 casos a lo menos en Valparaíso y 165 a nivel nacional, y el mismo número de querellas se han presentado durante este año en la Región de Valparaíso y en el resto del país.

Presidenta, apoyaré esta iniciativa, porque creo que no podemos seguir fallándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Creo que debe ser una de nuestras principales prioridades políticas, y quienes ejercemos funciones públicas no podemos sino protegerlos y orientarlos para que tengan un buen y pleno desarrollo.

Discusión en Sala

He dicho, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL .-

Muchas gracias, Presidenta .

Sin duda que el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes es un acto abominable desde todo punto de vista. Y nadie, por cierto, puede quedar indiferente frente a circunstancias tan graves y que dejan tantas huellas.

Los últimos efectos producidos por la pandemia, los encierros y otras tantas cuestiones más han generado igualmente un incremento de las denuncias por situaciones de esta naturaleza.

El Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Walker, al informar sobre el proyecto se refería precisamente a la necesidad de hacer algunas correcciones conceptuales que son absolutamente válidas.

Aquí hay un cambio de enfoque, toda vez que se establece que no existe la prostitución infantil, sino que la explotación sexual infantil; no existe la pornografía infantil, sino la explotación sexual para producir material pornográfico, donde se expone a niños, niñas y adolescentes. Es algo gravísimo. Y ambas figuras se están incorporando mediante la presente legislación. Como bien señalaba el Senador, nos estamos poniendo al día como país.

Quiero recordar, a propósito del Senador Walker, a su hermano Patricio Walker , quien durante mucho tiempo hizo su bandera de lucha la presentación de diversas iniciativas que apuntaban, precisamente, a la protección y al resguardo de los niños, niñas y adolescentes de los abusos a los cuales están expuestos.

Quisiera, por su intermedio, Presidenta , que su hermano le hiciera llegar a Patricio nuestro reconocimiento por esas secuencias de trabajo realizadas en el pasado.

Desde el año 2017 hasta la fecha, ha habido un incremento sustantivo de las cifras vinculadas al contexto de la explotación sexual, las cuales, según datos del Ministerio Público, han experimentado significativos cambios a propósito de los problemas del encierro, de la pandemia y por otras situaciones de similar naturaleza.

Aquello también se debe a una falta de normativas que protejan a los menores en el país. Y como ha señalado la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), organización que resguarda los derechos de los niños y jóvenes, también las razones pueden deberse al aumento de la pobreza y a la falta de oportunidades, que incrementan el número de explotadores sexuales infantiles, que primero, seducen, y luego, explotan.

En el ámbito de la Comisión de Familia, en la Cámara de Diputados, me tocó iniciar los procesos de discusión de la llamada "Ley de Garantías de la Niñez", donde el tema estuvo ampliamente presente en los debates.

Y el presente proyecto, junto con felicitar a sus autores, a sus mocionantes, nos pone efectivamente en una condición distinta en nuestro país. Porque considerar las falencias que existen en nuestra legislación penal al respecto, sin duda que es importante para avanzar.

Junto con felicitarlos, este tema nos debe exponer y comprometer absolutamente a todos. No hay acto más abominable que el abuso sexual al que pueden verse enfrentados niños, niñas y adolescentes, y el avance del proyecto nos permite dar un paso hacia una protección completamente necesaria y fundamental para nuestro país.

Voto a favor, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidenta .

Yo quiero valorar, en primer lugar, a los autores de una iniciativa que consideramos importante para el país.

Quienes hemos sido parlamentarios por varios períodos hemos sido testigos en nuestras regiones de situaciones dolorosas, abominables que ocurren por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Quisiera señalar que el primer caso que me correspondió alguna vez recibir en mi oficina parlamentaria de Puerto Varas fue la de un profesional de la salud veterinaria, de Fresia, que violentaba sexualmente a los hijos de los campesinos que le trabajaban el fundo, quien fue condenado a diez años de prisión gracias a las denuncias que realizamos y a que la justicia actuó allí de manera drástica.

Fue una de las primeras condenas a diez años, cuando en Chile las penas para este tipo de delitos eran mucho menores.

Hoy es un día que nos preocupa, porque en este mismo momento, mientras discutimos este proyecto de ley, se dio a trámite la admisibilidad del recurso de nulidad que presentó la defensa de Martín Pradenas. Esperamos que ahora no pase lo mismo que ocurrió con el hijo de un connotado parlamentario, que pudo eludir la justicia después de que todo el país sabía el delito que había cometido.

Martín Pradenas también abusó de menores, y espero que si se llegase a anular ese juicio, aquello signifique que se pueda llegar a la cadena perpetua efectiva, que fue una de las cosas que, de una u otra manera, pidió la Fiscalía.

En Puerto Montt tenemos el caso de abogados, profesionales, que contaban con una red de explotación sexual, incluso algunos de ellos se arrancaron del país y fueron aprehendidos en Paraguay.

Pero el caso más doloroso de los últimos años ocurrió también en la capital regional, en donde un falso militar se presentó en distintas escuelas de Puerto Montt ofreciendo cursos de alta montaña para disciplinar y dar nuevas oportunidades a niños, niñas y adolescentes, quien fue condenado recientemente a presidio perpetuo por abuso sexual, estupro y violación de nueve menores de edad, todas ellas sacadas de sus establecimientos educacionales a vista y paciencia de directores y de autoridades de educación.

Respecto a este caso, que es tremendamente doloroso, yo quisiera preguntarles a mis cuarenta y nueve colegas Senadores si lo conocían; los de la Región, por cierto que sí. Pero yo me atrevo a señalar que la mayoría no lo conocía porque no ocupó las portadas nacionales, porque si hubiera ocurrido en Santiago o en regiones del centro habría sido distinto el trato dispensado. Pero aquí hubo de todo: se abusó del contexto de vulnerabilidad y violencia intrafamiliar de las víctimas; del contexto social; hubo manipulaciones, coacciones y abuso psicológico sobre los menores; negligencia y abandono de las instituciones que debían proteger a estos menores, y, por cierto, un sistema judicial que se demoró años en impartir justicia, a pesar de que se habían hecho denuncias muchos años atrás.

¿Cómo es posible que este tipo de abusos hayan ocurrido y se hayan mantenido durante tanto tiempo? Las respuestas, por cierto, pueden ser múltiples y variadas, pero lo importante es que el proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo va a sancionar más drásticamente este tipo de delitos, sobre todo la producción de material pornográfico infantil. Se aplicarán penas más severas a quienes cometan estos delitos abominables, que toda nuestra sociedad debe condenar. Y ojalá que siempre la justicia actúe en función de esos objetivos.

Aprovecho la ocasión de agradecer en esta Sala la deferencia que tuvo la Senadora Ximena Órdenes , quien puso urgencia a un proyecto de nuestra autoría, que estuvo parado tres años en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados -no lo quiso tratar ni siquiera en plena pandemia -y que aprobamos en general aquí en la Sala, cuya finalidad es que nunca más profesionales conductores condenados por abuso sexual puedan manejar un vehículo del transporte público mayor o menor de nuestro país.

Discusión en Sala

Todo esto en función de un caso tremendamente doloroso ocurrido con una estudiante de catorce años de Puerto Montt, que fue violentada sexualmente en las cercanías del Estadio Regional de Chiquihue por un chofer de una línea de colectivos que llegó a dicha ciudad con una condena por abuso sexual y que siguió cometiendo ese tipo de delitos con los pasajeros, en este caso, menores de edad.

Señora Presidenta, obviamente que votamos a favor... .

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

Obviamente, votamos a favor de este proyecto.

Creemos que le hace bien a Chile tener sanciones más duras para este tipo de delitos y seguir ampliando todos aquellos elementos que conduzcan a que ojalá, como decían algunos Senadores acá, este tipo de conductas de pedofilia o explotación sexual, que siempre han existido en la historia pero que hoy se han visto incrementadas producto de la tecnología, puedan ser objeto de sanciones ejemplificadoras.

He dicho, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidenta.

La verdad es que esta iniciativa no solamente es importante, sino que se enmarca en lo que fue el Acuerdo Nacional por la Infancia. Porque cuando uno mira la cantidad de proyectos de ley que han logrado surgir de ese acuerdo puede realmente sentirse orgulloso al constatar que la política, cuando privilegia los intereses colectivos y las urgencias sociales, logra cambios importantes.

Lo cierto es que ya no solo dejó de existir el Sename, no solamente ya se creó un nuevo servicio que separa a los niños infractores de los vulnerados en sus derechos, llamado "Servicio Mejor Niñez", sino que además hace pocos días aprobamos el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil, que busca darles a los niños infractores un estándar de vida que les permita reinsertarse efectivamente.

El proyecto de ley que analizamos hoy día, que busca tipificar y perseguir el delito de la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, se enmarca dentro de las noventa medidas de la agenda de infancia.

Por eso es tan relevante que lo saquemos y aprobemos rápido, porque desgraciadamente uno de los elementos más dolorosos de la vulneración de los derechos humanos de nuestros niños en Chile radica en que muchas de estas redes se construyeron desde la realidad de niños vulnerados en sus derechos en la red del Estado y que supuestamente los debía proteger.

Por lo tanto, la arquitectura transversal de la agenda de infancia y del acuerdo nacional no solo contemplaba la persecución penal y la tipificación de este delito, que es lo que estamos haciendo hoy día, sino también mejorar la labor de la Fiscalía, de las policías, para perseguir de manera efectiva el crimen organizado de aquellos que utilizan a menores de edad, logrando que puedan pagar con penas de cárcel ejemplares, y desbaratar las bandas que han transformado, desgraciadamente, en un negocio la vulneración y la violación de los derechos humanos de estos niños.

Me alegra y valoro que hoy día podamos seguir poniéndole prioridad a proyectos que vienen ingresados desde el año pasado, que efectivamente son parte de esta agenda de la infancia y que van conformando el cumplimiento de los acuerdos que en su minuto asumimos cuando dijimos "Los niños tienen que estar primero en la fila".

Por lo tanto, no es una política pública, no es una medida, sino que son noventa.

Discusión en Sala

Y este proyecto de ley va en esa línea.

Así que no solamente lo voto a favor, sino que celebro que hoy día el Congreso vaya construyendo en estas materias un gran sentido de urgencia y de unidad.

Se valora que en este tema tengamos todos una misma mirada y que los Comités, cuando les toca definir las tablas, vayan poniendo estos proyectos con urgencia.

Voto a favor, Presidenta , y espero que el tercer trámite, que viene después de esta aprobación, también pueda realizarse con celeridad.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Este proyecto de ley tiene por objeto dar un adecuado marco de protección a las víctimas de explotación sexual cuando estas son niños, niñas y adolescentes, creando un nuevo párrafo relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, e incorporando las condiciones legales necesarias para combatir con efectividad este tipo de delitos que afectan a los menores de edad en nuestro país y que ocurren cotidianamente.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, los delitos sexuales, en especial los que tienen como víctimas a menores de edad, han aumentado y debemos ser consecuentes con un compromiso para combatirlos.

Además esto responde a un tema estructural, pues los niños y niñas no cuentan en Chile con una ley de protección integral de derechos o de garantías, que les asegure protección y prevenga vulneraciones.

En ese contexto, se ha vuelto una prioridad proteger los derechos de los niños frente a la realidad, más aún considerando que la explotación sexual es una forma de esclavitud, razón por la cual no se puede hablar de prostitución infantil. La prostitución, se supone, es por definición un acto voluntario absolutamente distinto a la situación de los niños que se ven forzados al comercio sexual.

Tan es así que las víctimas más frecuentes de este tipo de delitos son menores de catorce años.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en las gestiones de los años 2020 y 2021 se puede observar un progresivo aumento de casos cuyas víctimas son menores de edad. Y en ese universo el 85 por ciento son mujeres.

En ese marco el proyecto de ley persigue aumentar las penas e incorporar nuevos tipos penales en esta temática, que es tan sensible para nuestra sociedad y para nuestras futuras generaciones.

De este modo, se sancionarán no solo las acciones sexuales, sino también los actos de significación sexual ante una persona mayor de catorce años, o bien se determine a estos menores de edad a realizar actos en que se les hiciere escuchar material pornográfico o de explotación sexual, o presenciar espectáculos del mismo carácter.

Asimismo, será sancionado quien promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años, incorporándose agravantes cuando medie dependencia económica o personal, o si existe habitualidad o retribución.

Es por ello que manifiesto mi voto favorable a todas las disposiciones de este proyecto de ley en su fase en particular, y me alegra que Chile esté a la altura de ser un país donde no solo es un eslogan el poner a los niños en el primer lugar de la fila.

Gracias, Presidenta .

Discusión en Sala

El señor KAST.-

¿Puede abrir la votación, Presidenta?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

No vamos a abrir la votación, porque todas las normas vienen aprobadas por unanimidad.

Entonces, si ustedes dan la unanimidad y aprobamos, dejaríamos a los tres Senadores inscritos sin la posibilidad de intervenir y daríamos por despachado el proyecto.

Esa es la razón por la cual no se ha abierto la votación.

Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES .-

¡Si me permite el Senador Espinoza, podré intervenir...!

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Senador Espinoza , si le permite hablar al Senador Flores, sería bueno.

El señor FLORES .-

¿Me permite hablar, querido?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

El señor FLORES .-

¡Sabemos que la Senadora Rincón es más atractiva que yo, pero qué le voy a hacer...!

(Risas).

Estimados colegas, tal como lo ha mencionado la Presidenta , estamos ante uno de los proyectos que más conmueven y, a la vez, preocupan, porque hay pocos actos del ser humano tan deleznable, tan detestables -la verdad es que cuesta calificarlos- como es el abuso, la violación de un derecho humano cuando existe un descontrapeso tan enorme como el que se da entre un adulto y un niño, y en este caso la promoción de la explotación sexual de menores.

Por lo tanto, aquí no debiera haber titubeos ni vacilaciones en que este proyecto evidentemente tiene que ser aprobado. Y si es por unanimidad, maravilloso, porque lo que ha venido ocurriendo en este concepto de la prostitución infantil es que el término "prostitución", señalado en el Código Penal, deja entrever que hubiese algo de autorización, de participación voluntaria de un infante o un adolescente.

Y la verdad es que lo que ha hecho el Congreso Nacional con este proyecto es una aclaración, porque ese desbalance de poder, ese ejercicio de un adulto ante la vulnerabilidad de un menor, ya sea por la vía del dinero, de una prestación, de algún favorecimiento o por las razones que sean, debe ser objeto de un trato duro.

Lo que finalmente resuelve este proyecto, estimadas y estimados colegas, es que, en primer lugar, aclara un concepto porque, tal como lo dijo el colega Matías Walker en su intervención en la Comisión, no existe la prostitución infantil; lo que existe es la explotación sexual infantil. Tampoco existe la pornografía infantil; lo que existe es la explotación sexual para producir material pornográfico en el cual se expone a niñas, niños y adolescentes.

Y esto, evidentemente, no solo es algo que espanta y avergüenza, sino que debe ser considerado dentro de nuestro Código Penal como una falta gravísima.

Discusión en Sala

Esto lo aclara este proyecto.

En segundo lugar, lo que también conocemos, creo que no hay otro delito contra un niño, niña o adolescente que afecte más su autonomía o indemnidad sexual como lo es la explotación sexual infantil.

Y hoy día esto se aclara y se especifica en el Código Penal.

Por lo tanto, sin entrar en mayores detalles sobre este proyecto, me parece que es un avance para poder recalificar esta brutal forma de violar los derechos fundamentales de personas que se están formando y que quedan marcadas para toda la vida cuando son engañadas o violentadas.

Por tal razón, sin ninguna duda, espero que este proyecto se apruebe el día de hoy.

Gracias, Presidenta .

La señora PROVOSTE.-

¿Presidenta?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Senadora Provoste, ¿punto de reglamento?

La señora PROVOSTE.-

Sí, Presidenta.

Solicito que recabe la unanimidad para aprobar el proyecto, no obstante que después se continúe con el orden de las palabras solicitadas.

"Si le parece", Presidenta .

El señor COLOMA.-

¿Para qué? ¿Para votar?

Es unánime.

La señora PROVOSTE.-

¡Sí, pues! Que se recabe ahora.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

La Senadora Provoste solicita que recabemos ahora la unanimidad y luego, no obstante que ya esté despachado el proyecto, los tres Senadores que están inscritos puedan intervenir.

Entonces, recabo el acuerdo de la Sala para aprobar las enmiendas que fueron acordadas unánimemente por la Comisión y aquellas que no fueron objeto de modificaciones.

(La señora Presidenta hace sonar la campanilla en señal de aprobación).

--Por unanimidad, se aprueban las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Bien.

Entonces, queda despachado el proyecto a su tercer trámite en forma unánime.

Discusión en Sala

Seguimos ahora con los discursos que nos faltaban.

Tiene la palabra, sobre este mismo proyecto, la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidenta .

Voy a tratar de ser bien breve.

Creo que es difícil no dar una opinión sobre este importante proyecto porque, como lo han dicho varios, es fundamental modernizar la regulación y, principalmente, cambiar el concepto de prostitución infantil por el de explotación sexual comercial de niño, niñas y adolescentes.

Efectivamente, y lo han dicho varios, es difícil comprender que un niño desee prostituirse. Eso es absurdo. Claramente lo que ahí hay es un abuso en circunstancias que normalmente están vinculadas a vulnerabilidad.

También coincido con algunos que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a que no existe una vulneración más grave de los derechos humanos que el delito en comento.

Y otro punto al que quiero hacer mención es que, cuando no existe la tipificación adecuada de un ilícito, lo más probable es que la persecución tampoco lo sea.

Por lo tanto, esto que parece conceptual no lo es tanto.

Por un lado, está el punto de vista del principio, de lo que implica cambiarle el nombre a algo tan grave, tan doloroso, que no es solamente una situación puntual, porque lo más probable es que la vida de un niño se altere para siempre producto de este abuso, y, por otro, no es menor que nos pongamos a tono con la modernidad y con lo que hoy día todos los organismos internacionales solicitan.

Desde el 2017 al 2019 hubo más de 4.286 casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a niñas, aunque tampoco es menor la cantidad de niños, que son casi 500 casos. O sea, esta situación, tanto para niñas como para niños, es brutal.

Por lo tanto, nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo de esta problemática, y de ninguna manera reprocharla.

Por otro lado, la explotación sexual está vinculada -y no voy a dar un detalle del proyecto, porque ya todos lo han hecho- a la difusión y comercialización de material pornográfico, que hoy día es un tema preocupante y que, si bien está tipificado, no queda bastante claro.

Nosotros habíamos hecho una indicación en torno al tema, que decía: "Con todo, quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales".

Finalmente, esta indicación no fue apoyada, a pesar de la buena voluntad y los buenos oficios del Ministerio Público.

Por lo tanto, nosotros anunciamos que vamos a presentar, probablemente, una modificación a este proyecto de ley una vez que avance, o formularemos otra moción -no lo sabemos-, porque este es un delito cada día más recurrente.

He sido notificada de casos muy graves ocurridos en algunas regiones del país, en donde prácticamente la mitad de un curso de niños cercanos a los diez años ha sido víctima de este tipo de abusos. Incluso existen plataformas extranjeras -colombianas, por ejemplo- que usan y distribuyen imágenes corporales de estos niños, valiéndose de algunos resquicios y aprovechándose de la inocencia que obviamente implica la edad.

Entonces, creo que hay mucho por avanzar.

Discusión en Sala

Este es un camino con muchas aristas todavía por recorrer.

Por eso quiero dejar en claro que voy a apoyar el proyecto absolutamente, pero que es necesario trabajar con mayor profundidad el tema del ciberespacio e internet, porque es probablemente el medio más usado hoy día para engañar a los niños que, de alguna manera, ni siquiera saben que utilizan estas imágenes para comercializarlas, lo que probablemente es muy lucrativo.

Y este es un daño tremendo, porque lamentablemente, según lo que me ha informado la PDI, las imágenes no es posible eliminarlas, siguen dando vuelta en algunos países y comercializándose. Ese es un grave daño para los niños y su futuro, porque jamás salen de estas páginas.

Así que felicitaciones a la Comisión de Constitución por el trabajo, y seguiremos avanzando en esta materia.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

En primer lugar, yo entendí que esta era una discusión en particular, y no escuché absolutamente ni un solo comentario sobre el proyecto de ley en esa línea, sino que hemos hecho nuevamente una discusión de carácter general para aprobarlo casi seguramente por unanimidad.

Entonces, es importante dejar esto en claro porque, de lo contrario, aparecemos aprobando dos veces los proyectos.

Ahora, yo estoy muy de acuerdo con esta iniciativa. Es una normativa que celebramos, porque adecúa la legislación chilena al derecho internacional de los derechos humanos y, además, porque complementa el estatuto de protección integral de la niñez, que aprobamos también en este Congreso.

Estamos abordando aquí un proyecto de ley relativo al proxenetismo, la explotación sexual comercial y la pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Hemos reemplazado el concepto de prostitución infantil que, como se concibe, no permite castigar adecuadamente al adulto que promueve este tipo de acciones, porque, como dijo -creo- la Senadora que me precedió en el uso de la palabra, no existe tal cosa de la prostitución infantil, sino el uso dañino de carácter permanente de niños para actividades sexuales.

Ahora, la voluntad expresada por el menor o su consentimiento no puede operar como eximente ni atenuante de responsabilidad, ni tampoco puede ser idónea para liberar de persecución al adulto interviniente en los actos descritos en la norma.

Este es el centro vital de este proyecto, y contiene en su núcleo una valoración distinta del niño, niña o adolescente, de manera que el concepto de "autonomía progresiva" impone una atención preferencial y especial durante el desarrollo de ellos por parte del Estado, para que realmente lleguen a su plena autonomía con la suficiente formación y densidad valórica.

Por otra parte, se valoran las precisiones conceptuales que aporta este proyecto, como la de "explotación sexual comercial" de niños, niñas y adolescentes. Esta descripción de la conducta comprende las acciones explícitas y las implícitas, con un fuerte contenido social, aun cuando no haya contacto y aun cuando ese contacto sea en lugares distintos de los que habitualmente se utilizan en la significación sexual.

Además, el proyecto contiene normas importantes sobre reincidencia, que contribuyen a la redefinición de la cuantía del delito y, por tanto, se pone a tono, en general, con las diversas alternativas de explotación sexual, así

Discusión en Sala

como con su vinculación con la pornografía infantil.

Presidenta, creo que es importante decir que no tenemos en nuestra región demasiadas querellas por explotación sexual, conforme a los programas especiales que al respecto tiene el Ministerio de Justicia.

Y es relevante anticipar que, con la nueva tipificación de este delito, existe posibilidad de perseguir de mejor manera conductas reprochables que sabemos perfectamente que ocurren y que, sin embargo, por distintas razones, no llegan a poder de la autoridad.

Voto a favor este proyecto, Presidenta, tal como estaba desde el principio. Está ya aprobado el texto en general, y se ha coincidido por unanimidad en todas las indicaciones en particular. Por lo tanto, creo que este Congreso toma una decisión muy importante al aprobar.

Como dije, hemos debatido en general esta iniciativa dos veces; podríamos haberla aprobado algunos meses antes.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Finalmente, tiene la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

Primero, valoro el acuerdo unánime para votar a favor de algo tan necesario: proteger a las niñas, niños y adolescentes en toda condición, sobre todo de aquellos que quieren abusarlos sexualmente.

En este proceso, lo más destacable -y quiero valorar el trabajo de la Comisión de Constitución- fue haber precisado términos y conceptos para referirse a lo que hoy se conoce como "material de explotación sexual", que es, finalmente, lo que tiene un valor en dinero, lo cual permite que estas bandas internacionales puedan actuar.

Existe un mercado, un valor ya definido, y obviamente hay personas que están preocupadas de lograr que esto ocurra. No es un tema local o nacional; es un problema internacional.

La Senadora Carmen Gloria Aravena se refirió al caso de adolescentes, niñas y niños, que fueron engañados por técnicas que hoy se conocen como "sexting", que es básicamente el intercambio de material de contenido sexual entre ellos.

¿Qué nos dicen las estadísticas? Que uno de cada siete niños o niñas está compartiendo este contenido, el cual, obviamente, después puede ser vendido. Esto es lo que de alguna manera se busca perseguir.

Pero también se perseguirá la conducta de adultos que, conscientes de eso, generan y preparan estudios de televisión caseros para producir y comercializar ese material.

Se trata de material digital, por lo que ahí aparece el gran desafío de poder llevar nuestra legislación al ciberespacio. Chile, en este sentido, se ha adelantado: es el primer país de Latinoamérica en sacar adelante una ley que persigue delitos informáticos. Básicamente, el envío de imágenes de explotación sexual está condenado en todo el mundo. Esa es la forma de evitar que esto se disemine. Nuestra nueva ley lo permite.

Y no solo eso, Chile adhiere al Convenio de Budapest, que, en su Segundo Protocolo Adicional, firmado en Estrasburgo un par de meses atrás, permite a las policías del mundo el intercambio de evidencia digital para poder perseguir este crimen, que nadie quiere.

¿Dónde está el desafío, señora Presidenta ? En entender la complejidad para perseguir este delito. En ello tienen que actuar las brigadas de delito sexuales físicos que conocemos tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones, y después habilitar a las brigadas del cibercrimen, que deben actuar en forma coordinada para

Discusión en Sala

perseguir a estos delincuentes, quienes están cubriendo sus transacciones incluso con lavado de activos, utilizando, probablemente, monederos digitales para usar criptoactivos y así no dejar traza de lo que están haciendo.

Si queremos desarticular este crimen organizado a nivel mundial, tenemos que usar las nuevas herramientas, y Chile puede ser, en ese sentido, un referente.

Señora Presidenta , yo he propuesto a la Mesa que la inauguración del Mes Nacional de la Ciberseguridad -debía ser el 1 de octubre, pero se hará días antes, el día jueves 29-, que se realiza en el Senado por haber nacido la ley N° 21.113 de una moción de Senadores y Senadoras, tenga como objeto perseguir el cibercrimen transnacional con la nueva Ley de Delitos Informáticos, y también impulsar el empleo correcto del Convenio de Budapest para permitir el intercambio de información entre policías y la entrega de información de las plataformas a las policías, esencial para perseguir el ciberdelito. Si no, todo esto es letra muerta.

Esto requiere capacidades nuevas. Por eso se está discutiendo que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y, ojalá, Protección Ciudadana se haga cargo de esta realidad y le defina a la PDI esta labor investigativa esencial, junto con el cibercrimen.

Todos los delitos que están ocurriendo en el mundo físico tienen su paralelo en el mundo digital. Por tanto, debemos tener a las policías preparadas con personas idóneas: el 25 por ciento de los alumnos que ingresan este año a la Policía de Investigaciones quiere postular a las brigadas del cibercrimen. Pero también se requieren medios, y espero que estén contemplados en la Ley de Presupuestos.

Se necesitan softwares como el de Chainalysis Reactor, para ver cómo se hace el lavado de activos de este tipo de transacciones, incluso también de narcotráfico, para perseguir a estos delincuentes. No podemos dejar el espacio.

Yo valoro, señora Presidenta , que se avance, pero pongo la señal de alerta: tenemos que facultar a nuestras policías, al Ministerio Público, considerando también tribunales especializados para perseguir las conductas que generen este material de explotación sexual usando medios digitales, el ciberespacio, para transmitirlos.

Muchas gracias, señora Presidenta .

He dicho.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Bien, no hay más Senadores inscritos.

Conforme al acuerdo adoptado hace unos instantes, el proyecto ya fue aprobado en forma unánime y despachado para su tercer trámite a la Cámara de Diputados.

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 06 de septiembre, 2022. Oficio en Sesión 71. Legislatura 370.

Valparaíso, 6 de septiembre de 2022.

Nº 424/SEC/22

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, correspondiente al Boletín Nº 14.440-07, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1

o o o

Ha intercalado el siguiente número 2, nuevo:

“2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Artículo 366 quáter. El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.”.

o o o

Número 2

Ha pasado a ser número 3, reemplazado por el siguiente:

“3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo VI bis, nuevo:

“§ VI bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.”.

Número 3

Ha pasado a ser número 4, sin modificaciones.

Número 4

Ha pasado a ser número 5, con la siguiente enmienda:

Artículo 367 sustitutivo propuesto

Inciso tercero

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha intercalado, luego de “retribución”, la frase “hacia la víctima o un tercero”.

Número 5

Ha pasado a ser número 6, intercalándose en la frase sustitutiva que se propone, a continuación de “retribución”, lo que sigue: “hacia la víctima o un tercero”.

Número 6

Ha pasado a ser número 7, modificado como sigue:

Artículo 367 quáter propuesto

Inciso primero

Ha intercalado, a continuación del vocablo “pornográfico”, la frase “o de explotación sexual”.

Inciso segundo

Ha intercalado, a continuación del vocablo “pornográfico”, la frase “o de explotación sexual”.

Inciso tercero

Ha intercalado, a continuación del vocablo “pornográfico”, la frase “o de explotación sexual”.

Inciso cuarto

Ha intercalado, a continuación del vocablo “pornográfico”, la frase “o de explotación sexual”.

Números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Han pasado a ser números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, respectivamente, sin modificaciones.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que el Senado acordó sustituir la denominación administrativa de esta iniciativa, por la siguiente: “Proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio N° 17.108, de 13 de diciembre de 2021.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

LUZ EBENSPERGER ORREGO

Vicepresidenta del Senado

RAÚL A. GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 13 de septiembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 73. Legislatura 370. Discusión única. Se aprueban modificaciones.

INTRODUCCIÓN DE NUEVO PÁRRAFO A CÓDIGO PENAL RELATIVO A PROXENETISMO, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 14440-07)

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, correspondiente al boletín N° 14440-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señorita Presidenta, durante la tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se realizó un cambio administrativo al título del proyecto de ley, con el fin de dejar atrás ciertos conceptos erróneos.. Según indicó el senador Walker , Presidente de la Comisión, es un cambio de enfoque, toda vez que no existiría la prostitución infantil, sino la explotación sexual infantil; no existiría la pornografía infantil, sino la explotación sexual para producir material pornográfico en que se expone a niños, niñas y adolescentes, hechos gravísimos que está incorporado en esta legislación. Nos estamos poniendo al día como país. En la misma línea, se especificó el significado de la explotación sexual comercial desde el punto de vista de la producción, comercialización, distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil y explotación sexual infantil. De esta forma, se releva que no existe la pornografía infantil, sino la explotación sexual infantil para producir un material pornográfico.

Se contempla una nueva redacción para el artículo 366 quáter, de acuerdo con una indicación presentada por el senador Galilea, que establece: El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo, de 541 días a 5 años.

Además, si se determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo, 5 años.

Sumado a lo anterior, se señala que será sancionado con la misma pena el que determinare a una persona menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de 14 años de edad, e imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de 14 años.

Vamos a apoyar este proyecto, porque va en la línea correcta y porque es muy necesario para cuidar y defender a nuestros niños, que es algo sagrado.

He dicho.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

Discusión en Sala

El señor BOBADILLA.-

Señora Presidenta, solo quiero saludar y darle la bienvenida a don Luis Rojas, quien estuvo ausente de la Cámara por motivos de salud.

Bienvenido Luis.

-Aplausos.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, este proyecto de ley, además de aumentar las penas -cuestión que no tengo mucha opinión de que sea excesivamente favorable, porque tengo la convicción de que la gente comete los delitos sin pensar en las penas-, me parece importante, porque relevar el tema de la necesidad de reprimir y castigar, investigar y sancionar la explotación sexual infantil es un tema que nos compromete como sociedad.

Es indispensable que tengamos claridad y que exista una legislación que defina adecuadamente los delitos. En este sentido definirlos como explotación sexual infantil y no como pornografía infantil o prostitución infantil es absolutamente indispensable. La prostitución es un acto voluntario y pensar que un niño pueda prostituirse es un resabio de una sociedad antigua que no está acorde con nuestros tiempos.

Sin duda la explotación de los niños, niñas y adolescentes para satisfacción sexual de los mayores de edad es un delito de la mayor gravedad. Es tan grave que altera toda la vida futura de los niños, altera toda la vida de la sociedad.

Nos compete, como sociedad, reprimir constantemente, investigar y hacer todas las acciones que sean indispensables para suprimir de nuestra vida social un delito y un crimen tan grave. No se puede naturalizar la explotación sexual infantil.

Más allá de las penas, más allá de la represión, hay que hacer un trabajo de educación permanente. Hay que educar; hay que hacer una actividad permanente de educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, para que ellos sepan cuáles son los límites que no pueden dejar que nadie traspase, porque también está la autodefensa del niño que es capaz de contar en su familia lo que le está sucediendo y para eso es indispensable la educación sexual permanente, completa, con palabras correctas. En ese sentido, está bien este proyecto, pero más allá de este proyecto es indispensable dejar claridad en la sociedad de la necesidad de educarnos en el respeto propio y ajeno. Eso es lo que nos hará libres.

He dicho.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, honorable Cámara, valoro significativamente la propuesta de este proyecto de ley, ya que viene a otorgar una mayor protección hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, que hoy en día se encuentran expuestos a diversas hipótesis delictivas de explotación sexual.

Valoro que el proyecto esté dando los primeros pasos en cambiar el paradigma utilizado hasta hoy, complementando el concepto "pornografía infantil" con el concepto "material de explotación sexual", ya que el primero denota cierto consentimiento de quienes participan en los hechos y, claramente, sabemos que los menores no consienten en participar en esta clase de situaciones.

Destacó la eliminación del tipo subjetivo que exige que quien perpetra el delito lo haga con el ánimo de procurar su excitación sexual o la de otro, como lo ha sido hasta hoy en ciertas hipótesis el artículo 366 quater, ya que

Discusión en Sala

facilitará la ardua tarea del Ministerio Público para probar el ilícito y sancionar a quienes determinen a menores de 14 años a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de genitales o grabaciones en que se representen acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de 14 años de edad.

La eliminación del elemento subjetivo en el tipo penal también facilitará la labor del Ministerio Público para sancionar a quienes obtienen este tipo de imágenes con fines comerciales.

Muy acertadas fueron también las modificaciones del artículo 367, que permite ampliar las víctimas a todos aquellos menores de 18 años, sin distinción de si tienen o no discernimiento en su actuar; extienden el tipo penal a aquellos adultos que tienen a menores bajo su dependencia personal o económica, y además, amplían la tipificación del delito hacia cualquier tipo de soporte tecnológico de los utilizados hoy en día, entregando estas conductas a la competencia de las leyes chilenas, cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones, al que se tenga acceso desde el territorio nacional, situación que también ha provocado dificultades para determinar la ley aplicable.

Con todo, apoyo las modificaciones propuestas por el honorable Senado, ya que vienen en línea con las obligaciones del Estado orientadas a entregar protección efectiva a niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual.

He dicho.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, la realidad nos ha demostrado la necesidad de ir actualizando, cada cierto tiempo, la legislación penal, especialmente en lo referente a delitos que afecten a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como lo son niños, niñas y adolescentes, porque siempre se buscan nuevas maneras de delinquir, nuevas formas de abusar y aprovecharse de quienes tienen menores posibilidades de defenderse.

Tal como se menciona expresamente en este proyecto de ley, la legislación penal nacional en materia de delitos sexuales ha venido experimentando importantes reformas que han tenido la finalidad de entregar herramientas eficaces para la persecución de determinadas conductas, cuyas víctimas son principalmente niños, niñas y adolescentes.

Hemos avanzado en temas como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el acoso sexual contra menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil, entre otros aspectos.

En este sentido, valoramos que este proyecto de ley ponga en relevancia la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un tratamiento penal especial en un nuevo párrafo del Código Penal. Es un avance, pero no todo lo suficiente.

Desde hace algún tiempo hemos advertido sobre la urgencia de legislar, considerando especialmente los riesgos a los cuales se ven expuestos los niños, niñas y adolescente en nuestro país, donde la reinserción de adolescentes infractores ha fallado, donde institucionalidad protectora ha fallado, donde la delincuencia día a día es más violenta e indolente, llegando a agredir a menores de edad sin ningún tipo de conciencia.

Son una serie de situaciones que configuran vulneraciones a los derechos humanos, de los cuales son titulares niños, niñas y adolescentes, y que requieren de más esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad civil, y esto se concreta con fuerza en la legislación penal con este proyecto de ley, cuyas modificaciones del Senado votaremos hoy, pues el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes requiere por parte del Estado de formas de abordarlo que apunten a la sanción, pero sobre todo a la prevención.

Por ello, cobra tanta relevancia el problema de desapariciones de niños, niñas y adolescentes, así como los sistemas de búsqueda, que durante décadas no han sido del todo eficientes en esta labor. Dicha ineficiencia presenta la oportunidad para que se sigan cometiendo delitos de esta gravedad y naturaleza, de manera que como Estado debemos ser más proactivos. No debemos quedarnos solo en la tipificación y en la sanción de un delito,

Discusión en Sala

sino que tenemos que crear las condiciones necesarias para que su prevención sea eficaz. Esa es la respuesta que más necesitan los miles de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados año a año en nuestro país.

En consecuencia, llamo a votar a favor las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, este proyecto evidentemente va en la dirección correcta. Me faltan, eso sí, dos elementos que quizá todavía pueden ser incorporados en la iniciativa.

Uno de estos es el aumento de la edad de los menores que pueden ser susceptibles de ser víctimas de este tipo de delitos. El artículo 366 quater del Código Penal señala: “El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años (...), será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.”. No veo la razón por la que eso deba ser aplicable solamente para víctimas menores de catorce años de edad.

Por otra parte, evidentemente podríamos aumentar las penas, ya que la pena de presidio menor en su grado medio a máximo máximo no cubre el daño que realiza aquel que explota sexualmente a un menor para fines financieros o de otro tipo.

En ese sentido, espero que contemos con el respaldo necesario para aumentar las penas para este delito.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, a la fecha la legislación nacional no contempla una tipificación para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La forma en que se presenta este delito son los denominados delitos de “favorecimiento de la prostitución infantil, la obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio”, entre otros.

El proyecto crea un título especial sobre la materia en el Código Penal, lo que permite diferenciar estos delitos del abuso sexual y del estupro, entre otros.

La Unicef advierte: “La explotación sexual ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas; esto a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especies, protección o regalos, se constituye como una flagrante violación de los Derechos Humanos.”.

Hay diversas clases de este tipo de explotación. Se estima que en Chile por lo menos 3.719 niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual y comercial. Asimismo, la ONG chilena Raíces calcula que las edades de las víctimas oscilan entre diez y dieciocho años de edad, entre las que el 80 por ciento son mujeres.

Sin embargo, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no está tipificada como delito, ya que en el Código Penal se le concibe como prostitución infantil, concepto que es inadecuado para abordarla.

La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU, organización que resguarda los derechos de los niños y jóvenes, ha señalado que las razones pueden ser el aumento de la pobreza, la falta de oportunidades y, llanamente, el incremento de los explotadores sexuales infantiles, que primero seducen y luego

Discusión en Sala

explotan.

En este contexto, se ha vuelto una prioridad proteger los derechos de los niños frente a la realidad, más aún si se considera que la explotación sexual de los niños es una forma de esclavitud, razón por la que no se puede hablar de prostitución infantil. La prostitución es, por definición, un acto voluntario, absolutamente distinto a la situación de los niños que se ven forzados al comercio sexual.

Por supuesto que vamos a probar las modificaciones del Senado recaídas en este proyecto, puesto que este va, precisamente, en la lógica de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, invito también a la Cámara a aprobar las enmiendas del Senado incorporadas a este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, qué duda cabe de la necesidad de proyectos de ley como este. Lamentablemente, en los tiempos que corren cada vez vemos más situaciones de abuso sexual de menores en sus distintas formas. Aquí no estamos hablando solo de delitos de violación y de tocaciones, que ya de por sí son graves, sino del abuso sexual referido a introducir conceptos, ideas o expresiones sexuales en la cabeza de niños por parte de adultos.

Se me ocurre un ejemplo bastante reciente y contingente: la situación que vivimos en Valparaíso con el famoso show de cierre de campaña del Apruebo de las famosas Las Indetectables, que ya son conocidas por todos los chilenos. Evidentemente, lo que allí sucedió nos tiene que llevar una reflexión de lo inaceptable que es exponer frente a niños, porque sabemos que había niños en ese evento, ese tipo de comportamientos.

Por eso me preocupa una de las cosas que se hace en este proyecto de ley: la modificación al artículo 366 quater, en virtud del cual aprovecho de señalar que presenté una denuncia en contra del alcalde Sharp y de otros involucrados en aquel acto. Se trata de una modificación que establece una separación entre que un adulto realice acciones de significación sexual frente a menores de edad y el provocar que menores realicen acciones de significación sexual o exhibir material pornográfico.

En ambos casos se estaría estableciendo la posibilidad de penas distintas. Se estaría estableciendo la posibilidad de que, en el caso de Las Indetectables, por ejemplo, se aplique una pena más baja que en los casos que, por cierto, son graves, de los cuales estamos hablando hoy, que es el uso sexual de menores directamente. ¿Por qué estas dos cuestiones son distintas? ¿Por qué en estas dos cuestiones una sería más grave que la otra?

Creo que estamos hablando de cuestiones igualmente graves, que debiesen preocuparnos y que debiésemos trabajar para que sean igualmente sancionadas por parte de la justicia. No podemos permitir que se realice por parte de adultos acciones de significación sexual frente a menores y que eso caiga en presidio menor en su grado medio a máximo, si no me equivoco, y que en los otros casos, de los cuales estamos haciendo referencia...

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Señor diputado, refiérase al proyecto, por favor.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, estoy refiriéndome al proyecto. Si me pusiera atención, quizá se daría cuenta.

El caso del que estamos hablando es básicamente establecer conductas que son igualmente graves, pero que van a tener penas distintas. Eso es bastante preocupante.

Este proyecto de ley establece otras cuestiones que también son positivas. Entonces, evidentemente vamos a dar

Discusión en Sala

nuestro apoyo a este proyecto, pero en verdad me preocupa mucho que aquí estemos haciendo distinciones que no corresponden.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señorita Presidenta, los niños, las niñas y los adolescentes son personas que merecen especial protección del Estado. Cuando uno es un niño, lo único que llama es a que le den ternura, comprensión, protección.

Por eso, cuando se presenta un proyecto como este, que busca modernizar los términos para darles una mejor protección y también para establecer mayores penas a quien abuse de un niño, creo que debemos apoyarlo. No obstante, debemos ir más allá y entender que el Estado tiene una función esencial.

Por eso, tenemos que potenciar todas las actividades, funciones e instituciones que dan la protección a los niños. Hemos carecido de ello mucho tiempo en nuestra historia, por defectos que trascienden a los gobiernos. Ni siquiera es un problema de inspiración política, sino muchas veces de carácter presupuestario.

Chile tiene hoy mejores condiciones, por eso debemos avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes, en darles mejores condiciones, donde se detiene, se cuida, se educa a los niños, pero sobre todo, en entregarles la posibilidad de ser niños, disfrutar, crecer, divertirse y de que jamás sean objeto de delitos deleznales, como el abuso o el estupro, como los que se describen en este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, meses atrás en este mismo hemiciclo aprobamos las dolorosas conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.

Las conclusiones y las recomendaciones que arrojó esa comisión no solo nos deberían doler profundamente a todos y a todas, sino que, además, nos tienen que poner en alerta y, sobre todo, llevarnos con urgencia a la acción.

Constatamos una enorme debilidad institucional a la hora de enfrentar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y lo más grave de todo es que esa debilidad institucional ha sido identificada por las redes de explotación sexual infantil, que ven en los centros de protección del Estado un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias, que debiesen ser lugares de protección, en espacios de riesgo de vulneraciones gravísimas.

Niños, niñas y adolescentes son sacados de sus casas dada la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad de sus familias, y luego son institucionalizados y llevados a lugares de protección de derechos, que no lo son en realidad, donde terminan siendo captados por redes de explotación sexual que funcionan ante un Estado que no está ni ha estado a la altura de la situación.

Todas las instituciones tenemos responsabilidades: las policías deben dar efectiva prioridad a la búsqueda de niñas y niños desaparecidos; el Ministerio Público tiene que priorizar la persecución de estos delitos; el Ejecutivo debe desarrollar e implementar eficazmente los planes y programas para detectar tempranamente las vulneraciones de derechos y prevenirlas, pero nosotros, como Poder Legislativo, también tenemos una deuda pendiente con los niños, niñas y adolescentes que han sido captados por redes de explotación sexual.

Discusión en Sala

La modernización legislativa elimina al fin el concepto de “prostitución” infantil -noción errada que mantiene la percepción de que los niños, niñas y adolescentes presentan algún grado de voluntariedad para participar en ese delito, lo que niega su condición de víctimas al no considerar la asimetría de poder que subyace entre la víctima y los victimarios-, reemplazándolo por el de “explotación sexual” comercial de niños, niñas y adolescentes, que considera la verdadera naturaleza del delito: un tipo de abuso infantil.

Sabemos que eso no es suficiente, pero destacamos positivamente que hayamos avanzado en este proyecto, que fue uno de los compromisos que tomamos como Poder Legislativo cuando aprobamos en esta Cámara el informe a que he hecho referencia...

-Aplausos.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, diputada.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señora Presidenta, estuve tentada a subir a la testera a dejarle un antiinflamatorio, porque encuentro que tiene un poquito afectada su garganta. Espero que se mejore.

Por cierto que voy a aprobar el contenido del proyecto que estamos discutiendo, pero se me ocurrió que sería muy interesante que los legisladores se juntaran más frecuentemente con los especialistas en salud mental, porque uno cuando conversa el tema del autocuidado y la autoconciencia, del respeto por tu cuerpo y por tu sexualidad, hay que considerar que este fenómeno se desarrolla en plena pubertad, entre los 10 y los 14 años.

He trabajado muchos años en el psiquiátrico atendiendo a gente de los segmentos más desfavorecidos, desde el punto de vista económico y cultural de nuestro país. Además, completé un gran trabajo en la fundación Paternitas . Al respecto, les quiero decir que cuando uno atiende a niñas que han sido objeto de maniobras de depredadores sexuales, proxenetas, etcétera, muchas veces comprende que tienen una gran claridad sobre lo que les ha sucedido, una seudomadurez, pues conocen perfectamente las reglas del juego y, hasta cierto punto, tienen una cuestión que a mí producía mucho dolor al comienzo: un cinismo para enfrentar el tema de los abusos sexuales a los que han sido sometidas, porque, no nos hagamos los lesos, hay muchos padres y muchas madres que encuentran desahogo económico usando a sus hijos en maniobras sexuales.

La otra cosa que quiero señalar es que actualmente hay un cinismo en la sociedad chilena. Existen grupos de profesores y profesoras que, desde la perspectiva ideológica del constructivismo, están introduciendo temas que atentan contra la inocencia y la ingenuidad de los niños. En este sentido, me encantaría que algún día tratáramos eso: cómo se han perdido los límites y la falta de respeto que existe ante la inocencia y la belleza que deberían caracterizar a la infancia y a la pubertad.

He dicho.

La señora MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Gracias, diputada, por su preocupación por mi salud. Estoy con las secuelas de la covid-19.

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señora Presidenta, sin duda, en Chile tenemos deudas pendientes en materia de delitos sexuales, especialmente en relación con la concepción de dichos ilícitos y la protección que como Estado entregamos a las víctimas. Parte de dicha protección, a mi parecer, se gesta desde la capacidad de comprender tanto la dimensión del daño recibido como la correcta contextualización de las consecuencias de tales hechos.

Cuando hablamos de delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, la importancia de la correcta tipificación se

Discusión en Sala

hace más urgente aún, si consideramos que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una de las formas más violentas de abuso de poder, siendo incluso considerada como una forma moderna de esclavitud. Su multicausalidad, que incluye contextos de vulnerabilidad y pobreza, ambientes y relaciones violentas, claramente la cultura patriarcal, como así también lo relativo a nuestros cambios de conducta y comunicaciones, la desprotección en relación con el uso indiscriminado de redes sociales, entre muchos otros factores, muestra la necesidad de establecer un correcto conocimiento y, además, la profundidad del daño causado con cada uno de aquellos delitos.

Este proyecto, que viene a reconocer y cambiar el concepto de “prostitución” por “explotación sexual”, entrega una noción más cercana a la realidad, más consciente de la profundidad y los efectos terribles que las conductas en dichas explotaciones generan, no solo en el crecimiento y formación de niños, niñas y adolescentes, sino también en la profunda indefensión en la que muchos menores de edad se han visto en un país que posee una de las tasas más altas en relación con este tipo de delitos en la región.

Establecer el concepto de explotación sexual genera, además, claridad sobre todas aquellas acciones en las que es utilizada una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de significación sexual a cambio de cualquier tipo de retribución, lo que permite entender parte de las nocivas dimensiones que tienen estos casos, estableciendo la importancia de la dependencia y de las acciones que evitan que niñas, niños y adolescentes puedan salir de dichos círculos.

Votaré a favor de este proyecto, entendiendo que aún nos falta mucho en materia de protección, pensando especialmente en la protección de las víctimas y en el cambio de enfoque, que es esencial para comprender que la multiplicidad de factores nos obliga como Estado a estar más alertas, más presentes y más conscientes de que se trata de una realidad de la cual debemos hacernos cargo.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señorita ROMERO (doña Natalia) .-

Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, hoy nos toca ver una iniciativa que amerita el respaldo de todas y todos en este hemiciclo, puesto que se relaciona con la protección de los derechos e intereses más elementales de niños, niñas y adolescentes, y particularmente de aquellos que están sujetos a las más fuertes vulneraciones económicas y sociales.

Honestamente, creo que este proyecto viene a modernizar y a cambiar el enfoque respecto a los delitos sexuales cometidos contra menores y adolescentes, aclarando que, en hechos relativos a la explotación sexual, la pornografía y la exposición a ella, no existe realmente ninguna voluntad cuando menores son sometidos a estos vejámenes, sino el de posiciones de superioridad y aprovechamiento por la fuerza de la inocencia de nuestros menores. Esto viene a reconocer el aprovechamiento delictual y maligno de quienes obligan a menores de edad a someterse a estos vejámenes.

A la vez, este proyecto permite agravar las penas relativas a estos hechos, imponiendo penas adecuadas en contra de estos crímenes.

Sinceramente, apoyaré este proyecto, para defender y proteger lo más sagrado de nuestro país, nuestro futuro y su correcto desenvolvimiento, es decir, a nuestros niños y niñas.

Por ello, y teniendo la convicción de que nadie ha de restarse de este proyecto, mi voto es a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro Segundo del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 144 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acevedo Sáez , María Candelaria De la Carrera Correa , Gonzalo Marzán Pinto , Carolina Rathgeb Schifferli , Jorge Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Matheson Villán , Christian Rey Martínez, Hugo Ahumada Palma , Yovana Del Real Mihovilovic , Catalina Medina Vásquez , Karen Riquelme Aliaga , Marcela Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mellado Pino , Cosme Rivas Sánchez , Gaspar Araya Guerrero , Jaime Donoso Castro , Felipe Mellado Suazo , Miguel Rojas Valderrama , Camila Arroyo Muñoz , Roberto Durán Espinoza , Jorge Melo Contreras , Daniel Romero Leiva , Agustín Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Meza Pereira , José Carlos Romero Sáez , LeonidasBarchiesi Chávez , Chiara Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Talguia , Natalia Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Barría Angulo , Héctor Fuenzalida Cobo , Juan Molina Milman , Helia Sáez Quiroz , Jaime Becker Alvear , Miguel Ángel Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Saffirio Espinoza , Jorge Bello Campos , María Francisca Giordano Salazar , Andrés Morales Maldonado , Carla Sagardia Cabezas , Clara Beltrán Silva , Juan Carlos González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo González Olea , Marta Moreno Bascur , Benjamín Santana Castillo , Juan Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bernales Maldonado , Alejandro Guzmán Zepeda , Jorge Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Bórquez Montecinos , Fernando Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Schubert Rubio , Stephan Bravo Castro , Ana María Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Bravo Salinas , Marta Ilabaca Cerda , Marcos Ñanco Vásquez , Ericka Serrano Salazar , Daniela Brito Hasbún , Jorge Irrarrázaval Rossel , Juan Ojeda Rebolledo , Mauricio Soto Ferrada , Leonardo Bugueño Sotelo , Félix Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Bulnes Núñez , Mercedes Jouannet Valderrama , Andrés Orsini Pascal , Maite Sulantay Olivares , Marco Antonio Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irrarrázabal , Ximena Tapia Ramos , Cristián Camaño Cárdenas , Felipe Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Tello Rojas , Carolina Cariola Oliva , Karol Labbé Martínez , Cristian Palma Pérez , Hernán Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Ulloa Aguilera , Héctor Castillo Rojas , Nathalie Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Olea , Joanna Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Leal Bizama , Henry Pérez Salinas , Catalina Undurraga Vicuña , Alberto Cicardini Milla , Daniella Lee Flores , Enrique Pino Fuentes , Víctor Alejandro Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila ,

Discusión en Sala

Consuelo Cifuentes Lillo , Ricardo Lilayu Vivanco , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Concha Smith , Sara Longton Herrera , Andrés Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Cordero Velásquez , María Luisa Malla Valenzuela , Luis Ramírez Díez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cornejo Lagos , Eduardo Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Weisse Novoa , Flor Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Martínez Ramírez , Cristóbal Raphael Mora , Marcia Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvo la diputada señora:

Naveillan Arriagada, Gloria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Se despacha el proyecto a ley.

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 13 de septiembre, 2022. Oficio en Sesión 56. Legislatura 370.

VALPARAÍSO, 13 de septiembre de 2022

Oficio N° 17.736

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín N° 14.440-07.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 424/SEC/22, de 6 de septiembre de 2022.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

RAÚL SOTO MARDONES

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Veto Presidencial

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 13 de septiembre, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 13 de septiembre de 2022

Oficio N° 17.737

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín N° 14.440-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,” e intercálase, entre el guarismo “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “367 quáter, 367 septies”

2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Artículo 366 quáter. El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo 6 bis, nuevo:

“§ 6 bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.

4. Derógase el artículo 366 quinquies.

5. Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

“Artículo 367. El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.”.

6. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero”.

7. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“Artículo 367 quáter. El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Artículo 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Artículo 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

Artículo 367 octies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

8. Reemplázase en el encabezado del Párrafo 7 del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

10. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

11. Elimínase en el inciso primero del artículo 368 ter la expresión “366 quinquies,” y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

12. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

tres párrafos anteriores”.

13. Elimínase en el inciso primero del artículo 369 ter la expresión “366 quinquies,”, y sustitúyese el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

14. Sustitúyese en el artículo 369 quinquies el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

15. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

16. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 372 el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

17. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

2. Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Reemplázase en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4 de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo “366 quinquies” por la expresión “367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como substitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies,”, y agrégase, a continuación del guarismo “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo,”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Dios guarde a V.E.

RAÚL SOTO MARDONES

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

4.2. Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 12 de octubre, 2022. Oficio en Sesión 86. Legislatura 370.

FORMULA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (BOLETÍN N° 14.440-07).

Santiago, 12 de octubre de 2022.

N° 160-370/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARADE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

Mediante oficio N° 17.737 de fecha 13 de septiembre de 2022, V.E. comunicó que el H. Congreso Nacional aprobó la iniciativa correspondiente al boletín N° 14.440-07.

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA Y EL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL

El proyecto de ley que se observa tuvo origen en un Mensaje Presidencial de 23 de junio de 2021. Su fundamento se reconduce a una recomendación del Tercer Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

Dicha instancia corresponde a un esfuerzo multisectorial de coordinación de diversas instituciones públicas y privadas cuyo propósito es acordar compromisos para la prevención y sanción de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estas instituciones se comprometen a ejecutar diferentes acciones por un tiempo determinado, siendo encabezados por una Mesa Ejecutiva, que sistematiza la información reportada por cada una.

Desde la sociedad civil fueron muchas las instituciones que participaron en este Tercer Marco: ONG Raíces; ONG Social Creativa; Corporación Opción; ONG Paicabí; Fundación Social Novo Millenio; Fundación Tierra Esperanza; Corporación SERPAJ; Corporación Prodel; Fundación Ciudad del Niño; Corporación de Apoyo y Promoción de la Equidad en Inclusión Social. Todas estas organizaciones, dedicadas a la protección especializada frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, participaron en el Primer y Segundo Marco para la Acción con el mismo propósito, es decir, proponer un nuevo marco legal de protección para niños, niñas y adolescentes.

Las recomendaciones del informe multisectorial se estructuraron en cinco líneas de acción[1], dentro de las cuales, la quinta, dice relación con la línea de acción que procura determinar la “sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas”.

Respecto de esta línea de acción, el informe relevó la incorrecta aproximación al problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que tiene la regulación sustantiva en el Código Penal chileno que, en definitiva, profundiza la victimización secundaria de los afectados.

En efecto, las leyes que actualmente regulan esta materia desvirtúan el problema. El derecho nacional contempla el delito de “prostitución infantil” lo que constituye una etiqueta errada sobre el fenómeno. Ello, pues supone que una persona menor de edad vende su cuerpo de manera premeditada y consciente a un adulto. La así llamada “prostitución infantil” es, en realidad, explotación infantil. El fenómeno tiene como base la capacidad de poder que ejerce un explotador sobre una niña, un niño o adolescente que, generalmente, ha padecido abusos y violencia sexual desde sus primeros años. Así, el adulto capitaliza el abandono y la orfandad emocional de niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y de violencia que puede equipararse al trabajo forzoso, incluso a una forma contemporánea de esclavitud, como la define[2] y otros organismos especializados.

Así, este proyecto de ley nace para hacerse cargo del problema detectado. Con este diagnóstico, seguir usando la noción de “prostitución infantil” es un error conceptual que debe ser corregido, tornándose obligatorio actualizar la legislación con el objeto de condenar sin vacilaciones este tipo de crímenes. Lo anterior es especialmente decisivo

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

si se considera que la mayoría de las víctimas no se perciben como tales y establecen una dependencia afectiva de su explotador[3].

II. TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA

a) Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados

Como ya fue mencionado, la iniciativa fue ingresada a través de Mensaje el 23 de junio de 2020 a la Cámara de Diputados, siendo estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta comisión emitió su primer informe el día 7 de diciembre de 2021.

Tras el respectivo debate y estudio de las propuestas contenidas en la iniciativa legal, así como de aquellas sugerencias levantadas durante su tramitación, el proyecto fue aprobado y despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 13 de diciembre de 2021, realizando los siguientes cambios:

i. Se incorporó un nuevo artículo 367 quáter, reemplazando la referencia al artículo 366 quinquies, y un nuevo artículo 367 septies en el artículo 94 bis del Código Penal, con el objeto de aplicar la norma de imprescriptibilidad de la acción penal.

ii. Sin sustituir ni modificar en otros aspectos el artículo 367 del Código Penal, que contiene el nuevo delito de explotación sexual comercial, se aumentó la pena en un grado respecto de la propuesta original.

iii. Se dividió el inciso primero del artículo 367 quáter con el objeto de dejar en una norma separada –nuevo inciso segundo– la figura de producción de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

iv. Se creó un nuevo delito en el artículo 367 septies no contemplado en la propuesta original que sanciona la transmisión, sin soporte o grabación, de la imagen o sonido de una interacción sexual que involucra a una persona menor de 18 años.

v. Se replicó la norma actual, como un nuevo artículo 367 octies, idéntica a la aplicable al delito de trata de personas contenida en el artículo 411 septies, para que la agravante de reincidencia pueda darse por satisfecha por cargo a las sentencias condenatorias dictadas en el extranjero.

vi. Se realizaron adecuaciones en el Código Penal con el objeto de actualizar las referencias, habida cuenta de que el nuevo artículo 367 quáter sintetizaba y contenía las ideas regulativas de los artículos 366 quinquies y 374 bis, las que el proyecto deroga. Adicionalmente, las modificaciones tuvieron en consideración que la existencia de un nuevo párrafo, el “6 bis” que se intercala entre los párrafos 6 y 7, hacía necesario referirse, en las normas comunes a los párrafos anteriores (párrafo 7 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal) a los “tres” párrafos anteriores en reemplazo de la palabra “dos”. Esta adecuación efectivamente se hizo tanto en el nombre del párrafo 7, como en los artículos 368, 368 bis, 368 ter, 369, 369 ter, 369 quinquies, 371 y en los incisos segundo y tercero del artículo 372.

vii. Se realizaron también actualizaciones en el mismo sentido que el literal anterior en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad; en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; y, en el Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

b) Segundo Trámite Constitucional en el Senado

La iniciativa fue estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

El debate en la Comisión recayó sobre el perfeccionamiento del artículo 366 quáter, que no había sido objeto de modificaciones por parte del Ejecutivo, ni por la Cámara de Diputadas y Diputados, en lo relativo a la nomenclatura de la noción de “pornografía” de personas menores de 18 años, y en lo relativo a la clarificación del destino de la “retribución” en los delitos de explotación sexual comercial.

Tras la discusión en sala, el proyecto fue aprobado el día 6 de septiembre de 2022 y despachado a tercer trámite

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

en los siguientes términos:

i. Respecto a la modificación del artículo 366 quáter del Código Penal, se sustituyeron los actuales incisos primero y segundo, por nuevos incisos primero, segundo y tercero, pasando el resto de los apartados del artículo a ordenarse correlativamente. De esta forma, se eliminó la tendencia interna o ánimo especial libidinoso respecto de las siguientes hipótesis: (i) Determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual o a hacerla ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter (ii) Determinar a una persona menor de 14 años a enviar imágenes o grabaciones que representen acciones de significación sexual, propias o de otro menor de 14 años, o imágenes o grabaciones de sus genitales, propias o de otro menor de 14 años;

ii. Se agregó, en todas las normas que hacen referencia al “material pornográfico” de niños, niñas o adolescentes la expresión “de explotación sexual”; y,

iii. Se aclaró que la retribución a que hace referencia el delito de explotación sexual de niños, niñas o adolescentes puede estar destinada al propio menor de edad o a un tercero.

c) Tercer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados

La Cámara de Diputados, en sesión de 13 de septiembre de 2022, aprobó las enmiendas propuestas por el H. Senado, remitiendo Oficio de Ley al Gobierno para su promulgación.

III. FUNDAMENTOS DE LAS OBSERVACIONES

Los cambios que se proponen se refieren, por una parte, a la actualización de referencias o remisiones de una norma a otros artículos y, por otra, a la inclusión del artículo 367 septies, creado por el proyecto, en el estatuto general de delitos sexuales contra NNAs.

a) Adecuaciones de referencias:

En relación con el primero de los asuntos, si bien en la Cámara de Diputadas y Diputados se hicieron algunas adecuaciones de referencia como consecuencia de la nueva ubicación de los delitos que involucran material pornográfico o que se relacionan con la explotación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, dada la complejidad y consecuencias que tienen las modificaciones introducidas a normas sobre delitos sexuales, se ha advertido la necesidad de agregar referencias adicionales en otras normas del cuerpo punitivo y de otras legislaciones sectoriales. Estos ajustes de referencia tienen lugar en un área del derecho profundamente caracterizada por el apego al principio de legalidad, como lo es el derecho penal, por lo cual deben ser realizados. Asimismo, es necesario establecer una legislación íntegra y coherente que refuerce el carácter racional del legislador chileno.

Por una parte, algunas de estas correcciones suceden en el propio seno del Código Penal. En particular, en el artículo 369 bis, en el artículo 369 ter, en el artículo 369 quinquies, en el artículo 370 bis, en el inciso primero del artículo 372 y en el artículo 372 ter.

En el caso del artículo 369 bis, este aplica las reglas de la sana crítica en los delitos sexuales, lo cual es innecesario hoy dadas las reglas especiales de valoración que existen en el Código Procesal Penal. Por esta razón se ha decidido propiciar su supresión.

En el caso del artículo 369 ter, dicha norma debió haber hecho mención a los incisos primero y segundo del artículo 367 quáter y no solo a su inciso primero a partir del cambio en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por otra parte, en los demás casos se ha buscado enmendar los problemas de referencia que se derivan de que no se modificó la mención de “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores” que hacen operativas las reglas del párrafo 7 en algunas normas. De esta manera, se propone sustituir dicha referencia ampliando finalmente a los párrafos 5, 6 y 6 bis, para así no dejar fuera a las hipótesis de violación (párrafo 5) de las reglas comunes, que no fueron indicadas del párrafo 7.

Lo anterior se produjo puesto que se creó un nuevo párrafo que “divide” el contenido del actual párrafo 6 en un párrafo 6 y un párrafo 6 bis. El motivo de esta operación era que el actual párrafo 6 se denominaba “del estupro y

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

otros delitos sexuales”, siendo la intención separar los delitos para visibilizar, en particular, el delito que pasó a llamarse de delito de prostitución infantil a delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, no fue intención del legislador excluir el párrafo 5 de estas disposiciones, considerando que se trata de reglas comunes a estos ilícitos.

Adicionalmente, tratándose de normas ajenas al Código Penal, dichas adecuaciones deben realizarse también en el artículo 469 del Código Procesal Penal y en el artículo 191 bis de este mismo Código, que, a pesar de haberse derogado por la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, esta ley tiene entrada en vigencia diferida, por lo que es relevante de todas maneras hacer la adecuación. También se ha decidido introducir adecuaciones en el artículo 32 n°2 de la propia ley N° 21.057; en el artículo 6° numeral 10° del Código Orgánico de Tribunales; en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta; en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos y en el artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y en la ley N° 19.846 sobre calificación de la producción cinematográfica.

b) Incorporar el nuevo delito del 367 septies al estatuto de delitos sexuales contra NNAs:

Más allá de las adecuaciones formales anteriormente enunciadas, parece necesario que el proyecto de ley le otorgue el estatus de “delito sexual contra NNA” al nuevo artículo 367 septies, que crea un nuevo delito de transmisión, sin soporte o grabación, de material sexual de niños, niñas o adolescentes. De esta forma, en todas las normas en que se menciona un listado de delitos de esa connotación, debería incluirse este nuevo delito, lo cual se realiza a través del presente veto.

Para materializar lo anterior, el nuevo artículo 367 septies, debe incluirse en el listado de las siguientes normas: Dentro del Código Penal, en el artículo 368 ter; en el artículo 369 ter, referido a técnicas especiales de investigación; en el artículo 369 quinquies y en el artículo 372, referido a la pena de inhabilidad absoluta perpetua para desempeñar oficios o labores que involucren un desempeño con NNAs; en el artículo 469 del Código Procesal Penal, que establece un especial destino para las especies decomisadas por este tipo de delitos; en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, para excluir del beneficio de “rebajas de condena”; en la letra a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, para establecerlo como delito base de la figura de lavado de activos; en el artículo 6° numeral 10° del Código Orgánico de Tribunales; y, en el artículo segundo de la ley N° 21.160, para la renovación de la acción civil contra el imputado por un delito sexual cometido contra un NNA.

IV. LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY

Sobre el particular, en uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, vengo en formular las siguientes observaciones al referido proyecto de ley:

AL ARTÍCULO 1

1) Para reemplazar, el numeral 11, por el siguiente:

“11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 368 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázanse las expresiones “o 374 bis” por la expresión “, 367 quáter o 367 septies”.

2) Para incorporar el siguiente numeral 13, nuevo, pasando el actual numeral 13 a ser 14 y así sucesivamente:

“13. Suprímese el artículo 369 bis.”

3) Para reemplazar el numeral 13, que ha pasado a ser 14, por el siguiente:

“14. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 ter:

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázanse las expresiones “374 bis, inciso primero y 374 ter” por los vocablos “367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies”.

4) Para reemplazar el numeral 14, que ha pasado a ser 15, por el siguiente:

“15. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 quinquies:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Incorpórase, luego de la expresión “367 ter”, la expresión “, 367 quáter y 367 septies”.

5) Para incorporar el siguiente numeral 16, nuevo, pasando el actual numeral 15 que ha pasado a ser 16, a ser numeral 17 y así sucesivamente:

“16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

6) Para reemplazar el actual numeral 16, que ha pasado a ser 18, por el siguiente:

“18. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 372:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”;

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter, 367 septies”.

7) Para incorporar el siguiente numeral 19, nuevo, pasando el actual numeral 17 a ser 20:

“19) Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

AL ARTÍCULO 2

8) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

1. Modifícase, el inciso primero del artículo 1°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

2. Modifícase, el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis al Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

AL ARTÍCULO 3

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

9) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “367 ter” la frase “, 367 quáter, 367 septies”.

ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13, NUEVOS

10) Para incorporar los siguientes artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, nuevos, pasando el actual artículo 7 a ser 14:

“Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

a) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 191 bis, la frase “párrafos 5 y 6” por la expresión “párrafos 5, 6 y 6 bis”.

b) Reemplázanse, en el inciso cuarto del artículo 469, las expresiones “366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter” por las expresiones “367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies”.

Artículo 8.-

Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Agrégase entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue la expresión “, 367 quáter”.

c) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 septies”.

Artículo 9.-

Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter, 367 septies”.

Artículo 10.-

Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, entre la expresión “6°” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

Artículo 11.-

Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase, entre la expresión “6°” y conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

b) Elimínase la expresión “, 374 bis”.

Artículo 12.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

a) Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”;

Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Artículo 13.-

Reemplázanse, en el artículo 30 de la ley N° 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, las expresiones “en los artículos 366 quinquies, 374 bis y 374 ter” por las expresiones “367 quáter y 367 quinquies”.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

ANA LYA URIARTE RODRÍGUEZ

Ministra Secretaria General de la Presidencia

MARCELA RÍOS TOBAR

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[1] i. Componente línea de acción “análisis del problema”; ii. Componente línea de acción “Prevención”; iii. Componente línea de acción “Detección temprana y atención primaria”; iv. Componente línea de acción “Restitución de derechos y reparación del daño”; y v. Componente línea de acción “sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas”.

[2] “Es una violación fundamental de los derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud”. Declaración Programa de Acción Declaración de la reunión realizada en Estocolmo con motivo del Congreso Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños Estocolmo 24 de agosto de 1996 p. 1.

[3] Véase por ejemplo “Claves para un modelo de abordaje integral de la ESCNNA” p 28. Disponible en: www.fundacionrenacer.org

Oficio a la Corte Suprema

4.3. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 17 de octubre, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 17 de octubre de 2022

Oficio N° 17.788

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia de las Observaciones de S.E. el Presidente de la República formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín N° 14.440-07, con el objeto de que se pronuncie especialmente sobre lo dispuesto en el nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales.

Hago presente a V.E., de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución Política, que el proyecto está calificado con urgencia "suma".

Dios guarde a V.E.

RAÚL SOTO MARDONES

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Informe de Comisión de Constitución

4.4. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 18 de octubre, 2022. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 88. Legislatura 370.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BOLETÍN N° 14.440-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar las observaciones de S.E. el Presidente de la República, formuladas al proyecto individualizado en el epígrafe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de la República, artículos 32 y siguientes - Título III- de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y artículos 121 y 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, con urgencia calificada de “suma”.

Durante la tramitación y estudio de estas observaciones se contó con la colaboración y participación, de la señora Macarena Lobos (Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la República), del señor Jaime Gajardo (Subsecretario de Justicia), de la señora María Ester Torres (Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y de la señora Flora Ben- Azul (asesora legislativa de la División Jurídica del Ministerio).

Cabe hacer presente que la observación aditiva que incorpora el artículo 12 al proyecto, tiene rango orgánico constitucional de conformidad con el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental. Esta observación es del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

a) Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”;

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.”.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Se transcriben los antecedentes entregados por el Ejecutivo:

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA Y EL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL

El proyecto de ley que se observa tuvo origen en un Mensaje Presidencial de 23 de junio de 2021. Su fundamento se reconduce a una recomendación del Tercer Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

Dicha instancia corresponde a un esfuerzo multisectorial de coordinación de diversas instituciones públicas y privadas cuyo propósito es acordar compromisos para la prevención y sanción de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estas instituciones se comprometen a ejecutar diferentes acciones por un tiempo determinado, siendo encabezados por una Mesa Ejecutiva, que sistematiza la información reportada por cada una.

Desde la sociedad civil fueron muchas las instituciones que participaron en este Tercer Marco: ONG Raíces; ONG Social Creativa; Corporación Opción; ONG Paicabí; Fundación Social Novo Millenio; Fundación Tierra Esperanza; Corporación SERPAJ; Corporación Prodel; Fundación Ciudad del Niño; Corporación de Apoyo y Promoción de la Equidad en Inclusión Social. Todas estas organizaciones, dedicadas a la protección especializada frente a la

Informe de Comisión de Constitución

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, participaron en el Primer y Segundo Marco para la Acción con el mismo propósito, es decir, proponer un nuevo marco legal de protección para niños, niñas y adolescentes.

Las recomendaciones del informe multisectorial se estructuraron en cinco líneas de acción[1], dentro de las cuales, la quinta, dice relación con la línea de acción que procura determinar la “sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas”.

Respecto de esta línea de acción, el informe relevó la incorrecta aproximación al problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que tiene la regulación sustantiva en el Código Penal chileno que, en definitiva, profundiza la victimización secundaria de los afectados.

En efecto, las leyes que actualmente regulan esta materia desvirtúan el problema. El derecho nacional contempla el delito de “prostitución infantil” lo que constituye una etiqueta errada sobre el fenómeno. Ello, pues supone que una persona menor de edad vende su cuerpo de manera premeditada y consciente a un adulto. La así llamada “prostitución infantil” es, en realidad, explotación infantil. El fenómeno tiene como base la capacidad de poder que ejerce un explotador sobre una niña, un niño o adolescente que, generalmente, ha padecido abusos y violencia sexual desde sus primeros años. Así, el adulto capitaliza el abandono y la orfandad emocional de niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y de violencia que puede equipararse al trabajo forzoso, incluso a una forma contemporánea de esclavitud, como la define[2] y otros organismos especializados.

Así, este proyecto de ley nace para hacerse cargo del problema detectado. Con este diagnóstico, seguir usando la noción de “prostitución infantil” es un error conceptual que debe ser corregido, tornándose obligatorio actualizar la legislación con el objeto de condenar sin vacilaciones este tipo de crímenes. Lo anterior es especialmente decisivo si se considera que la mayoría de las víctimas no se perciben como tales y establecen una dependencia afectiva de su explotador [3].

II. TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA

a) Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados

Como ya fue mencionado, la iniciativa fue ingresada a través de Mensaje el 23 de junio de 2020 a la Cámara de Diputados, siendo estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta comisión emitió su primer informe el día 7 de diciembre de 2021.

Tras el respectivo debate y estudio de las propuestas contenidas en la iniciativa legal, así como de aquellas sugerencias levantadas durante su tramitación, el proyecto fue aprobado y despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 13 de diciembre de 2021, realizando los siguientes cambios:

- i. Se incorporó un nuevo artículo 367 quáter, reemplazando la referencia al artículo 366 quinquies, y un nuevo artículo 367 septies en el artículo 94 bis del Código Penal, con el objeto de aplicar la norma de imprescriptibilidad de la acción penal.
- ii. Sin sustituir ni modificar en otros aspectos el artículo 367 del Código Penal, que contiene el nuevo delito de explotación sexual comercial, se aumentó la pena en un grado respecto de la propuesta original.
- iii. Se dividió el inciso primero del artículo 367 quáter con el objeto de dejar en una norma separada -nuevo inciso segundo- la figura de producción de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.
- iv. Se creó un nuevo delito en el artículo 367 septies no contemplado en la propuesta original que sanciona la transmisión, sin soporte o grabación, de la imagen o sonido de una interacción sexual que involucra a una persona menor de 18 años.
- v. Se replicó la norma actual, como un nuevo artículo 367 octies, idéntica a la aplicable al delito de trata de personas contenida en el artículo 411 septies, para que la agravante de reincidencia pueda darse por satisfecha por cargo a las sentencias condenatorias dictadas en el extranjero.
- vi. Se realizaron adecuaciones en el Código Penal con el objeto de actualizar las referencias, habida cuenta de que

Informe de Comisión de Constitución

el nuevo artículo 367 quáter sintetizaba y contenía las ideas regulativas de los artículos 366 quinquies y 374 bis, las que el proyecto deroga. Adicionalmente, las modificaciones tuvieron en consideración que la existencia de un nuevo párrafo, el “6 bis” que se intercala entre los párrafos 6 y 7, hacía necesario referirse, en las normas comunes a los párrafos anteriores (párrafo 7 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal) a los “tres” párrafos anteriores en reemplazo de la palabra “dos”. Esta adecuación efectivamente se hizo tanto en el nombre del párrafo 7, como en los artículos 368, 368 bis, 368 ter, 369, 369 ter, 369 quinquies, 371 y en los incisos segundo y tercero del artículo 372.

vii. Se realizaron también actualizaciones en el mismo sentido que el literal anterior en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad; en el artículo 4° de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; y, en el Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

b) Segundo Trámite Constitucional en el Senado

La iniciativa fue estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

El debate en la Comisión recayó sobre el perfeccionamiento del artículo 366 quáter, que no había sido objeto de modificaciones por parte del Ejecutivo, ni por la Cámara de Diputadas y Diputados, en lo relativo a la nomenclatura de la noción de “pornografía” de personas menores de 18 años, y en lo relativo a la clarificación del destino de la “retribución” en los delitos de explotación sexual comercial.

Tras la discusión en sala, el proyecto fue aprobado el día 6 de septiembre de 2022 y despachado a tercer trámite en los siguientes términos:

i. Respecto a la modificación del artículo 366 quáter del Código Penal, se sustituyeron los actuales incisos primero y segundo, por nuevos incisos primero, segundo y tercero, pasando el resto de los apartados del artículo a ordenarse correlativamente. De esta forma, se eliminó la tendencia interna o ánimo especial libidinoso respecto de las siguientes hipótesis: (i) Determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual o a hacerla ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter (ii) Determinar a una persona menor de 14 años a enviar imágenes o grabaciones que representen acciones de significación sexual, propias o de otro menor de 14 años, o imágenes o grabaciones de sus genitales, propias o de otro menor de 14 años;

ii. Se agregó, en todas las normas que hacen referencia al “material pornográfico” de niños, niñas o adolescentes la expresión “de explotación sexual”; y,

iii. Se aclaró que la retribución a que hace referencia el delito de explotación sexual de niños, niñas o adolescentes puede estar destinada al propio menor de edad o a un tercero.

c) Tercer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados

La Cámara de Diputados, en sesión de 13 de septiembre de 2022, aprobó las enmiendas propuestas por el H. Senado, remitiendo Oficio de Ley al Gobierno para su promulgación.

III. FUNDAMENTOS DE LAS OBSERVACIONES

Los cambios que se proponen se refieren, por una parte, a la actualización de referencias o remisiones de una norma a otros artículos y, por otra, a la inclusión del artículo 367 septies, creado por el proyecto, en el estatuto general de delitos sexuales contra NNAs.

a) Adecuaciones de referencias:

En relación con el primero de los asuntos, si bien en la Cámara de Diputadas y Diputados se hicieron algunas adecuaciones de referencia como consecuencia de la nueva ubicación de los delitos que involucran material pornográfico o que se relacionan con la explotación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, dada la complejidad y consecuencias que tienen las modificaciones introducidas a normas

Informe de Comisión de Constitución

sobre delitos sexuales, se ha advertido la necesidad de agregar referencias adicionales en otras normas del cuerpo punitivo y de otras legislaciones sectoriales. Estos ajustes de referencia tienen lugar en un área del derecho profundamente caracterizada por el apego al principio de legalidad, como lo es el derecho penal, por lo cual deben ser realizados. Asimismo, es necesario establecer una legislación íntegra y coherente que refuerce el carácter racional del legislador chileno.

Por una parte, algunas de estas correcciones suceden en el propio seno del Código Penal. En particular, en el artículo 369 bis, en el artículo 369 ter, en el artículo 369 quinquies, en el artículo 370 bis, en el inciso primero del artículo 372 y en el artículo 372 ter.

En el caso del artículo 369 bis, este aplica las reglas de la sana crítica en los delitos sexuales, lo cual es innecesario hoy dadas las reglas especiales de valoración que existen en el Código Procesal Penal. Por esta razón se ha decidido propiciar su supresión.

En el caso del artículo 369 ter, dicha norma debió haber hecho mención a los incisos primero y segundo del artículo 367 quáter y no solo a su inciso primero a partir del cambio en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por otra parte, en los demás casos se ha buscado enmendar los problemas de referencia que se derivan de que no se modificó la mención de “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores” que hacen operativas las reglas del párrafo 7 en algunas normas. De esta manera, se propone sustituir dicha referencia ampliando finalmente a los párrafos 5, 6 y 6 bis, para así no dejar fuera a las hipótesis de violación (párrafo 5) de las reglas comunes, que no fueron indicadas del párrafo 7.

Lo anterior se produjo puesto que se creó un nuevo párrafo que “divide” el contenido del actual párrafo 6 en un párrafo 6 y un párrafo 6 bis. El motivo de esta operación era que el actual párrafo 6 se denominaba “del estupro y otros delitos sexuales”, siendo la intención separar los delitos para visibilizar, en particular, el delito que pasó a llamarse de delito de prostitución infantil a delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, no fue intención del legislador excluir el párrafo 5 de estas disposiciones, considerando que se trata de reglas comunes a estos ilícitos.

Adicionalmente, tratándose de normas ajenas al Código Penal, dichas adecuaciones deben realizarse también en el artículo 469 del Código Procesal Penal y en el artículo 191 bis de este mismo Código, que, a pesar de haberse derogado por la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, esta ley tiene entrada en vigencia diferida, por lo que es relevante de todas maneras hacer la adecuación. También se ha decidido introducir adecuaciones en el artículo 32 n°2 de la propia ley N° 21.057; en el artículo 6° numeral 10° del Código Orgánico de Tribunales; en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta; en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos y en el artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y en la ley N° 19.846 sobre calificación de la producción cinematográfica.

b) Incorporar el nuevo delito del 367 septies al estatuto de delitos sexuales contra NNAs:

Más allá de las adecuaciones formales anteriormente enunciadas, parece necesario que el proyecto de ley le otorgue el estatus de “delito sexual contra NNA” al nuevo artículo 367 septies, que crea un nuevo delito de transmisión, sin soporte o grabación, de material sexual de niños, niñas o adolescentes. De esta forma, en todas las normas en que se menciona un listado de delitos de esa connotación, debería incluirse este nuevo delito, lo cual se realiza a través del presente veto.

Para materializar lo anterior, el nuevo artículo 367 septies, debe incluirse en el listado de las siguientes normas: Dentro del Código Penal, en el artículo 368 ter; en el artículo 369 ter, referido a técnicas especiales de investigación; en el artículo 369 quinquies y en el artículo 372, referido a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar oficios o labores que involucren un desempeño con NNAs; en el artículo 469 del Código Procesal Penal, que establece un especial destino para las especies decomisadas por este tipo de delitos; en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, para excluir del beneficio de “rebajas de condena”; en la letra a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, para establecerlo como delito base de la figura de lavado de activos; en el artículo 6° numeral 10°

Informe de Comisión de Constitución

del Código Orgánico de Tribunales; y, en el artículo segundo de la ley N° 21.160, para la renovación de la acción civil contra el imputado por un delito sexual cometido contra un NNA.

II.- TEXTO DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.

AL ARTÍCULO 1

1) Para reemplazar, el numeral 11, por el siguiente:

“11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 368 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázanse las expresiones “o 374 bis” por la expresión “, 367 quáter o 367 septies”.”.

2) Para incorporar el siguiente numeral 13, nuevo, pasando el actual numeral 13 a ser 14 y así sucesivamente:

“13. Suprímese el artículo 369 bis.”

3) Para reemplazar el numeral 13, que ha pasado a ser 14, por el siguiente:

“14. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázanse las expresiones “374 bis, inciso primero y 374 ter” por los vocablos “367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies”.”.

4) Para reemplazar el numeral 14, que ha pasado a ser 15, por el siguiente:

“15. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 quinquies:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Incorpórase, luego de la expresión “367 ter”, la expresión “, 367 quáter y 367 septies”.”.

5) Para incorporar el siguiente numeral 16, nuevo, pasando el actual numeral 15 que ha pasado a ser 16, a ser numeral 17 y así sucesivamente:

“16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.”.

6) Para reemplazar el actual numeral 16, que ha pasado a ser 18, por el siguiente:

“18. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 372:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”;

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter, 367 septies”.”.

7) Para incorporar el siguiente numeral 19, nuevo, pasando el actual numeral 17 a ser 20:

“19) Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.”.

AL ARTÍCULO 2

Informe de Comisión de Constitución

8) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

1. Modifícase, el inciso primero del artículo 1°, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo.”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

2. Modifícase, el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis al Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

AL ARTÍCULO 3

9) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies;”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “367 ter” la frase “, 367 quáter, 367 septies”.

ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13, NUEVOS

10) Para incorporar los siguientes artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, nuevos, pasando el actual artículo 7 a ser 14:

“Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

a) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 191 bis, la frase “párrafos 5 y 6” por la expresión “párrafos 5, 6 y 6 bis”.

b) Reemplázanse, en el inciso cuarto del artículo 469, las expresiones “366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter” por las expresiones “367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies”.

Artículo 8.- Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Agrégase entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue la expresión “, 367 quáter”.

c) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 septies”.

Artículo 9.- Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter, 367 septies”.

Artículo 10.- Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema

Informe de Comisión de Constitución

Nacional de Registros de ADN, entre la expresión “6°” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

Artículo 11.- Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

- a) Intercálase, entre la expresión “6°” y conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.
- b) Elimínase la expresión “, 374 bis”.

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

- b) Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”;
- b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Artículo 13.- Reemplázanse, en el artículo 30 de la ley N° 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, las expresiones “en los artículos 366 quinquies, 374 bis y 374 ter” por las expresiones “367 quáter y 367 quinquies”.

III.- SÍNTESIS DEL DEBATE SOSTENIDO ACERCA DE LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO.

Sesión N° 47 de 18 de octubre de 2022.

La señora Macarena Lobos (Subsecretaria Secretaría General de la Presidencia) saluda a las y los integrantes de la Comisión.

Refiere que la observación del Presidente de la República tiene por objeto realizar adecuaciones formales en tres aspectos, a saber: A) con la incorporación del título 6 bis, que hace referencia tanto al nuevo tipo penal como al catálogo de sanciones relativas a los nuevos tipos penales, se hace necesario agregar al proyecto aprobado por el Congreso una referencia expresa a la incorporación del párrafo nuevo en aquellas normas posteriores. De lo contrario, el nuevo tipo penal no tendría aplicación en el mismo, lo que sería un error no deseado por el legislador; B) en segundo lugar, son adecuaciones a otros cuerpos legales, tales como la leyes N°s 21.057, 19.913, 19.831 y 19.846, todas sobre las cuales no se hizo, en su discusión en las Cámaras, referencia alguna con los nuevos tipos penales de los artículos 366 quáter y 367 septies; C) como tercer punto, si bien no viene corregido en el veto, porque materialmente no se puede hacer, también se considera la existencia de la nueva Ley Antonia, boletín N° 13688-25, que establece nuevos tipos penales y que actualmente se encuentra en trámite en el Tribunal Constitucional. Al respecto, es necesario hacer algunas adecuaciones a tipos penales que desaparecen con este proyecto en trámite y evitar colisiones entre ambos cuerpos normativos que modifican el Código Penal, ya que algunos tipos penales a los que hace referencia la Ley Antonia desaparecen con la aprobación del presente proyecto.

El señor Jaime Gajardo (Subsecretario de Justicia) explicó que un primer aspecto es modificar la correlativa con las normas que quedaron afuera con la incorporación del párrafo 6 bis y el nuevo delito del artículo 366 quáter y el 367 septies de la misma forma. En definitiva, en un veto que realiza adecuaciones formales y de correlación.

Esta materia de delitos sexuales ha sido la más modificada en los últimos años, a modo de ejemplo, la ley de entrevistas videograbadas y otros cuerpos, son recientes (2019 al 2022) y este conjunto de cuerpos normativos, que modifican los delitos sexuales, no están debidamente actualizadas en el presente proyecto, por lo que se hace imperioso subsanarlo antes de su publicación.

Lo anterior, sucede de tres formas, a saber:

- a) El proyecto crea un nuevo párrafo 6 bis, que ahora contiene todos los delitos de explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

Informe de Comisión de Constitución

- Debe incluirse allí donde hay referencia a los párrafos 5 y 6 del título VII del Libro II, pues obedece a la misma lógica de sanción de delitos sexuales.

- Las referencias a “los dos párrafos anteriores” ahora debe ser hecha a “los tres párrafos anteriores”, pues de otra manera se dejaría fuera, con la incorporación de este nuevo párrafo, al párrafo 5 relativo al delito de violación

b) Combina dos artículos (366 quinquies y 374 bis) en un nuevo artículo 367 quáter, contenidos en el nuevo párrafo 6 bis.

- Debe actualizarse la referencia reemplazando esas menciones por la del artículo 367 quáter nuevo.

c) Crea un nuevo delito en el artículo 367 septies de transmisión de material pornográfico, también contenido en el nuevo párrafo 6 bis.

- Dado que tiene la misma pena y afecta de manera muy similar al NNA que se ve involucrado en este tipo de conductas, amerita que éste sea también incluido en aquellas reglas comunes relativas a los delitos sexuales cometidos contra NNA (reglas procesales, sobre prescripción, relativas a inhabilidades, beneficios penitenciarios, etc.)

La diputada señora Jiles pregunta cuál es la razón técnica de ingresar el veto antes de la publicación de la ley Antonia, entendiendo que con su entrada en vigencia igualmente tendremos que hacer adecuaciones.

La Subsecretaria señora Macarena Lobos refiere que la razón técnica responde al hecho de que el plazo para vetar la ley hubiera expirado si hubiesen esperado el despacho de ley Antonia en el Tribunal Constitucional. El riesgo era grande, porque no habrían podido aplicar las agravantes a los delitos sexuales en caso de que ley Antonia no fuera despachada.

El diputado señor Sánchez tiene la impresión que estas modificaciones corrigen cuestiones de forma, pero aprovecha la opinión para preguntarle al gobierno su opinión en cuanto al criterio en el artículo 366 quáter. Refiere que este artículo pone dentro de la misma categoría acciones de significación sexual en de niños, niñas y adolescentes, tales como exhibirles material pornográfico y acciones de connotación sexual, y en su modificación y posterior aprobación se establecen penas distintas, lo que califica como un error.

En efecto, indicó que las hipótesis de los incisos primero y segundo del artículo al que hizo referencia suponen, en primer lugar, que un adulto realice acciones de significación sexual frente a un niño, mientras que su inciso segundo refiere lo contrario, es decir, que un niño las realice frente a un adulto, motivado por este último. Cree que en ambos casos se comparte la gravedad del hecho, pero que el proyecto castiga con una pena menor cuando se hace por parte de un adulto y con una pena mayor cuando lo hace un niño, por lo que solicita al Ejecutivo explicar los fundamentos que hay detrás.

El Subsecretario señor Gajardo señala que hay que considerar que el proyecto de ley que dio inicio a la tramitación del presente mensaje se ingresó en julio del 2021, culminando con su aprobación en tercer trámite constitucional el 13 de septiembre del presente año, por lo que no es un proyecto de este Gobierno.

Ahora, frente a la pregunta realizada, expresó que va más allá del objeto del veto, el que solo realiza adecuaciones formales, y que en ningún caso quiere o desea hacer mención a la discusión del fondo del mensaje.

La diputada señora Jiles cree que la respuesta del ejecutivo es “pésima”. La pregunta del diputado Sánchez ha desatado un desastre, ya que aparentemente no hay una respuesta a la misma, lo que cree que los hace entrar a un conflicto legislativo en la materia.

La amplitud o extensión del veto es definida por el Ejecutivo, y a partir de su respuesta les cabe la duda sobre el criterio sobre el cual, luego de una revisión completa de todo el texto, se deja sin discutir el fondo de este asunto del artículo 366 quáter.

Estando el veto en curso, podrían cambiar de parecer y corregir lo que pareciere ser un problema sin respuesta adecuada.

La Subsecretaria señora Lobos refiere que la consulta formulada por Sánchez responde que son hipótesis distintas,

Informe de Comisión de Constitución

lo que justifica su pena.

En efecto, el inciso primero refiere “El que, sin realizar una acción sexual en los términos anterior, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo”. Es decir, cuando efectivamente un adulto lo realice.

Luego, en su inciso segundo se dispone otra hipótesis, esto es: “Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo”.

De la lectura de ambas, se concluye que no estamos hablando de la misma hipótesis, por ende se le atribuyen distintas sanciones.

El diputado señor Sánchez agradece la explicación. Reafirma entonces que hay una idea de que hay acciones distintas, pero le parece un profundo error el creer que son conductas de distinta gravedad.

Si un adulto realiza conductas de significación sexual o un menor las realiza frente a un adulto que lo incitó a realizarlas, cree que son igualmente gravísimas. Cree que hay un error que se ha cometido como institución, como Congreso Nacional.

Con todo, eso no altera la discusión sobre el veto, dado que son cambios formales.

El Subsecretario señor Gajardo indica que el objeto del veto es respetar la voluntad del Congreso y realizar una modificación meramente formal, con el objeto que todas las modificaciones aprobadas por ambas Cámaras estuvieran en los cuerpos legales normativos respectivos.

La diputada señorita Cariola (Presidenta), considerando que no hay más preguntas, sugiere hacer la votación por la totalidad del veto, en un solo acto, lo cual es aceptado por la Comisión.

VOTACIÓN ÚNICA

Sometidas a votación, en su totalidad y en un solo acto las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que “Introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes”, boletín N° 14.440-07, son aprobadas por unanimidad. Votaron a favor los (as) diputados (as) Karol Cariola (Presidenta de la Comisión), Jorge Alessandri, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Raúl Leiva, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez, Leonardo Soto, y Gonzalo Winter (10-0-0).

Se designa como diputada Informante a la señorita Catalina Pérez.

Tratado y acordado en sesión de fecha 18 de octubre de 2022, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Karol Cariola (Presidenta de la Comisión); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Raúl Leiva; Andrés Longton; Catalina Pérez; Luis Sánchez; Leonardo Soto; Gonzalo Winter.

Sala de la Comisión, a 18 de octubre de 2022.

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

[1] i. Componente línea de acción “análisis del problema” ii. Componente línea de acción “Prevención” iii. Componente línea de acción “Detección temprana y atención primaria” iv. Componente línea de acción “Restitución de derechos y reparación del daño” y v. Componente línea de acción “sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas”.

[2] “Es una violación fundamental de los derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por adultos y la

Informe de Comisión de Constitución

remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud". Declaración Programa de Acción Declaración de la reunión realizada en Estocolmo con motivo del Congreso Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños Estocolmo 24 de agosto de 1996 p. 1.

[3] Véase

por ejemplo "Claves para un modelo de abordaje integral de la ESCNNA" p 28. Disponible en: www.fundacionrenacer.org

Discusión en Sala

4.5. Discusión en Sala

Fecha 24 de octubre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 89. Legislatura 370. Discusión Observaciones Presidente de la República. Se aprueba.

INTRODUCCIÓN DE NUEVO PÁRRAFO A CÓDIGO PENAL RELATIVO A PROXENETISMO, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES (OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. BOLETÍN N° 14440-07)

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín N° 14440-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señorita Catalina Pérez .

Antecedentes:

-Observaciones de S.E el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, sesión 86ª de la presente legislatura, en lunes 17 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 88ª de la presente legislatura, en miércoles 19 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 9.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

Durante la tramitación y estudio de estas observaciones se contó con la colaboración y participación de la señora Macarena Lobos , subsecretaria general de la Presidencia; del señor Jaime Gajardo , subsecretario de Justicia, y de la señora María Ester Torres , jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El propósito fundamental de las observaciones es el siguiente:

Adecuaciones de referencias

Como consecuencia de la nueva ubicación de los delitos que involucran material pornográfico o que se relacionan con la explotación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, se ha advertido la necesidad de agregar referencias adicionales en otras normas del cuerpo punitivo y de otras legislaciones sectoriales.

Por una parte, algunas de estas correcciones suceden en el propio seno del Código Penal, en particular en los artículos 369 bis, 369 ter, 369 quinquies, 370 bis, 372, inciso primero, y 372 ter.

En el caso del artículo 369 bis, este aplica la regla general de la sana crítica en los delitos sexuales, lo cual es innecesario hoy dadas las reglas especiales de valoración que existen en el Código Procesal Penal. Por esta razón,

Discusión en Sala

se decidió derogarlo.

En el caso del artículo 369 ter, dicha norma debió haber hecho mención a los incisos primero y segundo del artículo 367 quater y no solo a su inciso primero, como consecuencia de las modificaciones del proyecto.

Por otra parte, en los demás casos se ha buscado enmendar los problemas de referencia que se derivan del hecho de que no se modificó la mención “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”, dado que en el proyecto se agregó un nuevo párrafo 6 bis.

En efecto, se creó un nuevo párrafo que divide el contenido del actual párrafo 6 en un párrafo 6 y un párrafo 6 bis. El motivo de esta operación fue que el actual párrafo 6 se denominaba “Del estupro y otros delitos sexuales”, siendo la intención separar los delitos para visibilizar en particular el delito que pasó a llamarse de delito de prostitución infantil a delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, no fue intención del legislador excluir el párrafo 5 de estas disposiciones, considerando que se trata de reglas comunes a estos ilícitos.

Adicionalmente, tratándose de normas ajenas al Código Penal, dichas adecuaciones deben realizarse también en el artículo 469 del Código Procesal Penal y en el artículo 191 bis de este mismo código, que, a pesar de haberse derogado por la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, esta ley tiene entrada en vigencia diferida, por lo que es relevante de todas maneras hacer la adecuación.

También se ha decidido introducir adecuaciones en el artículo 32, número 2, de la propia ley N° 21.057; en el artículo 6, numeral 10, del Código Orgánico de Tribunales; en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta; en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el artículo 4 de la ley N° 19.831, que crea el Registro de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, y en la ley N° 19.846, Sobre Calificación de la Producción Cinematográfica.

Incorporar el nuevo delito del 367 septies al estatuto de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes

Más allá de las adecuaciones formales anteriormente enunciadas, parece necesario que el proyecto de ley otorgue el estatus de delito sexual contra niños, niñas y adolescentes al nuevo artículo 367 septies, que crea un nuevo delito de transmisión, sin soporte o grabación, de material sexual de niños, niñas o adolescentes. De esta forma, en todas las normas en que se menciona un listado de delitos de esa connotación, debe incluirse este nuevo delito, lo cual se realiza a través del presente veto.

Para materializar lo anterior, el nuevo artículo 367 septies, debe incluirse en varias normas relativas a delitos sexuales contra menores, a saber:

Dentro del Código Penal, en el artículo 368 ter, que sanciona al propietario o encargado del local donde se cometen los delitos contra niños, niñas y adolescentes; en el artículo 369 ter, referido a técnicas especiales de investigación; en el artículo 369 quinquies y en el artículo 372, que se refieren a la pena de inhabilidad absoluta perpetua para desempeñar oficios o labores que involucren un desempeño con niños, niñas y adolescentes; en el artículo 469 del Código Procesal Penal, que establece un especial destino para las especies decomisadas por este tipo de delitos; en la letra e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, para excluir del beneficio de rebajas de condena; en la letra a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, para establecerlo como delito base de la figura de lavado de activos; en el artículo 6, numeral 10°, del Código Orgánico de Tribunales, que determina los crímenes y simples delitos que quedan sometidos a la jurisdicción chilena, aun cuando fueren perpetrados fuera del territorio de la república, y en el artículo 2° de la ley N° 21.160, para la renovación de la acción civil contra el imputado por un delito sexual cometido contra un niño, niña o adolescente.

Habiendo sido aprobadas por unanimidad estas observaciones por la Comisión que represento, igualmente solicito su aprobación en esta honorable Sala.

Es cuanto puedo informar.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para que el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo Falcón , haga ingreso a la Sala?

Acordado.

En discusión las observaciones de su excelencia el Presidente de la República. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, la realidad nos ha demostrado la necesidad de ir actualizando cada cierto tiempo la legislación penal, especialmente en lo referente a delitos que afectan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños, niñas y adolescentes. Siempre se buscan nuevas maneras de delinquir, nuevas formas de abusar y de aprovecharse de quienes tienen menores posibilidades de defenderse.

Tal como se menciona expresamente en los antecedentes de este proyecto de ley, la legislación penal nacional en materia de delitos sexuales ha venido experimentando importantes reformas que han tenido por finalidad entregar herramientas eficaces para la persecución de determinadas conductas cuyas víctimas son, principalmente, niños, niñas y adolescentes.

Hemos avanzado en temas como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el acoso sexual contra menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil, entre otros aspectos. En este sentido, valoramos que este proyecto de ley ponga en relevancia la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un tratamiento penal especial en un nuevo párrafo del Código Penal. Es un avance, pero no es suficiente.

Desde hace algún tiempo hemos advertido sobre la urgencia de legislar, considerando especialmente los riesgos a los cuales se ven afectados los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, donde la reinserción de adolescentes infractores ha fallado, donde la institucionalidad protectora ha fallado y donde la delincuencia, día a día, es más violenta e indolente, llegando a agredir a menores de edad sin ningún tipo de conciencia. Se trata de una serie de situaciones que configuran vulneraciones a los derechos humanos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes, y que requieren de más esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad civil.

Esto se concreta con fuerza en la legislación penal con este proyecto de ley que votaremos hoy, pues el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes requiere por parte del Estado de otras formas de abordarlo, apuntando a la sanción, pero sobre todo a la prevención. Por ello, cobra tanta relevancia el problema de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes y los sistemas de búsqueda, que durante décadas no han sido del todo eficientes en esta labor. Ahí se presenta la oportunidad para que se sigan cometiendo delitos de esta gravedad y naturaleza.

Como Estado debemos ser más proactivos y no solo quedarnos en la tipificación y la sanción de un delito, sino también crear las condiciones necesarias para que su prevención sea eficaz. Es esa la respuesta que más necesitan los miles de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados año a año en nuestro país.

Llamo a votar a favor del proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, no es un secreto que como Estado no hemos estado a la altura de la protección y el resguardo de la infancia. Así lo constatamos, por ejemplo, cuando conocimos las lamentables conclusiones que arrojó el

Discusión en Sala

Informe de la comisión especial investigadora de las situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado, aprobado hace algunos meses en este mismo hemiciclo.

Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso que quizás pueda parecernos pequeño, pero que en realidad es inmensamente significativo en la protección de la infancia.

Este proyecto viene a cumplir con una de las más de cuarenta recomendaciones que realizó el informe de esa comisión especial investigadora para avanzar, de una vez por todas, de manera conjunta y coordinada, en la protección y el resguardo de los niños, niñas y adolescentes.

Es indispensable efectuar la modernización del tipo penal de prostitución infantil con una regulación acorde a la verdadera naturaleza de este tipo de delitos; estamos hablando de abuso infantil. ¿Por qué es tan significativo? Porque cuando hablamos de prostitución infantil y no de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, mantenemos la percepción de que los niños, pero sobre todo las niñas y las adolescentes, que son las principales afectadas por este tipo de explotación, presentan algún grado de voluntariedad en la participación de este delito y, con ello, negamos su condición de víctimas y obviamos la asimetría de poder que subyace entre las víctimas y sus victimarios adultos.

El veto presidencial realiza adecuaciones que son muy necesarias, subsana algunos errores formales del proyecto, agregando referencias normativas que no se habían contemplado, ya que la legislación punitiva había sufrido algunas modificaciones durante la tramitación de este proyecto, e incorpora el nuevo delito de transmisión de material sexual de niños, niñas y adolescentes del artículo 367 septies del Código Penal al listado de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Todo esto con apego al principio de legalidad.

Por ello, anuncio desde ya nuestro voto favorable y hago un llamado a todas y todos mis colegas a hacer lo mismo, a fin dar celeridad a la tramitación de este proyecto, que es indispensable, junto con las demás medidas que debemos tomar como Estado, para proteger a nuestra infancia y, en particular, a aquellos niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Aprovecho de saludar al recién electo presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez .

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley es de suma relevancia y así ha quedado demostrado en su larga tramitación en ambas cámaras y en el reciente veto presidencial.

Aquí está en juego la dignidad sexual de los niños, niñas y adolescentes que piden a gritos una firme protección.

Este proyecto crea un apartado dedicado exclusivamente a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y me parece que es un gran avance para visibilizar, proteger y castigar de forma más severa a quienes se atreven a cometer delitos en que estén involucrados menores de edad, conductas que quedan impunes durante años en nuestro país.

La actual legislación regula la prostitución infantil que persigue el comercio sexual con un menor que, de manera consciente y premeditada, vende su cuerpo a un adulto. Sin embargo, el fenómeno observado en realidad constituye una etiqueta errada, pues lo que en realidad sucede es la explotación infantil, donde bandas especializadas en el comercio sexual se aprovechan y abusan de la carencia de afectividad emocional de los menores para realizar trabajos forzosos y denigrantes, lo que significa una forma contemporánea de esclavitud infantil.

No solo necesitamos perseguir el comercio sexual, sino también condenar sin vacilaciones y aplicar toda la rigurosidad de la ley contra quienes están a cargo de las redes de prostitución, comercio sexual y pornografía infantil. En definitiva, queremos que aquel que utilice a nuestros niños lo piense dos veces, pues todas aquellas

Discusión en Sala

conductas de índole sexual para beneficio propio, económico y personal serán condenadas de forma implacable.

Por último, quiero hacer hincapié en que cualquier abuso a un menor de edad debe ser considerado con la misma severidad. No nos podemos permitir hacer distinción en la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, votaré a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señora Presidenta, resultan de gran relevancia y necesidad las observaciones del Presidente de la República a un proyecto que tiene que ver con los pilares estructurales de la desigualdad y su plena vigencia.

La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno social bajo las lógicas de poder, pues en la mayoría de los casos los explotadores, a cambio de una prestación económica, abusan de niñas, niños y adolescentes históricamente vulnerados en sus derechos económicos y sociales, lo que favorece, además, la impunidad, pues la realidad es que esos niños son considerados de segunda categoría, una suerte de unidades de valor económico, siendo esta una de las formas más perversas de castigar la pobreza en Chile.

El veto permite la operatividad de la futura ley y mantiene la esencia en cuanto a solucionar el problema de varios tipos penales, los que contienen un enfoque que supone una suerte de participación voluntaria de los niños por la prestación que reciben, al hablar de favorecimiento de la prostitución infantil, obtención de servicios sexuales de menores de edad, producción de material pornográfico, todo lo cual es necesario adecuar, pues el niño, niña y adolescente es víctima indiscutible y no tiene ningún grado de participación.

El comité que supervisa la Convención sobre los Derechos del Niño advierte que el Estado es un garante en esta materia y que la explotación sexual y comercial de niños constituye una grave violación a los derechos humanos. No olvidemos que una comisión especial de esta Cámara, mandatada a investigar estos casos, nos alertó sobre la ausencia sistémica del Estado en el cumplimiento de su obligación de garante, especialmente respecto de niños o niñas que se encuentran bajo su tutela. Además, el abuso y explotación no son aislados, sino de larga data, facilitados por la debilidad institucional que encubre redes criminales, tal como ocurrió en el Cread Pudahuel, donde la magistrada Mónica Jeldres constató la existencia de redes de explotación sexual comercial, lo que la obligó a solicitar una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por todas estas razones, aprobaremos estas observaciones.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara: valoro significativamente la propuesta de este proyecto de ley, ya que viene a otorgar una mayor protección para nuestros niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran expuestos a diversas hipótesis delictivas y de explotación sexual.

Las observaciones ingresadas por el Ejecutivo vienen a dar congruencia a los diferentes textos legales relacionados con los delitos sexuales contra menores, los que han sido, reiteradamente, modificados durante los últimos años. Asimismo, las observaciones vienen a armonizar el texto de la nueva ley con los artículos del Código Orgánico de Tribunales y diversas otras leyes o cuerpos legales, entre ellas, la ley que regula las entrevistas videograbadas a menores víctimas de delitos sexuales y la que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, todo ello -repito- en

Discusión en Sala

concordancia con la debida armonía y congruencia que debe tener nuestro ordenamiento jurídico en las diferentes materias.

Por todo lo anterior, apoyo las observaciones introducidas por su excelencia el Presidente de la República.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley ya fue aprobado por la honorable Cámara y por el Senado. Sin lugar a dudas, constituye un avance significativo, ya que consagra importantes modificaciones y adiciones al Código Penal y a otros cuerpos legales en lo relativo a delitos de abuso sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

La persecución penal a los perpetradores de estos gravísimos delitos que afectan a nuestra población más vulnerable, como han dicho todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, es un deber primordial del Estado, el que ha sido refrendado, además, por distintos tratados internacionales suscritos por nuestro país. Quienes cometen esos delitos no solo causan daño permanente a las víctimas y su entorno cercano, sino a toda la sociedad, pues desnaturalizan nuestra propia condición humana.

En este sentido, es destacable que el veto presentado por el Ejecutivo introduzca mejoras al proyecto aprobado por el Congreso Nacional, a fin de armonizar y concordar las modificaciones introducidas con las normas del Código Penal vigente y otras disposiciones legales, para constituir una unidad coherente y sistemática capaz de ser aplicada por los tribunales de justicia y los demás operadores jurídicos en favor de las víctimas.

Por esta razón, apruebo convencida las observaciones presentadas por el gobierno, pues son necesarias y convenientes en la línea de perfeccionar el marco de protección de niñas, niños y adolescentes. Pido al resto de los diputados presentes que las sancionen favorablemente.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley ya fue aprobado en esta Sala. Lo que hoy discutimos es un veto presidencial que viene a introducir algunas modificaciones más bien formales, sin alterar el fondo. Sin embargo, quiero hacer referencia al fondo.

Resulta positivo y debemos celebrar que se dé un tratamiento más en detalle al delito de que trata el proyecto y se cambie el concepto de prostitución infantil por el de explotación sexual, porque, evidentemente, en ningún contexto puede llegar a haber consentimiento. Sin embargo, tenemos un problema no menor que me he preocupado de hacer saber al ministerio en la comisión. Es importante que todos tengamos conciencia del mismo.

Aquí se ha cometido una falta, un error bastante grueso al modificar la norma, particularmente el artículo 366 quater del Código Penal. ¿En qué sentido? Básicamente se ha establecido -no se explicita, pero es lo que se deja en evidencia con las penas que se establecen- que sería menos grave el hecho de que un adulto realice prácticas sexuales frente a un menor a que el menor realice prácticas sexuales frente al adulto. Creo que es importante que haya un consenso transversal en toda la clase política en cuanto a que ambas conductas son aberrantes. No podemos enviar señales contradictorias a la ciudadanía. No puede ser que en un caso se establezca un rango de pena que puede ir de presidio menor en su grado medio a máximo y en el otro se establezca que, sí o sí, la pena será siempre de presidio menor en su grado máximo. ¿Por qué se establece esta diferencia? Es una diferencia que no tiene sentido, que no tiene lógica y que es completamente contradictoria. Es más, les garantizo que la gran

Discusión en Sala

mayoría de los chilenos piensa lo mismo que estoy transmitiendo, esto es, que son conductas igualmente aberrantes.

Cualquier tipo de trato sexual entre adultos y entre menores de edad constituye una conducta completamente aberrante que no puede ser justificada bajo ningún contexto. Repito: aquí se haya hecho un cambio que hoy no vamos a modificar, porque ya está aprobado y no es materia de esta votación; sin embargo, es importante que entendamos el error que se ha cometido, la falta que se ha cometido en una cuestión tan importante como la persecución de los delitos sexuales, especialmente aquellos que se cometen contra menores.

Es igualmente grave que un adulto realice conductas sexuales frente a un menor a que un adulto fuerce a un menor de edad a realizar conductas sexuales frente a él o ante cualquier otra persona. En eso no puede haber doble estándar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

No hay más diputados inscritos para hacer uso de la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las observaciones del Presidente de la República en los siguientes términos:

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Corresponde votar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

Corresponde votar la observación número 1) de su excelencia el Presidente de la República, a cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señora Presidenta, esta observación de su excelencia el Presidente de la República es para reemplazar el número 11 por el siguiente:

“11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 368 ter: a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázanse las expresiones “o 374 bis” por la expresión “, 367 quáter o 367 septies”.”.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 130 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cifuentes Lillo , Ricardo Matheson Villán , Christian Rathgeb Schifferli , Jorge Aedo Jeldres , Eric Concha Smith , Sara Medina Vásquez , Karen Riquelme Aliaga , Marcela Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Mellado Pino , Cosme Rivas Sánchez , Gaspar Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Romero Leiva , Agustín Araya Guerrero , Jaime De Rementería Venegas , Tomás

Discusión en Sala

Meza Pereira , José Carlos Romero Sáez , Leonidas Araya Lerdo de Tejada, Cristián Donoso Castro , Felipe Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Talguia , Natalia Arce Castro , Mónica Durán Espinoza , Jorge Mix Jiménez , Claudia Sáez Quiroz , Jaime Arroyo Muñoz , Roberto Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Saffirio Espinoza , Jorge Astudillo Peiretti , Danisa Gazmuri Vieira, Ana María Morales Maldonado , Carla Sagardia Cabezas , Clara Barchiesi Chávez , Chiara Giordano Salazar , Andrés Moreira Barros , Cristhian Sánchez Ossa , Luis Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Moreno Bascur , Benjamín Santana Castillo , Juan Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Becker Alvear, Miguel Ángel González Villarroel , Mauro Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz, Frank Bello Campos, María Francisca Guzmán Zepeda , Jorge Nuyado Ancapichún , Emilia Schalper Sepúlveda , Diego Beltrán Silva , Juan Carlos Hertz Cádiz , Carmen Ñanco Vásquez , Ericka Schneider Videla , Emilia Benavente Vergara , Gustavo Hirsch Goldschmidt , Tomás Ojeda Rebolledo , Mauricio Schubert Rubio , Stephan Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera de la Fuente, Erika Serrano Salazar , Daniela Bernaldes Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Irarrázaval Rossel , Juan Ossandón Irarrázabal , Ximena Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Jiles Moreno , Pamela Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Teao Drago , Hotuiti Bravo Castro, Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Palma Pérez , Hernán Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Cartes , Marlene Trisotti Martínez , Renzo Bulnes Núñez , Mercedes Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Pérez Olea , Joanna Undurraga Vicuña , Alberto Calisto Águila , Miguel Ángel Labbé Martínez , Cristian Pérez Salinas , Catalina Urruticoechea Ríos , Cristóbal Camaño Cárdenas , Felipe Leal Bizama , Henry Pino Fuentes , Víctor Alejandro Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Venegas Salazar , Nelson Carter Fernández , Álvaro Lilayu Vivanco , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Videla Castillo, Sebastián Castillo Rojas, Nathalie Longton Herrera , Andrés Pulgar Castillo , Francisco Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Castro Bascuñán, José Miguel Malla Valenzuela , Luis Ramírez Díez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Celis Montt , Andrés Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Martínez Ramírez , Cristóbal Raphael Mora , Marcia Yeomans Araya , Gael Cid Versalovic , Sofía Marzán Pinto, Carolina

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el resto de las observaciones de su excelencia el Presidente de la República con la misma votación. ¿Habría acuerdo?

Aprobadas.

Despachado el proyecto al Senado.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4.6. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Observaciones . Fecha 24 de octubre, 2022. Oficio en Sesión 71. Legislatura 370.

VALPARAÍSO, 24 de octubre de 2022

Oficio N° 17.808

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra informar a V.E. que mediante oficio N° 17.737, de 13 de septiembre de 2022, la Cámara de Diputados comunicó a S.E. el Presidente de la República el texto del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín N° 14.440-07.

En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 73 de la Carta Fundamental, S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 160-370, de 12 de octubre del corriente, formuló observaciones al mencionado proyecto de ley.

Al respecto, comunico a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ha aprobado la totalidad de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República.

Hago presente a Vuestra Excelencia que la observación signada con el número 10), en lo que respecta al nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, fue aprobada con el voto favorable de 130 diputadas y diputados, de un total de 155 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

RAÚL SOTO MARDONES

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio de la Corte Suprema

4.7. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 28 de octubre, 2022. Oficio en Sesión 92. Legislatura 370.

OFICIO N° 221-2022

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.”

Antecedente: Boletín N° 14.440-07.

Santiago, 28 de octubre de 2022.

Por Oficio N° 17.788, de fecha 17 de octubre del año en curso, el Presidente de la Cámara de Diputados y su Secretario General, Raúl Soto Mardones y Miguel Landeros Perkic, remitieron a la Corte Suprema las observaciones que realizó S.E. Presidente de la República ejerciendo su potestad de veto (artículo 73 de la Constitución Política de la República), en relación al proyecto de ley que “introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes”, de conformidad con lo dispuesto el artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, correspondiente al boletín N° 14.440-07.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el 28 de octubre del año en curso, presidida por su subrogante señor Haroldo Brito, e integrada por los ministros señores Silva G. y Blanco, señora Muñoz S., señores Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señoras Repetto y Ravanales, señor Carroza y señora Letelier, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

SEÑOR RAÚL SOTO MARDONES.

VALPARAÍSO

“Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° 17.788, de fecha 17 de octubre del año en curso, el Presidente de la Cámara de Diputados y su Secretario General, Raúl Soto Mardones y Miguel Landeros Perkic, remitieron a la Corte Suprema las observaciones que realizó S.E. Presidente de la República ejerciendo su potestad de veto (artículo 73 de la Constitución Política de la República), en relación al proyecto de ley que “introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes”, con el objeto que se pronuncie especialmente sobre lo dispuesto en el nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales.

Lo anterior, a fin de recabar la opinión de la Corte Suprema sobre el veto que formuló el presidente en contra de esta iniciativa, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Constitución Política de la República, y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que el proyecto contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

Segundo: Que en el mensaje se señala que este proyecto busca recoger las sugerencias que los diversos actores institucionales y de la sociedad civil, han venido desarrollando durante los últimos 20 años en esta materia, atendido que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es considerada una de las más graves vulneraciones a los derechos humanos.

Lo anterior a fin implementar una de las cinco líneas de acción que comprende el Tercer Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), que dice relación con el robustecimiento de la “sanción de las personas explotadoras y protección de las víctimas”.

Oficio de la Corte Suprema

Se señala además que la legislación nacional no contempla una tipificación para este tipo de explotación sexual, particularmente porque los tipos penales y las referencias a la prostitución, favorecen la percepción de que las víctimas de estos delitos presentan algún grado de “voluntariedad” para “participar” de esta actividad, sin considerarse la asimetría de poder que subyace entre una víctima y el o los victimarios, percepción fuertemente arraigada en nuestra cultura.

Tercero: Que el proyecto propone una serie de modificaciones al Código Penal y otros cuerpos legales, que tienen como objetivo ajustar el régimen aplicable a lo que se considera en la actualidad “prostitución infantil” y “pornografía infantil”, a la matriz interpretativa de “explotación infantil” que se considera conceptualmente más adecuada a la realidad que se pretende combatir con los respectivos códigos penales. Esto, a través de modificaciones al Código Penal (mediante una reformulación general del párrafo 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal y un ajuste en las reglas que rigen su penalidad y prescriptibilidad) y a la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad.

Bajo estas condiciones, las observaciones que el Presidente de la República incorporó al citado proyecto, en el ejercicio de la potestad que prevé el artículo 73 de la Constitución Política de la República, se fundamentan, en los términos del oficio respectivo, en la necesidad de realizar una completa “actualización de referencias o remisiones” de las distintas normas que se verían afectadas por la promulgación de esta iniciativa, y en la necesidad de incorporar de modo completo al nuevo artículo 367 septies en el “estatuto general de delitos sexuales contra NNAs”.

De este modo, el veto ejercido por el Presidente, comparte el sentido y el alcance del proyecto aprobado por el Congreso, y sólo pretende profundizar sus efectos y facilitar su inteligencia, través de mejoras de técnica legislativa que se espera permitan una mejor consistencia sistemática en la regulación de los delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes, en relación a los cuerpos normativos que rigen la materia.

Cuarto: Que, al respecto, cabe tener en cuenta que el oficio remitido por el Congreso al máximo tribunal, sólo requiere la opinión del máximo tribunal en relación a lo dispuesto en el nuevo artículo 12 propuesto, y que propone modificaciones al numeral 10 del artículo 6° del Código orgánico de Tribunales.

“artículo 12.- Introdúcense las siguiente modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

a) Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N°1,” por las expresiones “367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”;

b) Reemplazase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Quinto: Que la disposición consultada propone una nueva modificación al numeral 10 del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales que establece la lista de casos en que nuestro país preserva su jurisdicción en relación a determinados crímenes y simples delitos que han sido perpetrados fuera del territorio nacional, actualizando la lista de casos en que se acepta la extraterritorialidad de la jurisdicción penal chilena.

Estos casos, que se justificarían en la homologación sistemática de la regulación vigente, con la intención legislativa que trasunta el proyecto inicialmente aprobado por la Cámara, se manifestaría:

a) En la eliminación de las referencias a los artículos 366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1 del Código penal que actualmente contempla la primera parte de dicha disposición, remplazándolas por las de los artículos 367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies del mismo cuerpo normativo y;

b) En la modificación de la referencia que realiza la segunda parte de dicha disposición (que rige la situación de la comercialización, importación, exportación, distribución, difusión, exhibición y, adquisición y almacenamiento malicioso de material pornográfico, en que participen chilenos menores de dieciocho años) desde el artículo 374 bis del Código Penal, por la del artículo 367 quáter del mismo cuerpo normativo.

En lo que se refiere a esta modificación, cabe señalar que ella parece razonable en términos generales, en la medida que se condice con el espíritu general de la propuesta, y la nueva fisonomía del propuesto nuevo párrafo 6 bis del Título VII del Libro II del Código Penal.

Oficio de la Corte Suprema

Por lo menos, este parece ser el caso en relación a la supresión de la referencia al artículo 366 quinquies y 374 bis del Código Penal -cuyos rangos punitivo quedan absorbidos por el nuevo 367 quáter- y la incorporación de la referencia a los artículos 367 quáter y 367 septies del mismo cuerpo normativo, que establecen el nuevo sistema punitivo de estos delitos.

Sin embargo, cabe señalar que la preservación de la referencia al artículo 367 bis N° 1 del Código Penal que propone el veto ejecutivo resulta inadecuada, toda vez que dicha disposición se encuentra actualmente derogada por la Ley N° 20.507(artículo Primero N° 2, D.O. 08-04-2011), que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución, habiendo quedado absorbido en su rango típico por el actual artículo 411 ter del Código Penal.

Sexto: Que, por último, en lo que se refiere a las restantes modificaciones planteadas por el ejecutivo, cabe tener en cuenta que tal como indica su fundamentación, parecen limitarse a dirimir aspectos técnicos del proyecto, sin cuestionar sus fundamentos o sentido, razón por la que no parecen ameritar mayores observaciones, salvo en lo que se refiere a dos errores formales que pueden apreciarse en los artículos 1 y 13 de la propuesta y que respectivamente dicen relación con:

a)La modificación propuesta al artículo 370 bis del Código Penal, en dónde se plantea la modificación de una frase que no se encuentra en la norma vigente, que no emplea la expresión “precedentes” que sugiere el documento, sino la expresión “anteriores” (así consta desde la introducción de esta disposición a través de la ley N° 19.617).

b)La modificación propuesta al artículo 30 de la Ley N° 19.846, en donde el veto ejecutivo propone el reemplazo de las palabras “los artículos 366 quinquies, 374 bis y 374 ter”, debiendo haberlo hecho solo respecto de “366 quinquies, 374 bis y 374 ter”.

Séptimo: Que en síntesis el proyecto en estudio propone mejorar la regulación sustantiva y procesal que rige los delitos y los mecanismos de protección de los niños, niñas y adolescentes en Chile, especialmente con miras a la implementación del Tercer Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, como se indicara ut supra.

Por otro lado, la disposición consultada, que actualiza el listado de casos en que se acepta la extraterritorialidad de la jurisdicción penal chilena, parece razonable y pertinente, salvo en lo que dice relación con la preservación de la referencia al artículo 367 bis N° 1 del Código Penal, que como se señaló se encuentra derogado desde el año 2011 por la publicación de la Ley N° 20.507.

En cuanto a los impactos que se puedan producir en el poder judicial, su dimensión es difícil de cuantificar en relación al aumento de números de ingresos, en lo económico es posible que se puedan necesitar nuevos desarrollos informáticos, así como un mayor número de salas “Gesell”.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Ofíciase.

PL N° 31-2022”

Saluda atentamente a V.S.



Informe de Comisión de Constitución

4.8. Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 14 de noviembre, 2022. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 75. Legislatura 370.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.

BOLETÍN N° 14.440-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros respecto de las Observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, y para cuyo despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de “suma”.

Cabe hacer presente que tratándose de Observaciones del Ejecutivo, ellas fueron discutidas en general y en particular a al vez, según lo establecen los artículos 127 y 188, N° 1, del Reglamento de la Corporación.

Asimismo, se deja constancia que la Honorable Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (130 votos) la totalidad de las Observaciones formuladas a este proyecto de ley, según consta en el Oficio N° 17.808, de fecha 24 de octubre de 2022, de esa Corporación.

- - -

A las sesiones que la Comisión dedicó al análisis de este asunto concurrieron, en forma presencial o telemática, los siguientes personeros:

- El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, acompañado por la jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; los asesores legislativos señoras Flora Ben-Azul, Alejandra Lazo y Camila Moya y señor Rafael Ferrada, y el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton.
- La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos, acompañada por la asesora señora Francisca Oyarzún.
- El Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señor Antonio Bascuñán.
- El analista sectorial de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.
- Los asesores parlamentarios señoras Paola Bobadilla, Alejandra Fischer, Karelyn Lüttecke y Carolina Navarrete, y señores Mauricio Burgos, Miguel Ángel Díaz, Roberto Godoy, Felipe Hübner, Benjamín Lagos, Pedro Lezaeta, Héctor Mery e Ignacio Ortega.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, contenido en la observación número 10), es de rango orgánico constitucional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, por lo que, conforme a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, del mismo Texto, para su aprobación requiere de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

Cabe consignar que la Excm. Corte Suprema emitió su opinión acerca de dicha disposición, mediante Oficio N° 221-2022, de 28 de octubre de 2022.

- - -

Informe de Comisión de Constitución

Previo al análisis de las Observaciones formuladas, tuvo lugar en el seno de la Comisión una reflexión acerca de su sentido y alcance.

Al respecto, el Honorable Senador señor Walker destacó que se trata de modificaciones simples, que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución y en la Sala de la Cámara de Diputados.

Refiriéndose al veto aditivo del Ejecutivo, el Subsecretario de Justicia señaló que su propósito es hacerse cargo de un conjunto de aspectos formales que deben ser afinados como consecuencia de la creación del nuevo tipo penal que establece la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Tales precisiones fueron advertidas cuando se preparaba la implementación de la ley por el Ministerio Público, en conjunto con las divisiones jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En ese marco, añadió, se trata de adecuaciones de referencia legislativa que se dan principalmente debido a que los delitos sexuales en los últimos cinco años han sido objeto de diversas modificaciones como consecuencia de la entrada en vigencia de distintas leyes, entre ellas, la ley N° 21.057, sobre entrevistas grabadas en video, la ley N° 21.160, que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la ley N° 21.153, que tipificó el acoso sexual en espacios públicos, la ley N° 21.483, que reforzó la protección de las víctimas de delitos cuando sean menores de edad, y la Ley Antonia (actualmente en revisión del Tribunal Constitucional). Además, si bien durante la tramitación del proyecto de ley sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, se hizo alusión a otras disposiciones legales relevantes, faltó precisar algunas normas vinculadas a la materia. Las Observaciones del Ejecutivo, entonces, admiten la siguiente agrupación:

- a) Las relativas al Párrafo 6 bis que se incorpora al Título VII del Libro II del Código Penal, con el objeto de que las referencias permitan una aplicación efectiva de la disposición para delitos contenida en el mismo Código, en particular en lo relativo al delito de violación.
- b) Las referidas al artículo 367 quáter, que pasó a comprender los delitos asociados a pornografía de niños, niñas y adolescentes, y que hoy se encuentran en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis (que se eliminan del Código).
- c) Las que atañen al nuevo delito de transmisión de material pornográfico, que necesita ser incorporado como referencia legislativa en el artículo 367 septies.

La señora Subsecretaria de la SEGPRES, luego de recordar que la llamada Ley Antonia se encuentra en control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sostuvo que se requerirá de un nuevo proyecto de ley para corregir ciertas inconsistencias que se han podido identificar entre su articulado y el del proyecto sobre explotación sexual infantil.

Por último, acotó, hay una Observación para adecuar el problema que se produce con el nuevo Título 6 bis que deja sin aplicación las normas comunes del Título VII sobre agravantes y penas accesorias para los delitos de violación de menores, lo cual no era parte del espíritu de la iniciativa.

Consultado por el Honorable Senador señor Araya acerca de la Observación que propone suprimir el artículo 369 bis, el Subsecretario de Justicia comentó que tal supresión se relaciona con una norma que se encontraba vigente al tiempo en que se aprobó la Reforma Procesal Penal, y que regulaba la forma de valorar la prueba en el tiempo intermedio. Con arreglo al artículo 369 bis, en los procesos por los delitos a que se refieren los “dos párrafos anteriores”, el juez apreciará la prueba conforme con las reglas de la sana crítica. Como esta disposición se modificó por la Reforma Procesal Penal, el principal problema que genera mantenerla en el Código Penal es que pueda subsistir al incorporarse en el proyecto. Para evitar aquella confusión y debido a que se encuentra vigente su regulación en el Código Procesal Penal, se propone su eliminación.

La señora Subsecretaria de la SEGPRES puntualizó que, en circunstancias que las normas de ponderación de la prueba se contienen en el Código Procesal Penal, el artículo en comentario del Código Penal quedó rezagado. Dado que la materia se encuentra regulada mediante una norma específica del Código Procesal Penal, la subsistencia del artículo que se propone suprimir podría generar conflictos de interpretación. Así, conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado,

Informe de Comisión de Constitución

indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

En estricto rigor, prosiguió, no habría contradicción en lo tocante a la forma de valoración de la prueba que rige actualmente. Lo que se cuestiona es la subsistencia en el Código Penal de una norma sobre valoración de la prueba junto a la que regula la misma materia en el Código Procesal Penal (que establece las reglas generales para cualquier delito). Es inconveniente mantener una regulación específica para un delito, cuando el asunto se encuentra regulado en general por el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Ante la pregunta del Honorable Senador señor Walker sobre si lo que se busca es sólo concordar textos, la señora Subsecretaria de la SEGPRES respondió afirmativamente, puesto que en nada se modifica el régimen vigente de valoración de la prueba que corresponde al juez.

El Honorable Senador señor Araya manifestó su inquietud respecto de esta propuesta: el artículo 369 bis fue corregido el año 1999, esto es, en el mismo momento en que se tramitaba el Código Procesal Penal. Si sucesivas reformas posteriores nunca han alertado acerca de alguna falta de concordancia, su mantención podría responder a alguna razón práctica.

El señor Subsecretario de Justicia arguyó que el artículo 369 bis se aplicó únicamente hasta el año 2005, pues fue concebido para el tránsito hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que, en circunstancias que la norma en cuestión se publicó un poco antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, como la implementación de la reforma procesal penal fue gradual, la norma se aplicó donde continuaba rigiendo el proceso penal antiguo (entre los años 1999 y 2005, cuando entró en régimen pleno).

El Honorable Senador señor Araya destacó que, aunque no se visualizan contradicciones normativas entre ambos artículos, deben evitarse interpretaciones judiciales que consideren que el artículo 369 bis es más amplio o laxo que el Código Procesal Penal en materia de valoración de la prueba.

Refiriéndose a la respuesta de la Excma. Corte Suprema y del Ministerio Público a la consulta que se les formulara acerca de este asunto, el señor Subsecretario de Justicia destacó, en lo tocante a la eliminación del artículo 369 bis del Código Penal (que viene proponiendo el Ejecutivo), que mientras ese Alto Tribunal no se pronunció a su respecto, el Ministerio Público manifestó su opinión favorable a dicha supresión, puntualizando que no generaría efectos en materia de persecución penal. En todo caso, añadió, dicha supresión sería armónica con la regulación que se consulta para el Código Procesal Penal. No obstante, el personero hizo notar que el oficio remitido por la Excma. Corte Suprema sólo se pronuncia, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, acerca de la incorporación de un artículo 12, nuevo, mediante el cual se modifica el numeral 10 del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales. Por su parte, acotó, el Ministerio Público aludió también a otros aspectos normativos.

El señor Subsecretario del ramo reiteró que, en general, las Observaciones en análisis persiguen adecuar referencias legislativas y aspectos formales del proyecto, e incluir una mención especial al delito de violación dentro del Párrafo VI del Código Penal. En este sentido, prosiguió, aunque algunos de los comentarios de la Corte Suprema y del Ministerio Público son atendibles, se trata (como en el caso del artículo 367 bis, N° 1, del Código Penal) de cuestiones sustanciales que exceden las pretensiones y el marco de discusión del veto del Ejecutivo. De allí que la voluntad del Gobierno sea recoger tales preocupaciones en una futura ley adecuatoria, que ya se está elaborando por parte de la SEGPRES y que prontamente será sometido a tramitación legislativa.

El Honorable Senador señor Galilea subrayó que la duda planteada a la Excma. Corte Suprema y al Ministerio Público perseguía establecer si la supresión del artículo 369 bis del Código Penal era susceptible de producir algún efecto en la apreciación de la prueba. Al respecto, dijo, en circunstancias que el Máximo Tribunal no se pronunció, el Ministerio Público estimó que en nada se altera el mecanismo de valoración probatoria, porque los principios generales en la materia se encuentran regulados en el Código Procesal Penal.

El Honorable Senador señor Walker, luego de recordar que cada Observación debe ser aprobada o rechazada en su

Informe de Comisión de Constitución

totalidad y que cualquier perfeccionamiento normativo mayor requiere de un nuevo proyecto de ley, subrayó que el veto persigue subsanar aspectos formales y de referencia legislativa e incluir expresamente al delito de violación dentro del articulado.

El Profesor de Derecho Penal señor Bascuñán, explicó que el artículo 369 bis del Código Penal constituye una regla anterior a la reforma procesal penal, y que su función fue dialogar con el Código Procesal Penal estableciendo en el tiempo intermedio una norma de valoración racional de la prueba, al margen de apreciaciones legales o prueba tasada. Por ello, y como en la práctica el artículo 369 bis cayó en obsolescencia, requiere ser interpretado con arreglo a las normas de apreciación de la prueba introducidas por dicho Código. Los delitos sexuales no requieren una norma especial distinta a la que se contiene en aquel cuerpo normativo.

Es dable señalar que, para mejor resolver, la Comisión ofició al Ministerio Público a fin de conocer su parecer acerca de las Observaciones del Ejecutivo. El órgano persecutor emitió su opinión por Oficio N° 976/2022, de 2 de noviembre de 2022, que se tuvo en cuenta con ocasión del debate habido.

- - -

Se formularon por S.E. el Presidente de la República, diez Observaciones al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. A continuación, se efectúa una relación de estas observaciones y de las disposiciones en que recaen.

Observación N° 1

Recae en el numeral 11 del artículo 1, que elimina, en el inciso primero del artículo 368 ter del Código Penal, la expresión “366 quinquies,” y sustituye el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

La Observación propone reemplazar este numeral 11, por el siguiente:

“11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 368 ter:

- a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.
- b) Reemplázanse las expresiones “o 374 bis” por la expresión “, 367 quáter o 367 septies”.

Observación N° 2

Esta Observación propone incorporar al artículo 1 el siguiente numeral 13, nuevo:

“13. Suprímese el artículo 369 bis.”

El señor Presidente de la Comisión calificó esta Observación como aditiva.

Observación N° 3

Incide en el numeral 13 del artículo 1, que elimina, en el inciso primero del artículo 369 ter del Código Penal, la expresión “366 quinquies,” y sustituye el guarismo “374 bis” por “367 quáter”.

La Observación propone reemplazar el numeral 13, por el siguiente:

“14. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 ter:

- a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.
- b) Reemplázanse las expresiones “374 bis, inciso primero y 374 ter” por los vocablos “367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies”.

Observación N° 4

Recae en el numeral 14) del artículo 1, que sustituye, en el artículo 369 quinquies del Código Penal, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

Informe de Comisión de Constitución

La Observación consulta reemplazar el numeral 14, por el siguiente:

“15. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 369 quinquies:

- a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.
- b) Incorpórase, luego de la expresión “367 ter”, la expresión “, 367 quáter y 367 septies”.

Observación N° 5

Propone incorporar un numeral 16, nuevo, del tenor que sigue:

“16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

El señor Presidente de la Comisión calificó esta Observación como aditiva.

Observación N° 6

Incide en el numeral 16) del artículo 1, que reemplaza, en los incisos segundo y tercero del artículo 372 del Código Penal, el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

La Observación propone sustituir el actual numeral 16, por el siguiente:

“18. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 372:

- a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”;
- b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:
 - i. Elimínase la expresión “366 quinquies,”.
 - ii. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter, 367 septies”.

Observación N° 7

Consulta intercalar en el artículo 1 el siguiente numeral 19, nuevo:

“19) Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

El señor Presidente de la Comisión calificó esta Observación como aditiva.

Observación N° 8

Recae en el artículo 2, que modifica el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, en el siguiente sentido:

- 1. Sustituye la expresión: “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.
- 2. Suprime la expresión “374 bis;”.

La Observación consulta reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

- 1. Modifícase, el inciso primero del artículo 1°, en el siguiente sentido:
 - a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis

Informe de Comisión de Constitución

del Título VII del Libro Segundo.”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

2. Modifícase, el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis al Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo”, por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

Observación N° 9

Recae en el artículo 3, que reemplaza en el artículo 2° de la ley N° 21.160 el guarismo “366 quinquies” por “367 quáter”.

La Observación propone reemplazarlo, por el que se señala:

“Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies;”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “367 ter” la frase “, 367 quáter, 367 septies”.

Observación N° 10

Propone intercalar los siguientes artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, nuevos:

“Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

a) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 191 bis, la frase “párrafos 5 y 6” por la expresión “párrafos 5, 6 y 6 bis”.

b) Reemplázanse, en el inciso cuarto del artículo 469, las expresiones “366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter” por las expresiones “367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies”.

Artículo 8.- Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Agrégase entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue la expresión “, 367 quáter”.

c) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 septies”.

Artículo 9.- Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

a) Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter, 367 septies”.

Artículo 10.- Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, entre la expresión “6°” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

Artículo 11.- Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

Informe de Comisión de Constitución

a) Intercálase, entre la expresión “6°” y conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

b) Elimínase la expresión “, 374 bis”.

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

a) Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 bis N° 1, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”;

b) Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Artículo 13.- Reemplázanse, en el artículo 30 de la ley N° 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, las expresiones “en los artículos 366 quinquies, 374 bis y 374 ter” por las expresiones “367 quáter y 367 quinquies”.”.

El señor Presidente de la Comisión calificó esta Observación como aditiva.

- - -

Concluido el análisis de las Observaciones, el señor Presidente de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación la totalidad de ellas.

- Sometidas a votación la totalidad de las Observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley de que se trata, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker.

- - -

En mérito de los acuerdos consignados precedentemente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene el honor de proponeros respecto de las Observaciones en informe, lo siguiente:

- Aprobar la Observación número 1). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 2). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 3). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 4). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 5). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 6). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 7). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 8). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 9). Unanimidad 5x0.
- Aprobar la Observación número 10). Unanimidad 5x0.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 26 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 14 de noviembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Álvaro Elizalde Soto (Alfonso De Urresti Longton) y Rodrigo Galilea Vial.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2022.

Informe de Comisión de Constitución

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

Discusión en Sala

4.9. Discusión en Sala

Fecha 16 de noviembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 76. Legislatura 370. Discusión Observaciones Presidente de la República. Se aprueba.

INCORPORACIÓN DE NUEVO PÁRRAFO EN CÓDIGO PENAL RELATIVO A EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. VETO

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental, al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.440-07, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.440-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Es dable recordar que el objetivo de este proyecto de ley es propender a la protección penal de las víctimas de explotación sexual comercial cuando afecte a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se introduce un nuevo párrafo al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal , relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas o adolescentes.

Cabe consignar que la Cámara de Diputados, que es Cámara de origen, aprobó por unanimidad la totalidad de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al texto despachado por el Congreso Nacional.

Dichas observaciones versan sobre lo siguiente:

-La observación N° 1 propone sustituir el numeral 11 del artículo 1 del proyecto, que introduce modificaciones en el artículo 368 ter del Código Penal.

-La observación N° 2 propone adicionar un numeral 13, nuevo, que suprime el artículo 369 bis del Código Penal, relativo a la apreciación de la prueba por parte del juez.

-La observación N° 3 propone sustituir el numeral 13 del artículo 1, que pasaría a ser 14, y que introduce modificaciones al artículo 369 ter.

-La observación N° 4 propone sustituir el numeral 14 del artículo 1, que pasaría a ser 15, y que introduce modificaciones en el artículo 369 quinqués.

-La observación N° 5 propone adicionar un numeral 16, nuevo, que reemplaza una referencia en el inciso primero del artículo 370 bis.

-La observación N° 6 propone reemplazar el numeral 16 del artículo 1, que pasaría a ser 18, y que introduce modificaciones en el artículo 372 del Código Penal.

-La observación N° 7 propone adicionar un numeral 19, nuevo, que reemplaza la referencia en el artículo 372 ter.

-La observación N° 8 propone sustituir el artículo 2, que modifica el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de

Discusión en Sala

delitos sexuales.

-La observación N° 9 propone sustituir el artículo 3, que modifica el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

-La observación N° 10 propone adicionar los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, nuevos, para modificar, respectivamente, los siguientes textos legales: el Código Procesal Penal; la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta; la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transportes Remunerados de Escolares; el Código Orgánico de Tribunales, y la ley N° 19.846, sobre calificación de la producción cinematográfica.

Además, es dable consignar que el Presidente de la Comisión de Constitución calificó las observaciones números 2, 5, 7 y 10 como aditivas.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado deja constancia de que, sometidas a votación la totalidad de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker, por lo que propone a la Sala aprobar las diez observaciones formuladas por el Primer Mandatario.

Asimismo, consigna que el artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, propuesto por la observación N° 10, tiene rango de ley orgánica constitucional, por lo que requiere 27 votos favorables para su aprobación.

Cabe recordar que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 127 y 188, números 1° y 2°, del Reglamento del Senado, las observaciones del Ejecutivo se discuten en general y en particular a la vez, se votan separadamente y no procede dividir la votación.

El texto de las observaciones presentadas se transcribe en las páginas 6 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Quiero recordar que hay normas de quorum especial consideradas en las observaciones del Presidente de la República. Además, son varias votaciones.

Vamos a recabar la unanimidad para votar todo conjuntamente.

¿Habría acuerdo para una sola votación?

(Rumores).

El Senador Chahuán no da el acuerdo; por tanto, vamos a tener que votar una a una.

El señor MOREIRA .-

¿Cuántos votos se necesitan?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se requieren 27 votos.

Les recuerdo que, si se cae, el texto va a quedar incoherente.

No olvidemos que este veto fue aprobado unánimemente.

Discusión en Sala

Senador Chahuán, yo sé que usted está enojado conmigo, pero no haga responsables de que se caiga una votación a las niñas, niños y adolescentes que se verán beneficiados con esta legislación.

Entonces, voy a recabar de nuevo la unanimidad.

Si tiene un problema conmigo, lo resolvemos de otra manera. Pero no legislemos mal; no repitamos malas prácticas que se dan en otros órganos; legislemos bien.

(Rumores).

Voy a recabar de nuevo la unanimidad.

¿Habría acuerdo para que sea una sola votación?

El señor CHAHUÁN .-

Sí, Presidente , doy la unanimidad.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Muy bien, haremos una sola votación.

Muchas gracias, Senador Chahuán , por su grandeza y su gentileza.

Entonces, una sola votación.

Senador Walker, tiene la palabra.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar respecto de las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, iniciado en mensaje del ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique , para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia calificada de "suma".

Es dable mencionar que la Honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó la totalidad de las observaciones del Presidente de la República por unanimidad (130 votos).

Cabe hacer presente que la observación signada con el N° 10, en lo que respecta al nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, incide en una norma orgánica constitucional, de conformidad con el inciso primero del artículo 77 y en concordancia con el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental.

El propósito de estas observaciones es hacerse cargo de un conjunto de aspectos formales que deben ser afinados como consecuencia de la creación del nuevo tipo penal que establece la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes.

En este marco, se trata de adecuaciones de referencia legislativa que se dan principalmente debido a que los delitos sexuales en los últimos cinco años han sido objeto de diversas modificaciones como consecuencia de la entrada en vigencia de distintas normativas, entre ellas la ley N° 21.057, sobre entrevistas videograbadas; la ley N° 21.160, que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; la ley N° 21.153, que tipificó el acoso sexual en espacios públicos; la ley N° 21.483, que reforzó la protección de las víctimas de delitos cuando sean menores de edad, y la Ley Antonia, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.

Además, si bien durante la tramitación del proyecto de ley sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y

Discusión en Sala

adolescentes se hizo alusión a otras disposiciones legales relevantes, faltó precisar algunas normas vinculadas con la materia.

Las observaciones del Ejecutivo , entonces, admiten la siguiente agrupación:

a) Las relativas al párrafo 6 bis que se incorpora al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal , con el objeto de que las referencias permitan una aplicación efectiva de la disposición para delitos contenida en el mismo Código, en particular en lo relativo al delito de violación.

b) Las referidas al artículo 367 quáter, que pasó a comprender los delitos asociados a pornografía de niños, niñas y adolescentes, y que hoy se encuentran en el artículo 366 quinquies y en el artículo 374 bis, que se eliminan del Código.

c) Las que atañen al nuevo delito de transmisión de material pornográfico, que necesita ser incorporado como referencia legislativa en el artículo 367 septies.

En lo tocante a la eliminación del artículo 369 bis del Código Penal (que el Ejecutivo propone en la observación N° 2), el Ministerio Público manifestó su opinión favorable a dicha supresión, puntualizando que no generaría efectos en materia de persecución penal. En todo caso, dicha supresión sería armónica con la regulación que se consulta para el Código Procesal Penal.

En el mismo sentido, el profesor de Derecho Penal señor Antonio Bascuñán explicó que el artículo 369 bis del Código Penal constituye una regla anterior a la reforma procesal penal, y que su función fue dialogar con el Código Procesal Penal, estableciéndose en el tiempo intermedio una norma de valoración racional de la prueba, al margen de apreciaciones legales o prueba tasada. Por ello, y como en la práctica el artículo 369 bis cayó en obsolescencia, requiere ser interpretado con arreglo a las normas de apreciación de la prueba introducidas por dicho Código. Los delitos sexuales no requieren una norma especial distinta de la que se contiene en aquel cuerpo normativo.

Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

Le ruego desde ya, si usted y la Sala lo tienen a bien, abrir la votación.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Bien.

Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación, teniendo presente que, dentro de las diez observaciones, la correspondiente al artículo 12, como ha señalado el Presidente de la Comisión , es de quorum especial.

¿Habría acuerdo?

--Así se acuerda.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Se abre la votación de todas las observaciones, como se acordó previamente.

(Durante la votación) .

Senadora Aravena, tiene la palabra.

La señora ARAVENA.-

Presidenta, trataré de ser bien breve.

Solo quiero señalar que me parece un muy buen proyecto y que el trabajo de la Comisión fue muy bueno. En ese contexto, cambiar el concepto de prostitución infantil por el de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es quizá lo más valioso.

También deseo hacer mención, específicamente, a una indicación que nosotros presentamos, finalmente no

Discusión en Sala

aprobada, que aborda un tema del cual es importante hacernos cargo. Dice: "quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años" debiera ser sancionado "con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales".

La semana pasada, en Estados Unidos, una de las páginas pornográficas más grandes del mundo fue demandada precisamente por la exhibición en internet de la violación de un niño de apenas doce años de edad.

Por otro lado, el Ministerio Público ha señalado, como consta en uno de los informes referidos al proyecto, que "El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados garantizar que las personas, naturales o jurídicas, puedan ser consideradas responsables penalmente por haber cometido o intentado cometer delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, o por haber sido cómplices o haber participado en ellos, debiendo establecer por ley la responsabilidad de las empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones".

Por último, está el tema del acceso por parte de los menores de edad a material pornográfico como forma de abuso.

Otra materia pendiente que no fue abordada en este proyecto es el libre acceso que tienen hoy día menores de edad a material que es inapropiado para ellos. El libre acceso a material pornográfico violento y explícito, por ejemplo, está generando un efecto devastador en el desarrollo de las nuevas generaciones.

Los esfuerzos por regular el contenido y restringir el acceso a pornografía a menores de edad no han estado a la par con la rapidez con que ha evolucionado la tecnología. Eso lo plantea la Unicef.

Por ello, junto con otros Senadores, hace pocos días presentamos un proyecto para establecer un sistema de verificación de edad a sitios y plataformas web que exhiban contenido no apropiado para menores de edad.

Gracias, Presidente .

Obviamente, voy a votar a favor el veto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Les ruego a los señores Senadores que emitan su voto.

Cabe recordar que esta votación contempla una observación que requiere quorum especial.

No hay más inscritos, así que haremos sonar los timbres por algunos minutos para que todos los señores Senadores vengan a votar.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Ya están entrando los que faltan.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Sí.

Esperaremos unos minutos.

Están sonando los timbres.

Señor Secretario , haga el llamado respectivo.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

Discusión en Sala

(La Senadora Campillai, ingresando a la Sala, levanta la mano).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Sí, falta la Senadora Campillai.

La vamos a esperar, Senadora. No se preocupe.

La señora CAMPILLAI.-

Muy amable. Muchas gracias.

(Pausa).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Cerrada la votación.

--Se aprueban las observaciones formuladas por el Presidente de la República (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Edwards, Elizalde, Flores, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kusanovic, Latorre, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Aprobado y despachado el veto.

¿Dejamos la constancia de su voto favorable, Senador Keitel?

El señor KEITEL.-

Sí, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Así se consigna.

El señor KEITEL.-

Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Vamos a pasar ahora al proyecto que por unanimidad se acordó agregar a la tabla de hoy.

Le damos la bienvenida al Ministro de Obras Públicas, quien se ha hecho presente en la sesión.

4.10. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Observaciones . Fecha 16 de noviembre, 2022. Oficio en Sesión 99. Legislatura 370.

Valparaíso, 16 de noviembre de .2022

Nº 520/SEC/22

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al Boletín N° 14.440-07.

Hago presente a Su Excelencia que la observación signada con el número 10), en lo que respecta al nuevo artículo 12 que propone, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, fue aprobada con el voto afirmativo de 34 senadores, de un total de 47 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 17.808, de 24 de octubre de 2022.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ÁLVARO ELIZALDE SOTO

Presidente del Senado

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario General (S) del Senado

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 21 de noviembre, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 21 de noviembre de 2022

Oficio N° 17.873

A S.E. LA PRESIDENTA DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al boletín N° 14.440-07.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N°520/SEC/22, mediante el cual el H. Senado comunica la aprobación de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al referido proyecto.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del artículo 12 del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,”, e intercálase, entre la expresión “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “367 quáter, 367 septies”

2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Artículo 366 quáter. El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo 6 bis, nuevo:

“§ 6 bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.

4. Derógase el artículo 366 quinquies.

5. Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

Oficio al Tribunal Constitucional

“Artículo 367. El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.”.

6. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero”.

7. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“Artículo 367 quáter. El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Artículo 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Artículo 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

Artículo 367 octies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

8. Reemplázase en el encabezado del Párrafo 7 del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres

Oficio al Tribunal Constitucional

párrafos anteriores”.

10. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

11. En el artículo 368 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázase la expresión “o 374 bis” por “, 367 quáter o 367 septies”.

12. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

13. Suprímese el artículo 369 bis.

14. En el artículo 369 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázase la expresión “374 bis, inciso primero y 374 ter” por “367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies”.

15. En el artículo 369 quinquies:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Incorpórase, luego de la expresión “367 ter”, la expresión “, 367 quáter y 367 septies”.

16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

17. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

18. En el artículo 372:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

b) En su inciso segundo:

i. Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter, 367 septies”.

19. Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

20. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

1. En el inciso primero del artículo 1:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo.”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

2. En el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis en el Código Procesal Penal:

Oficio al Tribunal Constitucional

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

1. Elimínase la expresión “366 quinquies;”.

2. Agrégase, a continuación de la expresión “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4 de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la expresión “366 quinquies” por “367 quáter inciso segundo;”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies;”, y agrégase, a continuación de la expresión “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo;”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3 del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 191 bis, la expresión “párrafos 5 y 6” por “párrafos 5, 6 y 6 bis”.

2. Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 469 la frase “366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter” por “367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies”.

Artículo 8.- Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

2. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter”.

3. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 septies”.

Artículo 9.- Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

2. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter, 367 septies”.

Artículo 10.- Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, entre la expresión “6°” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

Artículo 11.- Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

1. Intercálase, entre la expresión “6°” y conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

2. Elimínase la expresión “, 374 bis”.

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

Oficio al Tribunal Constitucional

1. Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”.

2. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Artículo 13.- Sustitúyese en el artículo 30 de la ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, la frase “366 quinquies, 374 bis y 374 ter” por la expresión “367 quáter y 367 quinquies”.

Artículo 14.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

En la Cámara de Diputados la observación de S.E. el Presidente de la República que incorporó un nuevo artículo 12 en el proyecto de ley, fue aprobada con el voto a favor de 130 diputados, sobre un total de 155 en ejercicio.

En el Senado la señala observación fue aprobada con el voto favorable de 34 senadores, de un total de 47 en ejercicio.

Se dio cumplimiento así, en todos los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cúpleme informar a V.E. que la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 17.778, de fecha 17 de octubre de 2022, solicitó su opinión a la Excma. Corte Suprema acerca del nuevo artículo 12, que introduce modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales.

Adjunto a V.E. copia de la respuesta de la Excma. Corte Suprema, contenida en el oficio N° 221-2022, de 28 de octubre de 2022.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan actas, por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

5.2. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 13 de diciembre, 2022. Oficio en Sesión 108. Legislatura 370.

2022

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia Rol 13.830-22 CPR

[13 de diciembre de 2022]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y MODIFICA OTROS TEXTOS LEGALES QUE INDICA, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 14.440-07

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 17.873, de 21 de noviembre de 2022 ingresado a esta Magistratura con la misma fecha - la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al boletín N° 14.440-07, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del artículo 12 del proyecto de ley;

SEGUNDO: Que, el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre la norma del proyecto de ley remitido que esté comprendida dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

II.NORMA DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDA A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, la disposición del proyecto de ley remitido que ha sido sometida a control de constitucionalidad es la que se indica a continuación:

“Artículo12.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

1. Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”.

2.Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter.”;

III.NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

QUINTO: Que, el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política, señala que:

Oficio del Tribunal Constitucional

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”;

IV.NORMA DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTE NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

SEXTO: Que, la disposición legal consultada amplía las hipótesis en que determinados crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República quedan sometidos a la jurisdicción chilena, puesto que se otorgan atribuciones a los tribunales de justicia en relación a aquéllos, y por ello es propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 77, inciso primero, de la Carta Fundamental, como ya lo señalara esta Magistratura en STC 399, c.5°, en que se controló la constitucionalidad de la Ley N° 19.927, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil, así como en otras sentencias, como son las Roles N°s. 1316, c. 6°; 1439,c.6°;3130,c.8°y8196,c.8°;

V.NORMA ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

SÉPTIMO: Que, el artículo 12 del proyecto de ley en examen es conforme con la Constitución Política.

VI.INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

OCTAVO: Que, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta en Oficio N° 221-2022, de 28 de octubre de 2022, que rola a fojas 18, dirigido al Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Raúl Soto Mardones;

VII.CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LA NORMA DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

NOVENO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que la norma sobre la cual este Tribunal emite pronunciamiento fue aprobada, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 77, inciso primero, y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

QUE EL ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y MODIFICA OTROS TEXTOS LEGALES QUE INDICA, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 14.440-07, ES CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

PREVENCIÓN

El Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR previene que estuvo también por calificar como propio de ley orgánica constitucional el artículo 12 examinado, teniendo presente además, que la preceptiva del proyecto de ley incorpora nuevos tipos penales, y por tanto, amplía la competencia de los tribunales de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, y por tanto incide en las atribuciones de los tribunales de justicia en los términos que determina la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.

Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N°13.830-22 CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor

Oficio del Tribunal Constitucional

José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Rodrigo Patricio Pica Flores y señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López Magnasco.



6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 19 de diciembre, 2022. Oficio

VALPARAÍSO, 19 de diciembre de 2022

Oficio N° 17.935

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio N° 17.873, de 21 de noviembre de 2022, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al boletín N° 14.440-07, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad el artículo 12 del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 488-2022, de 16 de diciembre de 2022, con la sentencia recaída en la materia, y ha declarado que el artículo 12 del proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al boletín N° 14.440-07, es conforme con la Constitución Política.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, N° 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión “366 quinquies,”, e intercálase, entre la expresión “367 ter” y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: “,367 quáter, 367 septies”.

2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“Artículo 366 quáter. El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años.”.

3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo 6 bis, nuevo:

“§ 6 bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.”.

4. Derógase el artículo 366 quinquies.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5. Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

“Artículo 367. El que promoviére o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.”.

6. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala “, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro” por la siguiente frase: “obtuviere la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero”.

7. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

“Artículo 367 quáter. El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

Artículo 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Artículo 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

Artículo 367 octies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”.

8. Reemplázase en el encabezado del Párrafo 7 del Título VII del Libro II la expresión “dos párrafos anteriores” por “tres párrafos anteriores”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión “en los dos párrafos anteriores” por “en los tres párrafos anteriores”.

10. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión “los párrafos 5 y 6 de este Título” por “los tres párrafos anteriores”.

11. En el artículo 368 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázase la expresión “o 374 bis” por “, 367 quáter o 367 septies”.

12. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión “en los párrafos 5 y 6 de este Título” por “en los tres párrafos anteriores”.

13. Suprímese el artículo 369 bis.

14. En el artículo 369 ter:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Reemplázase la expresión “374 bis, inciso primero y 374 ter” por “367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies”.

15. En el artículo 369 quinquies:

a) Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

b) Incorpórase, luego de la expresión “367 ter”, la expresión “, 367 quáter y 367 septies”.

16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

17. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

18. En el artículo 372:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los dos párrafos precedentes” por “los tres párrafos anteriores”.

b) En su inciso segundo:

i. Elimínase la expresión “366 quinquies,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter, 367 septies”.

19. Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión “los dos párrafos anteriores” por “los tres párrafos anteriores”.

20. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

1. En el inciso primero del artículo 1:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo.”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2. En el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis en el Código Procesal Penal:

a) Sustitúyese la expresión “en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo” por “en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo”.

b) Suprímese la expresión “374 bis;”.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

1. Elimínase la expresión “366 quinquies;”.

2. Agrégase, a continuación de la expresión “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4 de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la expresión “366 quinquies” por “367 quáter inciso segundo;”.

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión “366 quinquies;”, y agrégase, a continuación de la expresión “367 ter”, lo siguiente: “, 367 quáter inciso segundo;”.

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3 del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión “366 quinquies, 367” por la siguiente: “367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies”.

Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 191 bis la expresión “párrafos 5 y 6” por “párrafos 5, 6 y 6 bis”.

2. Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 469 la frase “366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter” por “367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies”.

Artículo 8.- Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

2. Intercálase, entre la expresión “367 ter” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 367 quáter”.

3. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 septies”.

Artículo 9.- Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión “, 366 quinquies”.

2. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter, 367 septies”.

Artículo 10.- Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, entre la expresión “6°” y la conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

Artículo 11.- Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

1. Intercálase, entre la expresión “6°” y conjunción copulativa “y” que le sigue, la expresión “, 6° bis”.

2. Elimínase la expresión “, 374 bis”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

1. Reemplázanse las expresiones “366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1,” por las expresiones “367, 367 quáter inciso segundo y 367 septies”.
2. Reemplázase la expresión “374 bis” por “367 quáter”.

Artículo 13.- Sustitúyese en el artículo 30 de la ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, la frase “366 quinquies, 374 bis y 374 ter” por la expresión “367 quáter y 367 quinquies”.

Artículo 14.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Dios guarde a V.E.

VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley N° 21.522

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 21.522

Tipo Norma	:	Ley 21522
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1187183&t=0
Fecha	:	20-12-2022
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3av3o
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Fecha	:	30-12-2022
Publicación		

LEY NÚM. 21.522

INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 94 bis suprímese la expresión "366 quinquies," e intercálase, entre la expresión "367 ter" y el punto y coma que le sigue, lo siguiente: ", 367 quáter, 367 septies".

2. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 366 quáter, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

"Artículo 366 quáter. El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si se determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo.

Será sancionado con la misma pena del inciso precedente al que determinare a una persona menor de catorce años a enviar, entregar o exhibir:

a) Imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de catorce años de edad.

Ley N° 21.522

b) Imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de catorce años."

3. Incorpórase, a continuación del artículo 366 quáter, el siguiente Párrafo 6 bis, nuevo:

"§ 6 bis. Explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes."

4. Derógase el artículo 366 quinquies.

5. Sustitúyese el artículo 367 por el siguiente:

"Artículo 367. El que promoviére o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero."

6. Reemplázase en el artículo 367 ter el texto que señala ", a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro" por la siguiente frase: "obtuvo la realización de una acción sexual de una persona menor de dieciocho años a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero".

7. Incorpóranse, a continuación del artículo 367 ter, los siguientes artículos 367 quáter, 367 quinquies, 367 sexies, 367 septies y 367 octies:

"Artículo 367 quáter. El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su

Ley N° 21.522

voz o imagen, con los mismos fines.

Artículo 367 quinquies. Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición, señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.

Artículo 367 sexies. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del Título VII del Libro Segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Artículo 367 septies. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

Artículo 367 octies. Para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida."

8. Reemplázase en el encabezado del Párrafo 7 del Título VII del Libro II la expresión "dos párrafos anteriores" por "tres párrafos anteriores".

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 368 la expresión "en los dos párrafos anteriores" por "en los tres párrafos anteriores".

10. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión "los párrafos 5 y 6 de este Título" por "los tres párrafos anteriores".

11. En el artículo 368 ter:

a) Elimínase la expresión "366 quinquies,".

b) Reemplázase la expresión "o 374 bis" por ", 367 quáter o 367 septies".

12. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 369 la expresión "en los párrafos 5 y 6 de este Título" por "en los tres párrafos anteriores".

13. Suprímese el artículo 369 bis.

14. En el artículo 369 ter:

a) Elimínase la expresión "366 quinquies,".

b) Reemplázase la expresión "374 bis, inciso primero y 374 ter" por "367 quáter, incisos primero y segundo, y 367 septies".

15. En el artículo 369 quinquies:

Ley N° 21.522

a) Elimínase la expresión "366 quinquies,".

b) Incorpórase, luego de la expresión "367 ter", la expresión ", 367 quáter y 367 septies".

16. Reemplázase en el inciso primero del artículo 370 bis la expresión "los dos párrafos anteriores" por "los tres párrafos anteriores".

17. Reemplázase en el inciso primero del artículo 371 la expresión "los dos párrafos precedentes" por "los tres párrafos anteriores".

18. En el artículo 372:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión "los dos párrafos precedentes" por "los tres párrafos anteriores".

b) En su inciso segundo:

i. Elimínase la expresión "366 quinquies,".

ii. Intercálase, entre la expresión "367 ter" y la conjunción copulativa "y" que le sigue, la expresión ", 367 quáter, 367 septies".

19. Reemplázase en el artículo 372 ter la expresión "los dos párrafos anteriores" por "los tres párrafos anteriores".

20. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales:

1. En el inciso primero del artículo 1:

a) Sustitúyese la expresión "en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo" por "en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo.".

b) Suprímese la expresión "374 bis;".

2. En el numeral 2 del artículo 32 N° 2, que introduce un nuevo artículo 110 bis en el Código Procesal Penal:

a) Sustitúyese la expresión "en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo" por "en los Párrafos 5, 6 y 6 bis del Título VII del Libro Segundo".

b) Suprímese la expresión "374 bis;".

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad:

1. Elimínase la expresión "366 quinquies,".

Ley N° 21.522

2. Agrégase, a continuación de la expresión "367 ter", lo siguiente: ", 367 quáter, 367 septies".

Artículo 4.- Sustitúyese en el artículo 4 de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la expresión "366 quinquies" por "367 quáter inciso segundo,".

Artículo 5.- Elimínase en el literal b) del artículo 15 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la expresión "366 quinquies,", y agrégase, a continuación de la expresión "367 ter", lo siguiente: ", 367 quáter inciso segundo,".

Artículo 6.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 3 del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la expresión "366 quinquies, 367" por la siguiente: "367, 367 ter, 367 quáter, 367 septies".

Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 191 bis la expresión "párrafos 5 y 6" por "párrafos 5, 6 y 6 bis".

2. Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 469 la frase "366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter" por "367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quinquies y 367 septies".

Artículo 8.- Introdúcense en el literal e) del artículo 17 de la ley N° 19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la observación de buena conducta, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión ", 366 quinquies".

2. Intercálase, entre la expresión "367 ter" y la conjunción copulativa "y" que le sigue, la expresión ", 367 quáter".

3. Reemplázase la expresión "374 bis" por "367 septies".

Artículo 9.- Introdúcense en el literal a) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:

1. Elimínase la expresión ", 366 quinquies".

2. Reemplázase la expresión "374 bis" por "367 quáter, 367 septies".

Artículo 10.- Intercálase, en el literal b) del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, entre la expresión "6°" y la conjunción copulativa "y" que le sigue, la expresión ", 6° bis".

Artículo 11.- Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, las siguientes modificaciones:

1. Intercálase, entre la expresión "6°" y conjunción copulativa "y" que le sigue, la expresión ", 6° bis".

Ley N° 21.522

2. Elimínase la expresión ", 374 bis".

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 10° del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales:

1. Reemplázanse las expresiones "366 quinquies, 367 y 367 bis N° 1," por las expresiones "367, 367 quáter inciso segundo y 367 septies".

2. Reemplázase la expresión "374 bis" por "367 quáter".

Artículo 13.- Sustitúyese en el artículo 30 de la ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, la frase "366 quinquies, 374 bis y 374 ter" por la expresión "367 quáter y 367 quinquies".

Artículo 14.- Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 20 de diciembre de 2022.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Marcela Ríos Tobar, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.- Kenneth Giorgio Jackson Drago, Ministro de Desarrollo Social y Familia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al boletín N° 14.440-07

El Secretario Subrogante del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el

Ley N° 21.522

control de constitucionalidad respecto del artículo 12 del proyecto de ley; y por sentencia de 13 de diciembre de 2022, en los autos Rol N° 13.830-22-CPR.

Se declara:

Que el artículo 12 del proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, y modifica otros textos legales que indica, correspondiente al Boletín N° 14.440-07, es conforme con la Constitución Política.

Santiago, 16 de diciembre de 2022.- Sebastián Andrés López Magnasco, Secretario (S).